

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM nº RJ2011/3823

Acusados: Armando Tadeu Buchina
Arthur Gilberto Voorsluys
Fabio Floh
Luiz Álvaro Moreira Ferreira Filho
Nilton Batista Muniz
Othniel Rodrigues Lopes
Rodrigo Andres Pimenta Hoffmann
Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha
Silvana Dino
Tarcísio Antônio de Rezende Duque

Ementa: Uso de informação privilegiada ainda não divulgada ao mercado. *Absoluções e Multas.*

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. **Absolver Fabio Floh, Luiz Álvaro Moreira Ferreira Filho, Nilton Batista Muniz, Silvana Dino, Tarcísio Antônio de Rezende Duque, Rodrigo Andrés Pimenta Hoffmann e Armando Tadeu Buchina** da imputação de infração ao disposto no *caput* do art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002, c/c o art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76, no que diz respeito às alienações de BDRs patrocinadas pela LAEP realizadas entre os dias 8.1.2010 e 13.1.2010.
2. **Absolver Othniel Rodrigues Lopes, Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha, Armando Tadeu Buchina e Arthur Gilberto Voorsluys** da imputação de infração ao disposto no *caput* do art. 13 da Instrução CVM nº 358/02, c/c o art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76, no que concerne às alienações de BDRs patrocinadas pela LAEP realizadas entre os dias 14.1.2010 e 15.1.2010.
3. **Absolver Luiz Álvaro Moreira Ferreira Filho** da imputação de infração ao disposto no *caput* do art. 13 da Instrução CVM nº 358/02, c/c o art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76, com relação à alienação de 150.000 BDRs patrocinados pela LAEP, realizada no dia 28.1.2010.
4. Com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76, e §1º, inciso I, do mesmo dispositivo legal, aplicar ao acusado Othniel Rodrigues Lopes:
 - 4.1. A penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00**, por ter infringido o disposto no art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76, combinado com o *caput* do art. 13 da Instrução CVM nº 358/02, ao ter alienado, no dia 13.1.2010, 400.000 BDRs patrocinados pela LAEP, de posse de informações privilegiadas sobre a celebração de acordo, que seria divulgado ao mercado em 15.1.2010, por meio de aviso de fato relevante;

4.2. A penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00**, por ter infringido o disposto no art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76, combinado com o *caput* do art. 13 da Instrução CVM nº 358/02, ao ter alienado, no dia 18.1.2010, 400.000 BDRs patrocinados pela LAEP, de posse de informações privilegiadas sobre a operação de conversão de dívidas da sociedade, que seria divulgada ao mercado em 28.1.2010, por meio de aviso de fato relevante; e

4.3. A penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00**, por ter infringido o disposto no art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76, combinado com o *caput* do art. 13 da Instrução CVM nº 358/02, ao ter alienado, no dia 20.1.2010, 350.000 BDRs patrocinados pela LAEP, de 20.2.2010, 350.000 BDRs patrocinados pela LAEP, de posse de informações privilegiadas sobre a operação de conversão de dívidas da sociedade, que seria divulgada ao mercado em 28.1.2010, por meio de aviso de fato relevante.

5. O Colegiado deliberou, ainda, comunicar o resultado do julgamento à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício/CVM/SGE/Nº 35/2011, enviado em 16.5.2011 (fl. 2.495).

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

A CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao citado Conselho de Recursos.

Proferiram defesas orais os advogados *Marcus de Freitas*, representando os acusados Arthur Gilberto Voorsluys e Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha; *João Felipe Figueira de Melo*, representando os acusados Armando Tadeu Buchina, Othniel Rodrigues Lopes e Rodrigo Andres Pimenta Hoffmann; e *Maria Isabel do Prado Bocater*, representando os acusados Luis Álvaro Moreira Ferreira Filho, Nilton Batista Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Antônio de Rezende Duque.

Presente a Procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteira, Relator, Gustavo Tavares Borba, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2015.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2011/3823

Acusados: Othniel Rodrigues Lopes
Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha
Fábio Floh
Armando Tadeu Buchina
Arthur Gilberto Voorsluys
Luis Álvaro Moreira Ferreira Filho
Nilton Batista Muniz
Silvana Dino
Tarcísio Antônio de Rezende Duque
Rodrigo Andres Pimenta Hoffmann

Assunto: Negociação com uso de informação privilegiada ainda não divulgada ao mercado (infração ao art. 155, § 4º, da Lei nº 6.404/76, c/c art. 13, *caput*, da Instrução CVM nº 358/02).

Relator: Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI para apurar a responsabilidade de Othniel Rodrigues Lopes (“Othniel Lopes”), diretor-presidente da Parmalat Brasil S.A. Indústria de Alimentos (“Parmalat”) e membro do conselho de administração da Laep Investments Ltd. (“LAEP” ou “Companhia”), Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha (“Rodrigo Ferraz”), diretor de relações com investidores e membro do conselho de administração da LAEP, Armando Tadeu Buchina (“Armando Buchina”), Arthur Gilberto Voorsluys (“Arthur Gilberto”), Luiz Álvaro Moreira Ferreira Filho (“Luiz Álvaro”), Nilton Batista Muniz (“Nilton Muniz”), Silvana Dino e Tarcísio Antônio de Rezende Duque (“Tarcísio Duque”), diretores da Parmalat, Fabio Floh, gerente jurídico da Parmalat, e Rodrigo Andrés Pimenta Hoffmann (“Rodrigo Hoffmann”), gerente executivo financeiro da Parmalat, por terem negociado Certificados de Depósito de Valores Mobiliários – BDRs de emissão da LAEP, na posse de informações relevantes ainda não divulgadas ao mercado, em violação ao art. 13, *caput*, da Instrução CVM nº 358/2002¹, combinado com o artigo 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976².

2. Este processo administrativo tem origem no Processo CVM nº RJ2010/12402, em que a SMI, em sua atividade de acompanhamento de mercado, procurou verificar indícios de manipulação e de uso de informação privilegiada com BDRs emitidos pela LAEP (código Bovespa MILK11).

II. DOS FATOS

3. Em sua atividade de acompanhamento de mercado, a SMI, entre dezembro de 2009 e março de 2010, monitorou o comportamento, em termos de preço e volume, dos BDRs de emissão da LAEP (MILK11), tendo em conta os comunicados ao mercado e os fatos relevantes publicados, naquele período, pela administração da Companhia e de sua controlada indireta Parmalat, e as notícias publicadas na imprensa sobre seus negócios.

4. Este monitoramento foi iniciado quando se observou, entre 15 e 17.12.2009, uma variação positiva de 58,7% na cotação de fechamento de MILK11, que passou de R\$0,63 para R\$1,00, chegando a atingir R\$1,12 no pico *intra-day*, oscilação esta sobre a qual a LAEP, em comunicados de 16 e 17.12.2009, informou desconhecer qualquer fato ainda não divulgado ao mercado que pudesse justificá-la (fls. 01-02)³.

5. A partir daí, e até o fim de março de 2010, a SMI observou as seguintes oscilações de preço e volume do papel, fatos relevantes e notícias na imprensa (fls. 1244-1245):

a. Fato relevante conjunto de LAEP e Parmalat, de 21.12.2009, 7h:09min, comunicando, em complemento a outro divulgado em 20.4.2009, a aprovação pela CVM do registro de Oferta Pública de Aquisição (OPA) de ações da Parmalat pela Lácteos do Brasil S.A. ("Lácteos"), sua controladora direta e controlada da LAEP, para o fechamento de seu capital (fl. 5);

b. Oscilação de MILK11 entre 29.12.2009 e 04.1.2010, quando subiu de R\$0,98 para R\$1,36 (R\$1,49 no pico), com volume similar ao dos pregões de 15 a 17.12;

c. Notícia publicada pelo portal Exame em 5.1.2010, dando como acertada a venda da Parmalat para o grupo JBS Friboi (fl. 6);

d. Disparada de MILK11 a partir de 06.1.2010, atingindo R\$2,86 em 11.01, com pico de R\$3,55 em 08.01 e com volume ainda mais elevado que nos pregões anteriores;

e. Fato relevante de LAEP, de 15.1.2010, 11h:08min, anunciando ter obtido uma capitalização de R\$120 milhões, a ser realizada pelo fundo de investimento GEM – Global Yield Fund Limited ("GEM") (fl. 7);

f. Oscilação negativa de MILK11 em 15.1.2010, que abriu a R\$2,50 (queda de 5,7%), recuperou-se para R\$2,82 no *intra-day*, e fechou a R\$2,50, variando nos pregões seguintes entre R\$2,40 e R\$2,80, até iniciar, a partir de 4.2.2010, trajetória descendente;

g. Comunicado ao mercado conjunto de LAEP e Parmalat, informando, em 27.1.2010, a conclusão da OPA da Parmalat (fl. 10);

h. Fato relevante de LAEP, informando, em 28.1.2010, 18h:29min, a conversão de parte de sua dívida com "*importantes credores estratégicos*" em ações classe A (fls. 11);

i. Notícia publicada pelo portal Exame em 24.2.2010, informando que a venda da Parmalat para o *GP Investments* encontrava-se em fase adiantada de negociação (fl. 12);

j. Fato relevante conjunto de LAEP e Monticiano Participações S.A. ("Monticiano"), controlada pela GP Dairy, LLC, do grupo *GP Investments*, de 14.3.2010, 10h:08min, anunciando acordo de investimentos em que marcas pertencentes a controladas da LAEP seriam aportadas ao capital da Monticiano, em troca de participação minoritária nas ações desta última (fls. 13-14); e

k. Oscilação de MILK11, nos dias que antecederam o anúncio do acordo com Monticiano, quando apresentou aumento significativo de preço e volume negociado.

6. A respeito do fato relevante anunciado em 15.1.2010, a SMI solicitou cópia do contrato firmado entre LAEP e GEM para a operação de capitalização, além de outros esclarecimentos, em especial a cronologia dos fatos e as pessoas envolvidas nas negociações (fls. 15-16)⁴.

7. A LAEP informou, às fls. 18-23, que o aporte de capital do GEM se tratava de operação PIPE – *Private Investment in Public Equity*, envolvendo a abertura de uma linha de crédito para futuros aumentos de capital de até R\$120 milhões, em que seriam emitidas somente Ações Classe A não integrantes da estrutura de controle.

8. Segundo a Companhia, a operação foi inicialmente proposta a Othniel Lopes, por R. S., advogado do escritório L. A. A, em meados de dezembro de 2009, e a primeira reunião formal para tratar da operação teria acontecido em 15.12.2009, entre Othniel Lopes e M. E, pela LAEP, e M. M. e C. A., pelo lado do GEM. Entre 6.1.2010 foram retomados os contatos e um dia depois houve nova reunião, entre Othniel Lopes e M. E, pela LAEP, e M. M., C. A. e R. S., pelo GEM. Rodrigo Ferraz também teria tomado ciência destas tratativas no dia 7.1. A partir daí, foi desenhada definitivamente a operação, com o envio de minutas em 8.1.2010, seguido por negociações e revisões, até a assinatura dos documentos definitivos, entre a noite de 14.1 e a manhã de 15.1.2010.

9. Informou também a LAEP que, por volta das 11h00min do dia 14.1.2010, "*a Diretoria e o pessoal de gestão da Companhia (...) incluindo*" Armando Buchina, Arthur Gilberto, Fabio Floh, Luis Álvaro, Nilton Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque, foram chamados à sua sede por Othniel Lopes e Rodrigo Ferraz "*para a apresentação das linhas gerais da operação que se encontrava em fase final de discussão e troca de minutas, assim como a perspectiva do Conselho e dos Controladores em vista deste evento*" (fl.20).

10. Por fim, a LAEP relacionou todas as pessoas que tiveram ciência da operação antes de sua divulgação, entre diretores, funcionários e consultores da Companhia e da Parmalat e pessoas ligadas ao GEM (fls. 21-23).

11. A SMI resumiu os principais pontos do contrato de subscrição (fls. 46-73) firmado por LAEP e GEM em 15.1.2010 (fls. 1246-1247) da seguinte maneira:

a. O fundo GEM concedeu à LAEP uma opção para exigir a subscrição de ações ordinárias classe A (sem direito a voto) pelo Central Veredas Fundo de Investimentos em Participações ("Central Veredas"), fundo de participações controlado integralmente por GEM, até um valor total de R\$120.000.000,00, num prazo máximo de 3 anos;

b. Na data do acordo, *Laep Investment & Restructuring Fund SPC Cayman*, controladora da LAEP, deveria transferir 54.870.000 BDRs para Central Veredas, a título de adiantamento⁵;

c. Após este adiantamento, o GEM transferiria R\$20.000.000,00 para a LAEP, que em troca emitiria ações ordinárias pelo último preço de fechamento. Os BDRs referentes a essas ações seriam entregues ao Central Veredas;

d. As chamadas de capital seriam feitas através da emissão, pela LAEP, de notas de subscrição contra o GEM, especificando o número de ações a serem subscritas e o preço mínimo de subscrição, não inferior a R\$1,50 exceto em caso de acordo entre as partes; e

e. O preço de subscrição seria igual a 88% da média dos preços de fechamento do período de nove pregões subsequentes à emissão de uma nota de subscrição, excluídos os dias em que o papel não fosse negociado ou que 88% do preço de fechamento fosse inferior a R\$1,50 (ou seja, que o preço de fechamento fosse inferior a R\$1,71).

12. Com base nesses pontos, a SMI concluiu que "a estratégia de investimento do GEM na LAEP, através da **subscrição privada de ações novas a um preço inferior ao do mercado**, provoca a diluição do capital ensejando, a princípio, **uma redução no valor das ações**" (fl. 1247). (grifo no original)

13. Foram então analisados os negócios em bolsa com MILK11, por meio de listagens enviadas pela BSM (fls. 26-27 e 36-37), para identificar eventuais negociações por parte de pessoas ligadas às companhias envolvidas ou de outros investidores, que revelassem indícios de uso de informações privilegiadas ligadas ao fato relevante divulgado em 15.1.2010.

14. Na análise, a SMI identificou negócios com MILK11 feitos pelas pessoas ligadas à LAEP e à Parmalat relacionadas a seguir, nos pregões que antecederam a divulgação do aludido fato relevante, que comunicou a capitalização feita pelo GEM na LAEP:⁶

- a. Armando Tadeu Buchina - diretor de tecnologia da informação da Parmalat;
- b. Arthur Gilberto Voorsluys - diretor de operações da Parmalat;
- c. Fabio Floh - gerente Jurídico da Parmalat;
- d. Luis Álvaro Moreira Ferreira Filho - diretor de comércio exterior da Parmalat;
- e. Nilton Batista Muniz - diretor de vendas da Parmalat;
- f. Othniel Rodrigues Lopes - diretor-presidente da Parmalat e membro do Conselho de Administração da LAEP;
- g. Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha - diretor de relação com investidores e membro do conselho de administração da LAEP;
- h. Silvana Dino - diretora de recursos humanos da Parmalat;
- i. Tarcísio Antônio de Rezende Duque - diretor industrial da Parmalat;
- j. Rodrigo Andrés Pimenta Hoffmann - gerente executivo financeiro da Parmalat.

15. Ademais, todos eles, excetuando-se, novamente, Rodrigo Hoffmann⁷, foram citados pela LAEP (fl. 20) como participantes da reunião havida na Companhia em 14.1.2010, comentada no Item 9 retro, na qual teria sido comunicada e explicada a operação com a GEM, que viria a ser divulgada um dia depois como fato relevante.

16. Todos foram inquiridos pela SMI a respeito dos negócios em bolsa realizados com MILK11 proximamente à divulgação do fato relevante de 15.01.2010 (fls. 515-550, 920-923).⁸

17. A seguir, são relacionados os negócios com MILK11 realizados por cada um deles, entre 26.3.2009 a 19.03.2010, e as justificativas apresentadas para a realização das operações (fls. 551-918, 1178-1184).

Fabio Floh

18. Conforme informou a LAEP, às fls. 18-23, Fabio Floh soube das negociações com o GEM em 14.1.2010.

Tabela 1: Negócios de Fabio Floh com MILK11, entre 26.3.2009 a 19.03.2010.

Data	Compra	Valor (R\$)	Nº	Vendas	Valor (R\$)	Nº
11.1.2010				90.000	270.600,	6
12.1.2010				50.000	119.400,	4
13.1.2010				10.000	22.000,0	1
4.2.2010				20.000	49.800,0	4
8.2.2010				10.000	22.200,0	45
18.2.2010	40.000	73.800,0	2	40.000	74.700,0	6
19.2.2010	10.000	19.800,0	1	10.000	22.200,0	13
22.2.2010				20.000	39.850,0	5
Total	50.000	93.600,0	3	250.000	620.750,	84

19. Em sua resposta, às fls. 577 a 579, Fabio Floh afirmou ter recebido 200.000 MILK11, em 5.6.2009, como parte do plano de remuneração por seu cargo de Gerente Jurídico da Parmalat, e que, antes de negociá-las no mercado, tomou as seguintes providências:

- a. Aguardou o encerramento do período de *black-out* obrigatório referentes às ITRs de 2009 da LAEP e da Parmalat, em atraso desde quando recebeu os BDRs⁹;
- b. Protocolizou na LAEP um Plano Individual de Investimento (fls. 580-593), datado de 5.11.2009, pelo qual poderia adquirir ou alienar até 150.000 BDRs por mês; e
- c. Verificou, à época de cada negociação, se estava de posse de qualquer informação privilegiada ainda não divulgada.

20. Fabio Floh confirmou as informações prestadas pela LAEP, de que teria sabido da operação entre a companhia e o fundo GEM no dia 14.1.2010, um dia antes de sua efetivação, alegando, assim, que as operações que realizou entre 11.1 e 13.1.2010 foram feitas antes de ter tomado conhecimento daquele fato relevante e também de sua divulgação ao mercado.

21. Afirmou, também, que após tomar conhecimento da operação com a GEM, suspendeu qualquer negociação com MILK11, tendo efetuado novas negociações somente em 4.2.2010, quando a informação já estava amplamente disseminada no mercado. Por fim, alegou ser, há mais de sete anos, investidor contumaz da bolsa de valores, operando com vários papéis e, inclusive, fazendo *day trades*.

Luis Álvaro

22. Conforme informou a LAEP, às fls. 18-23, Luis Álvaro soube das negociações com o GEM em 14.1.2010.

Tabela 2: Negócios de Luis Álvaro com MILK11, entre 26.3.2009 a 19.03.2010.

Data	Compra	Valor (R\$)	Nº	Vendas	Valor (R\$)	Nº
30.7.2009				30.000	16.500,00	1

15.12.200				28.500	19.950,00	1
8.1.2010				91.500	320.250,0	5
13.1.2010				50.000	127.500,0	5
28.1.2010				150.000	382.000,0	17
4.2.2010	40.000	91.500,0	5			
9.3.2010	40.000	43.600,0	1			
16.3.2010				180.000	323.000,0	17
Total	80.000	135.100,0	6	530.000	1.189.200	46

23. Em sua resposta, à fl. 594, ele afirmou que exercia, à época, o cargo de Diretor de Comércio Exterior da Parmalat, *"não exercendo qualquer cargo de natureza estatutária e não participando, direta ou indiretamente, de negociações ou decisões estratégicas da empresa"*.

24. Confirmou ter tido conhecimento da operação entre LAEP e GEM no dia 14.1.2010, alegando, dessa forma, que os seus negócios com MILK11 teriam sido negociações normais de investidor, sem a utilização de informações privilegiadas.

Nilton Muniz

25. Conforme informou a LAEP, às fls. 18-23, Nilton Muniz soube das negociações com o GEM em 14.1.2010.

Tabela 3: Negócios de Nilton Muniz com MILK11, entre 26.3.2009 a 19.03.2010.

Data	Compra	Valor	Nº	Vendas	Valor	Nº
13.1.2010				650.000	1.450.000	30
9.2.2010	15.000	31.650,0	3			
5.3.2010	15.000	24.000,0	1			
Total	30.000	55.650,0	4	650.000	1.450.000	30

26. Em sua resposta, às fls. 595-596, ele disse que não ocupava cargo estatutário, atuando como *"profissional de vendas"*, e como tal não acompanhava ou esteve envolvido em qualquer negociação ou fato relevante da companhia, tendo recebido os BDRs como forma de atratividade para a aceitação do cargo.

27. Declarou que *"não tinha conhecimento do fato relevante que veio a ser publicado em 15 de janeiro"*, não confirmando a informação dada pela LAEP, às fls. 18-23, de que ele teria tido conhecimento da operação com a GEM no dia 14.1.2010, em reunião na Companhia.

28. Nilton Muniz justificou a venda de 650.000 MILK11 em 13.1.2010 com base nas cotações apresentadas pelo papel na bolsa e no seu objetivo de realizar o benefício recebido em sua contratação. Nesse sentido, alegou que a venda foi realizada dias após o pico máximo de preço, ocorrido em 08.01, e que acreditava, na data da venda, que o papel havia se estabilizado em novo patamar. Além disso, apontou que a cotação se manteve acima do preço médio de suas vendas, R\$2,23, nos 19 pregões subsequentes, o que demonstraria a normalidade do preço de suas vendas e que, durante o pregão de 15.01, após a divulgação do fato relevante, o papel apresentou valorização durante o

pregão, chegando a um preço máximo de R\$2,82, bem acima do referido preço médio a que vendeu¹⁰.

29. Sobre as operações de compra de 9.2 (a R\$2,11) e 5.3.2010 (a R\$1,60), alegou que foram realizadas após pregões que apresentaram quedas relevantes na cotação do papel, ocasião em que acreditou que o preço poderia se recuperar a um patamar acima de R\$2,00. Afirmou, ademais, ter revendido os BDRs em 19.5.2010 (fora do período analisado pela SMI) a R\$0,76, com significativo prejuízo.

Silvana Dino

30. Conforme informou a LAEP, às fls. 18-23, Silvana Dino soube das negociações com o GEM em 14.1.2010.

Tabela 4: Negócios de Silvana Dino com MILK11, entre 26.3.2009 a 19.03.2010.

Data	Vendas	Valor	Nº
13.1.2010	250.000	540.500,0	36
Total	250.000	540.500,0	36

31. Em sua resposta, à fl. 917, ela afirmou que exercia, à época, o cargo de Diretora de Recursos Humanos da Parmalat, não estatutário, e como tal não participava, direta ou indiretamente, das negociações ou decisões estratégicas da companhia.

32. Confirmou ter tido conhecimento da operação entre LAEP e GEM no dia 14.1.2010, alegando, dessa forma, que em seus negócios com MILK11 não houve a utilização de informações privilegiadas.

Tarcísio Duque

33. Conforme informou a LAEP, às fls. 18-23, Tarcísio Duque soube das negociações com o GEM em 14.1.2010.

Tabela 5: Negócios de Tarcísio Duque com MILK11, entre 26.3.2009 a 19.03.2010.

Data	Vendas	Valor	Nº
11.1.2010	150.000	450.000,0	1
13.1.2010	300.000	657.000,0	41
Total	450.000	1.107.000	42

34. Em sua resposta, à fl. 918, ele afirmou que exercia, à época, o cargo de Diretor Industrial da Parmalat, não estatutário, e como tal não participava, direta ou indiretamente, das negociações ou decisões estratégicas da companhia.

35. Confirmou ter tido conhecimento da operação entre LAEP e GEM no dia 14.1.2010, alegando, dessa forma, que em seus negócios com MILK11 não houve a utilização de informações privilegiadas.

Othniel Lopes.

36. Conforme informou a LAEP, às fls. 18-23, Othniel Lopes soube das negociações com o GEM em 9.12.2009.

Tabela 6: Negócios de Othniel Lopes com MILK11, entre 26.3.2009 a 19.03.2010.

Data	Vendas	Valor (R\$)	Nº
8.5.2009	500.000	200.000,00	50
13.1.2010	400.000	897.800,00	59
15.1.2010	2.300.000 (*)	5.770.694,0 (*)	273
18.1.2010	400.000	1.020.468,0	55
20.1.2010	350.000	927.500,00	2
Total	3.950.000	8.816.462,0	439

(*) BDRs alienadas para empréstimo dos recursos para a LAEP, como será visto adiante.

37. Em sua resposta, às fls. 597-600, ele disse ter recebido, em 2009, como bônus, quatro milhões de BDRs da LAEP, em conformidade com o Programa de Incentivo de Compra de Ações ("SIP") da Companhia.

38. Anexou à resposta o seu Plano Individual de Investimento, datado de 25.9.2009, pelo qual poderia adquirir ou alienar até 1.200.000 BDRs por mês (fls. 622-625), juntando também a Política de Negociação de Ações de Emissão Própria e Política de Divulgação de Informações Relevantes e Preservação de Sigilo ("Política de Negociação") da LAEP (fls. 602-614), que, segundo defendeu, permitia, na pendência de fato relevante, a negociação de valores mobiliários por pessoas vinculadas que tivessem Plano Individual de Investimento aprovados pela Companhia, bem como trazia a possibilidade de exceção ao período de vedação de negociação, desde que autorizada pela diretoria.

39. Othniel Lopes destacou a autorização dada pelo Conselho de Administração da LAEP, em 14.1.2010, para a alienação de suas BDRs. Nesta reunião, da qual participaram, dos aqui investigados, ele e Rodrigo Ferraz, foram deliberados, entre outros, os pontos abaixo, justificados pela situação financeira da Companhia e por suas obrigações contratuais, bem como pela *"necessidade urgente de pagar os credores operacionais, principalmente os pequenos produtores de leite da Sociedade"* (fls. 627-633):

a. Autorização para Othniel Lopes¹¹, Arthur Gilberto e Rodrigo Ferraz venderem todos os BDRs detidos até a data da reunião, a preços de mercado, em exceção à Política de Negociação e aos respectivos Planos Individuais de Investimento; e

b. Autorização para a assinatura de contratos de empréstimos com Othniel Lopes, Arthur Gilberto e Rodrigo Ferraz, referentes à receita obtida com a venda de seus BDRs, com a Companhia arcando com os impostos e custos relativos à operação¹².

40. Othniel Lopes acrescentou que, em 19.2.2010, AGE da LAEP ratificou as autorizações acima (fls. 635-639).

41. A autorização do conselho para a venda dos papéis fora dos limites fixados no Plano Individual de Investimento, e a posterior ratificação dos acionistas, visaram, segundo Othniel Lopes, *"tão somente, o benefício da Companhia e suas coligadas, que receberam os recursos oriundos destas negociações como empréstimos emergenciais para reforço do seu capital de giro"* (fl. 599).

42. Por fim, defendeu que a operação de venda dos BDRs observou a legislação e a regulamentação aplicáveis, tanto de Bermudas, quanto de Luxemburgo e do Brasil.

Rodrigo Ferraz.

43. Conforme informou a LAEP, às fls. 18-23, Rodrigo Ferraz soube das negociações com o GEM em 7.1.2010.

Tabela 7: Negócios de Rodrigo Ferraz com MILK11, entre 26.3.2009 a 19.03.2010.

Data	Vendas	Valor (R\$)	Nº
3.4.2009	63.500	22.860,00	8
7.4.2009	200.000	76.000,00	9
14.1.2010	1.800.000	4.977.560,0	227
Total	2.063.500	5.076.420,0	244

(*) BDRs alienadas para empréstimo dos recursos para a LAEP, como será visto adiante.

44. Sua resposta, às fls. 750-751, foi semelhante à de Othniel Lopes, nos argumentos e nos documentos anexados, às fls. 751-916, com exceção da quantidade de ações recebidas pelo SIP da LAEP, que para Rodrigo Ferraz foi de dois milhões, e da quantidade de BDRs que poderia adquirir ou alienar por seu Plano Individual de Investimento, que para ele eram de até 800.000 BDRs por mês (fls. 774-787).

45. Participou da reunião do Conselho de Administração da LAEP de 14.1.2010 e da AGE de 19.2.2010, onde foram autorizadas e ratificadas as alienações de BDRs e os empréstimos à Companhia.

Armando Buchina.

46. Conforme informou a LAEP, às fls. 18-23, Armando Buchina soube das negociações com o GEM em 14.1.2010.

Tabela 8: Negócios de Armando Buchina com MILK11, entre 26.3.2009 a 19.03.2010.

Data	Compra	Valor	Nº	Vendas	Valor	Nº
13.1.2010				150.000	330.000,0	7
15.1.2010				300.000(*)	756.000,0	10
4.2.2010	20.000	41.957,0	4			
Total	20.000	41.957,0	4	450.000	1.086.000	17

(*) BDRs alienadas para empréstimo dos recursos para a LAEP, como será visto adiante.

47. Em sua resposta, às fls. 551 a 552, ele disse ter recebido, em 5.6.2009, na qualidade de Diretor Tecnologia da Informação da Parmalat, não estatutário, 450.000 MILK11 como parte de seu prêmio de remuneração.

48. Sobre as suas operações com o papel, Armando Buchina afirmou que, antes de qualquer negociação, certificava-se da "inexistência, ao menos ao [seu] conhecimento, de operações ou fatos que não fossem de conhecimento público, nos termos da Política de

*Negociação de Valores Mobiliários da Companhia*¹³ – NPA 041, registrada junto [à CVM] em 08/11/2007”.

49. Nesse sentido, declarou só ter tido conhecimento da operação entre LAEP e GEM no dia 14.1.2010 e que, neste mesmo dia, após tomar conhecimento do negócio, suspendeu qualquer negociação com MILK11, tendo efetuado novas negociações somente após a divulgação do fato relevante pela LAEP, em 15.1.2010¹⁴.

50. Alegou, também, que, antes de operar, apresentou à Companhia um Plano Individual de Investimento (fls. 553-555), datado de 6.11.2009, pelo qual poderia adquirir ou alienar 300.000 BDRs por mês, afirmando que “[t]odas as negociações efetuadas com este ativo atenderam os limites estabelecidos neste Plano de Investimentos”, ressaltando como exceção *“aquelas operações realizadas estritamente para empréstimo dos recursos à LAEP e Parmalat, em vista da delicada situação financeira das empresas à época”*, que teriam sido aprovadas e ratificadas por AGE da LAEP realizada em 19.2.2010.

Arthur Gilberto.

51. Conforme informou a LAEP, às fls. 18-23, Arthur Gilberto soube das negociações com o GEM em 14.1.2010.

Tabela 9: Negócios de Arthur Gilberto com MILK11, entre 26.3.2009 a 19.03.2010.

Data	Vendas	Valor (R\$)	Nº
14.1.201	800.000 ^(*)	2.185.884, ^(*)	76
Total	800.000	2.185.884,	76

(*) BDRs alienadas para empréstimo dos recursos para a LAEP, como será visto adiante.

52. Em sua resposta, às fls. 561 a 562, ele disse que as 800.000 BDRs alienadas foram recebidas integralmente como bônus em 2009, dentro do SIP da Companhia, e que a alienação teria tido a aprovação do Conselho de Administração em 14.1.2010, em deliberação ratificada pela AGE, em 19.2.2010.

53. Além disso, segundo Arthur Gilberto, a operação teria observado a legislação e a regulamentação aplicáveis, tanto de Bermudas, onde *“o Conselho de Administração é o principal órgão de administração, responsável pela grande maioria das decisões”*, quanto de Luxemburgo e do Brasil.

54. Arthur Gilberto defendeu que a autorização do Conselho de Administração da LAEP para a venda dos papéis, e a ratificação pela AGE, visaram, *“tão somente, ao benefício da Companhia e suas coligadas, que receberam os recursos oriundos destas negociações como empréstimos emergenciais para reforço do seu capital de giro”* (fl. 562).

55. Não confirmou a informação dada pela LAEP, às fls. 18-23, de que teria tido conhecimento da operação com o GEM em 14.1.2010.

Rodrigo Hoffmann.

56. Seu nome não constava da relação de pessoas que tiveram conhecimento prévio da operação com o GEM, enviada pela LAEP às fls. 18-23, mas aparece na ata da AGE de 19.2.2010, às fls. 565-569, como um dos autorizados, retroativamente, a vender BDRs e a emprestar os recursos à Companhia.¹⁵

Tabela 10: Negócios de Rodrigo Hoffmann com MILK11, entre 26.3.2009 a 19.03.2010.

Data	Vendas	Valor	Nº
8.1.2010	200.000 ^(*)	531.600,00 ^(*)	4
Total	200.000	531.600,00	4

(*) BDRs alienadas para empréstimo dos recursos para a LAEP, como será visto adiante.

57. Em sua resposta, às fls. 1178-1179, afirmou que recebeu os BDRs como bônus, no âmbito do SIP da Companhia, e que a operação de venda dos papéis observou a legislação e a regulamentação aplicáveis, tanto de Bermudas, quanto de Luxemburgo e do Brasil. Também alegou que, em 19.2.2010, AGE da Companhia ratificou a alienação dos seus BDRs.

58. Como os demais, Rodrigo Hoffmann defendeu que a operação foi feita em benefício da Companhia e de suas coligadas, que receberam os recursos oriundos das negociações na forma de empréstimos emergenciais para reforçar seu capital de giro.

Manifestação da LAEP.

59. Em vista das alegações e informações relatadas acima, a SMI solicitou à LAEP esclarecimentos sobre a autorização dada pelo seu Conselho de Administração para que alguns diretores alienassem BDRs e emprestassem os recursos para a Companhia, solicitando também os contratos e outros documentos que teriam formalizado essas operações (fls. 924-925)¹⁶.

60. Em sua resposta, às fls. 927 a 933, acompanhada dos documentos de fls. 934-1175, a LAEP apresentou, primeiramente, uma contextualização da situação vivida por ela à época da realização dos empréstimos junto a seus diretores.

61. Segundo o seu relato, a Companhia, no início de 2010, enfrentava aguda crise de crédito, causada pela crise financeira mundial iniciada em 2008, que fez com que as grandes instituições financeiras restringissem a concessão de financiamento, e pela crise havida no setor lácteo nacional em 2008 e 2009, decorrente de alegadas práticas desleais de competidores.

62. Esses problemas, tendo atingido empresas sólidas e tradicionais, tiveram maior efeito sobre aquelas de menor porte, como a LAEP, que, além de tudo, possuía uma de suas controladas (a Parmalat) em recuperação judicial. Para comprovar este quadro, a Companhia anexou notícias publicadas no segundo semestre de 2008, com matérias sobre as dificuldades enfrentadas pelo setor de laticínios (fls. 1161-1175).

63. As dificuldades de financiamento teriam obrigado a Companhia *"a recorrer a instituições de fomento e factoring para se financiar, inclusive com o desconto da integralidade de seus recebíveis, com o grave aumento de suas despesas financeiras"*. Estes recebíveis eram oriundos, principalmente, da venda de produtos lácteos industrializados, tornando-se então fundamental, segundo aduziu a Companhia, a continuidade dos pagamentos aos fornecedores de leite *in natura*, para manter as suas atividades.

64. Estes eventos teriam feito com que, em janeiro de 2010, a LAEP se encontrasse atrasada em seus pagamentos a milhares de produtores e algumas cooperativas. Além disso, enfrentava o risco de intervenção na planta de Itaperuna por parte do Governo do

Estado do Rio de Janeiro bem como o bloqueio das atividades da planta de Santa Helena/GO por parte de movimentos sociais.

65. Para comprovar esta situação, a Companhia anexou os seguintes documentos:

a. DVD contendo matéria do programa Globo Rural sobre protesto de produtores de Goiás em frente à fábrica da Parmalat (sem data) (fl. 1080);

b. Notícias publicadas entre os dias 8.12.2009 e 20.1.2010, sobre as dificuldades de pagamento da Parmalat a produtores de Goiás e Rio de Janeiro, em especial informando o acampamento de produtores em frente à fábrica de Santa Helena/GO, com bloqueio de entrada e saída de produtos, em 13 e 14.1.2010, e noticiando notificação extrajudicial de 15.1.2010 do Governo do Estado do Rio de Janeiro, para pagamento de dívidas com produtores do estado, bem como a iminência de interdição da fábrica de Itaperuna, caso não seja feito o referido pagamento (fls. 1082-1109);

c. Quadro de dívidas da LAEP com produtores e cooperativas, consolidado por região, em 14.1.2010 (fl. 1042); e

d. Ofício enviado à Parmalat, em 15.1.2010, pela Secretaria Estadual, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Governo do Estado do Rio de Janeiro ("Secretaria Estadual"), cobrando a regularização, no prazo de cinco dias, das obrigações pendentes com produtores, sob pena de intervenção na fábrica de Itaperuna, e resposta da Parmalat (sem data) informando a quitação de 100% dos atrasos de pagamentos com produtores, num total de R\$3.370.000,00, e que o próximo vencimento de dívida seria no dia 20.1.10, num valor aproximado de R\$4 milhões (fls. 935-938).

66. Assim, afirmou a LAEP que, *"como única forma de evitar a paralisação de suas atividades e consequente bancarrota, solicitou a alguns de seus principais colaboradores que alienassem os BDRs de sua titularidade, recebidos ao longo de 2008 e 2009 como bônus (dentro do Stock Incentive Plan – SIP), em conformidade com a política de remuneração da Companhia, e emprestassem à Companhia a integralidade das quantias resultantes daquelas alienações"* (fl. 929).

67. Estas alienações, de acordo com a Companhia, teriam sido feitas em perfeita conformidade com sua Política de Negociação, arquivada na CVM em 8.11.2007 (fls. 940-958), e com a legislação de Bermudas, onde está sediada. Nos casos em que a quantidade de BDRs alienados foi superior à prevista nos Planos Individuais de Investimento, a LAEP alegou que o aumento de limite foi expressamente autorizado por deliberação de sua Diretoria em 14.1.2010, sem o voto dos interessados.

68. A reunião da Diretoria do dia 14.1.2010 está registrada no documento em inglês, intitulado *Officers Meeting*, às fls. 1016, onde está consignado que, na presença de todos os diretores da LAEP, bem como dos principais diretores das sociedades ligadas, o Diretor-Presidente, M. A. E., informou que, em vista da situação financeira da Companhia, esta necessita solicitar a alguns diretores e executivos que vendam os BDRs que receberam no âmbito do plano de remuneração (SIP) e emprestem os recursos à Companhia, para pagamento de fornecedores de leite da Parmalat.

69. Dessa forma, foi autorizada (i) a exceção aos Programas Individuais de Investimento arquivados na Companhia em 2009 e à Política de Negociação, nos termos de sua Cláusula 34¹⁷ e (ii) a alienação por alguns diretores e executivos, em especial Othniel Lopes, Arthur Gilberto e Rodrigo Ferraz, da totalidade das BDRs que receberam no

SIP¹⁸. Othniel Lopes e Rodrigo Ferraz, que integravam a Diretoria, se abstiveram de votar, pois estavam entre os que iriam vender BDRs e emprestar recursos para a Companhia.

70. A ata também registra que, considerando a urgência e a particularidade das decisões tomadas, estas deveriam ser rapidamente ratificadas pelo Conselho de Administração e submetidas à deliberação da Assembleia de Acionistas, o que ocorreu no mesmo dia 14.1.2010, para a aprovação do conselho, e em 19.2.2010, para a ratificação da AGE, conforme já relatado nos Itens 40 e 41 retro.

71. A LAEP apontou como vantagem dos empréstimos feitos junto aos diretores o fato de eles terem sido *"remunerados com taxas de CDI + 0,5% ao mês, muito inferiores às de mercado, e muitíssimo mais benéficas que as naquele momento praticadas pelas únicas fontes de financiamento da Companhia, que eram as empresas de factoring e fomento mercantil (e que haviam manifestado recusa à extensão de linhas de crédito na oportunidade)"*. Ademais, na impossibilidade de honrar o compromisso no prazo acordado, a companhia efetuou o pagamento de forma parcelada, quitando os valores devidos somente no início de julho de 2010.

72. Aduziu, também, que os empréstimos foram fundamentais para a continuidade das atividades empresariais e para a recuperação da Companhia, em conjunto com outras medidas implementadas à época – contratos com o GEM e a Monteciano, conversão de dívida em capital, fechamento do capital da Parmalat e arrendamento da Unidade Santa Helena.

73. Nesse sentido, anexou um email enviado à Secretaria Estadual, em 18.1.2010, pela Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio de Janeiro, agradecendo ao Governo do Estado por ter autorizado o início do processo de intervenção judicial na Parmalat e informando não ser mais necessário tal procedimento em razão do pagamento pelo fornecimento de leite em atraso (fls. 1158-1159).

74. Os empréstimos com as pessoas ligadas totalizaram, segundo a LAEP, cerca de R\$14 milhões, ou 42% das dívidas de curto prazo com produtores e cooperativas em 14.1.2010, relacionadas à fl. 1042, que totalizavam R\$33.003.658,36.

75. A LAEP confirmou que as pessoas autorizadas a negociar os BDRs foram Othniel Lopes, Rodrigo Ferraz, Armando Buchina, Arthur Gilberto e Rodrigo Hoffmann, anexando cópias dos contratos de empréstimo e dos respectivos termos de quitação (fls. 1044-1070).

76. Anexou, também, dois Termos Aditivos ao Contrato de Fomento Mercantil ("Termos Aditivos"), firmados entre a Parmalat e a BS Factoring e Fomento Comercial Ltda. ("BS Factoring"), com datas de 15.1.2010 e 18.1.2010, para antecipação dos valores a serem recebidos com a venda dos BDRs (fls. 1072-1078).

Dos contratos de empréstimo e dos Termos Aditivos (fls. 1044-1070)¹⁹.

A tabela abaixo traz a quantidade de BDRs referenciada na Cláusula 2.1 de cada contrato de mútuo, as datas de assinatura dos contratos, as datas de alienação dos papéis na bolsa e a data em que os valores deveriam ser transferidos para as mutuárias, consignadas na Cláusula 2.2, ii, dos contratos, bem como os valores brutos emprestados, que equivalem ao apurado nas alienações dos papéis na bolsa:

Tabela 11: Datas, quantidades de BDRs e valores emprestados à Companhia.

Mutuante	Nº de BDRs	Data do	Data da	Data da	Valor
----------	------------	---------	---------	---------	-------

	alienadas para o empréstimo	contrato	alienação - bolsa	transferência-contrato	emprestado - contrato
Othniel Lopes	2.300.000	14.1.2010	15.1.2010	20.1.2010	5.770.694
Rodrigo Ferraz	1.800.000	14.1.2010	14.1.2010	19.1.2010	4.997.560
Arthur Voosluys	800.000	14.1.2010	14.1.2010	19.1.2010	2.185.884
Rodrigo Hoffmann	200.000	15.1.2010	8.1.2010	21.1.2010	528.565,6
Armando Buchina	300.000 ^(*)	14.1.2010	15.1.2010	19.1.2010	756.000,0
Total					14.238.70

(*) No contrato consta 800.000, mas foi levantado pela SMI que ele alienou na bolsa 300.000 BDRs em 15.1.2010.

77. Os contratos estabeleciam, em sua Cláusula 3.1, que todos os tributos incidentes seriam recolhidos pelos mutuantes e que as mutuárias comprometiam-se a reembolsá-los dos impostos e encargos incidentes sobre a alienação dos BDRs. Dessa forma, a Cláusula 3.1.1 de cada contrato traz o valor máximo a ser retido a título de impostos, taxas de liquidação, emolumentos e corretagem (conforme um citado "Anexo I", não incluído), bem como o valor líquido resultante da subtração desta parcela retida do valor bruto.

78. Na tabela abaixo, a SMI resumiu os dados de cada contrato e termo de quitação, calculando, também, o percentual do valor total do empréstimo retido pelo Mutuante: ²⁰

Tabela 12: Dados constantes dos contratos de mútuo entre LAEP/Parmalat e pessoas ligadas

Mutuante	Data do contrato	Valor total	Valor retido	Valor líquido	Número de BDRs	Valor original Termo de Quitação	% retido
Othniel Lopes	14.1.2	5.770.69	899.000	4.872.51	2.300.	5.645.558,	15,5
Rodrigo	14.1.2	4.997.56	765.000	4.232.56	1.800.	4.997.560,	15,3
Arthur	14.1.2	2.185.88	335.006	1.850.87	800.00	2.185.884,	15,3
Rodrigo	15.1.2	528.565,	81.073,	447.492,	200.00	528.566,00	15,3
Armando	14.1.2	756.000,	115.316	644.949,	800.00	756.000,00	15,2
Total		14.238.7	2.195.3	12.048.3			

(*) O valor total de R\$756.000,00 corresponde, na verdade, às 300.000 BDRs alienadas em 15.1.2010.

79. Quanto aos Termos Aditivos firmados entre a Parmalat e a BS Factoring, o primeiro, de 15.1.2010, referia-se à antecipação dos valores líquidos emprestados por Rodrigo Ferraz e Othniel Lopes, e o outro, de 18.1.2010, à antecipação dos valores líquidos emprestados por Armando Buchina, Rodrigo Hoffmann e Arthur Gilberto (fls. 1072-1076).

III. DA ACUSAÇÃO.

80. Após análise dos fatos, alegações e documentos até aqui relatados e descritos, a SMI, às fls. 1205-1237, apresentou, em 24.2.2011, termo de acusação ("Acusação"), por meio do qual Othniel Lopes e Rodrigo Ferraz foram acusados de violação ao art. 13, *caput*, da Instrução CVM nº 358/2002, combinado com o artigo 155, §1º, da Lei nº 6.404/1976, e Armando Buchina, Arthur Gilberto, Luiz Álvaro, Nilton Muniz, Silvana Dino, Tarcísio Duque, Fabio Floh e Rodrigo Hoffmann foram acusados de violação ao art. 13, *caput*, da

Instrução CVM nº 358/2002, combinado com o artigo 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976, todos eles por terem negociado BDRs de emissão da LAEP (código MILK11), na posse de informações relevantes ainda não divulgadas ao mercado, relacionadas a fatos relevantes divulgados por LAEP e Parmalat em 15.1.2010 e 28.1.2010, nos quais se informavam, respectivamente, a capitalização da LAEP por um fundo estrangeiro e a conversão de dívida em capital.

81. O termo de acusação pediu a responsabilização dos Acusados na forma do art. 18 da Instrução CVM nº 358/02, para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76, pelos negócios realizados nas datas e nos montantes listados a seguir:

Tabela 14: Armando Buchina – Negócios com MILK11

Data	Vendas	Valor (R\$)
13.1.2010	150.000	330.000,00
15.1.2010	300.000	756.000,00
Total	450.000	1.086.000,00

Tabela 15: Arthur Gilberto – Negócios com MILK11

Data	Vendas	Valor (R\$)
14.1.2010	800.000	2.185.884,0
Total	800.000	2.185.884,0

Tabela 16: Fabio Floh – Negócios com MILK11

Data	Vendas	Valor (R\$)
11.1.201	90.000	270.600,0
12.1.201	50.000	119.400,0
13.1.201	10.000	22.000,00
Total	150.000	412.000,0

Tabela 17: Luis Álvaro – Negócios com MILK11

Data	Vendas	Valor (R\$)
8.1.2010	91.500	320.250,00
13.1.2010	50.000	127.500,00
28.1.2010	150.000	382.000,00
Total	291.500	829.750,00

Tabela 18: Nilton Muniz – Negócios com MILK11

Data	Vendas	Valor (R\$)
13.1.2010	650.000	1.450.000,00
Total	650.000	1.450.000,00

Tabela 19: Othniel Lopes – Negócios com MILK11

Data	Vendas	Valor (R\$)
13.1.2010	400.000	897.800,00
15.1.2010	2.300.00	5.770.694,00
18.1.2010	400.000	1.020.468,00
20.1.2010	350.000	927.500,00
Total	3.450.00	8.616.462,00

Tabela 20: Rodrigo Ferraz – Negócios com MILK11

Data	Vendas	Valor (R\$)
14.1.2010	1.800.00	4.977.560,0
Total	1.800.00	4.977.560,0

Tabela 21: Silvana Dino – Negócios com MILK11

Data	Vendas	Valor (R\$)
13.1.2010	250.000	540.500,00
Total	250.000	540.500,00

Tabela 22: Tarcísio Duque – Negócios com MILK11

Data	Vendas	Valor
11.1.2010	150.000	450.000,0
13.1.2010	300.000	657.000,0
Total	450.000	1.107.000

Tabela 23: Rodrigo Hoffmann – Negócios com MILK11

Data	Vendas	Valor
8.1.2010	200.000	531.600,00
Total	200.000	531.600,00

82. Todos os Acusados alienaram quantidades significativas de BDRs da LAEP entre os dias 8.1 e 14.1.2010 e, em 15.1 a Companhia divulgou fato relevante (fl. 7) a respeito de capitalização a ser feita por investidor institucional estrangeiro. Segundo a Acusação, da forma como esta operação foi estruturada, *"entre outras consequências, ocorreria uma diluição do capital da Laep, pela emissão de novas ações em favor de um investidor externo"* (fl. 1265).

83. Três dos Acusados ainda venderam quantidades significativas de BDRs nos pregões seguintes (Armando Buchina em 15.1, Othniel Lopes em 15, 18 e 20.1 e Luiz Álvaro em 28.1), sendo que nesta última data, 28.1, foi divulgado outro fato relevante (fl. 11) que, de acordo com a Acusação *"acenou com nova diluição de capital, pela conversão de dívida em novas ações."*

84. No entender da Acusação, “[e]ssas vendas realizadas [pelos Acusados] às vésperas da divulgação de fatos relevantes que comunicavam perda de valor das ações apresentam indício característico da atuação na posse de informação privilegiada” (fl. 1265).

85. A Acusação dividiu os Acusados em dois grupos, segundo as justificativas que apresentaram para as suas operações:

a. Othniel Lopes, Rodrigo Ferraz, Armando Buchina, Arthur Gilberto e Rodrigo Hoffmann, que alegaram que foram autorizados pelo Conselho de Administração da LAEP, em ato posteriormente ratificado em AGE²¹, para que alienassem BDRs em exceção aos Planos Individuais de Investimento e emprestassem os valores para a Companhia, com a finalidade de levantar recursos emergenciais para pagamento de fornecedores; e

b. Fabio Floh, Luis Álvaro, Nilton Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque, que afirmaram terem negociado suas BDRs sem conhecimento do fato relevante de 15.1.2010.

Da acusação contra Othniel Lopes, Rodrigo Ferraz, Armando Buchina, Arthur Gilberto e Rodrigo Hoffmann.

86. Deste primeiro grupo de Acusados, Othniel Lopes e Rodrigo Ferraz, conforme informado pela LAEP à fl. 22, tomaram conhecimento das tratativas com o GEM bem antes das respectivas alienações de BDRs (Othniel em 9.12.2009 e Rodrigo Ferraz em 7.1.2010). Logo, para os dois, essas informações, segundo a Acusação, “[são] suficiente[s] para caracterizar a infração ao art. 13 da Instrução CVM nº 358/02”.

87. Da mesma forma, Arthur Gilberto também vendeu seus BDRs de posse da informação relevante ainda não divulgada, já que foi informado da operação em 14.1.2010, por volta das 11h:00min, em reunião na sede da Companhia, e, conforme apurou a SMI, iniciou suas vendas no mesmo dia, às 15h:00min (fl. 1.266).

88. Quanto a Armando Buchina e Rodrigo Hoffmann (e, nesse ponto, também quanto a Fabio Floh, Luis Álvaro, Nilton Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque), não havendo afirmação expressa de que sabiam do fato relevante divulgado em 15.1.2010 antes do dia 14.1, a Acusação, para formar sua convicção, contestou os argumentos apresentados para justificar as suas operações, conforme exposto a seguir, e apurou indícios adicionais de que eles teriam conhecimento prévio da operação com o GEM.

89. Assim, o argumento de que havia uma necessidade emergencial para a alienação de seus BDR não foi aceito pela Acusação, aduzindo para isto que uma das justificativas apresentada à AGE de 19.2.2010 para a realização dos empréstimos foi uma notificação da Secretaria Estadual datada de 15.1 a respeito da iminente intervenção na fábrica de Itaperuna.

90. Ocorre que a data da notificação é do dia posterior à reunião do Conselho de Administração que autorizou as alienações e empréstimos de BDRs, e, portanto, não seria conhecida ainda, e, além disso, dava um prazo de cinco dias para o pagamento, ou apresentação de um cronograma de pagamentos, o que tiraria seu caráter emergencial (fls. 935-938).

91. Segundo a Acusação, este fato enfraquece o argumento de que as alienações foram feitas a pedido da LAEP com o único intuito de levantar recursos emergenciais para a Companhia.

92. A Acusação refutou também a alegação de que teria havido autorização para a alienação dos BDRS, para levantar recursos para empréstimo à LAEP, afirmando que a Instrução CVM n.º 358/02 não contempla qualquer exceção às vedações à negociação visando ao melhor interesse da Companhia.

93. Segundo os Acusados, a administração da LAEP aprovou exceções à Política de Negociação da Companhia e aos seus Planos Individuais de Investimento e autorizou a alienação de seus papéis, em atos ratificados posteriormente por AGE, tudo com o objetivo de levantar recursos para um empréstimo emergencial à Companhia.

94. Porém, segundo a Acusação, o art. 15 da Instrução CVM nº 358/2002, que trata da Política de Negociação de ações, *"não contempla qualquer exceção às vedações à negociação, visando ao melhor interesse da companhia"*, acrescentando que o §1º do art. 15 da Instrução CVM nº 358/2002 estabelece que *"a política de negociação [...] não poderá ser aprovada ou alterada na pendência de ato ou fato relevante ainda não divulgado"* (fl. 1266).

95. Prosseguindo, a Acusação aponta que só seria admitida a negociação por pessoa ligada, em período vedado, quando se tratar de aquisição de ações no período de 15 dias que anteceder a divulgação de ITR e DFP, e quando a companhia tiver aprovado cronograma com datas específicas para divulgação das informações e o plano individual estabeleça o compromisso irrevogável e irretratável de seus participantes de investir valores preestabelecidos em datas determinadas.²² Este, segundo a Acusação, *"não é o caso dos planos apresentados, que conferem aos participantes a **opção de negociar** (comprar ou vender) um limite mensal de títulos"*²³ (fls. 1268) (grifo no original).

96. A Acusação também apontou que, ao contrário do que os Acusados alegam, não foi respeitada a Política de Negociação da LAEP, em suas cláusulas 4-r e 15 a 17 (fls. 1268-1269):

"15. É vedada a negociação com Valores Mobiliários pelas Pessoas Vinculadas nas seguintes hipóteses: (i) se estiver em curso processo de aquisição ou venda de ações de emissão de qualquer empresa do Grupo."

"16. As vedações para negociação com Valores Mobiliários devem ser observadas pelas Pessoas Vinculadas até a divulgação do Fato Relevante ao público. (...)".

"17. Mesmo após sua divulgação ao público, o Fato Relevante deve continuar a ser tratado como não tendo sido divulgado até que tenha decorrido Prazo Razoável para que os participantes do mercado o tenham recebido e processado o Fato Relevante".

"4. r) Prazo Razoável – Significa os seguintes prazos: (ii) em relação às demais hipóteses de divulgação de Fato Relevante [Nota: o item (i) trata das ITR, DFP e IAN], quando tiverem decorrido 2 (dois) Dias de Pregão, contados do dia de divulgação do Fato Relevante, inclusive."

97. Dessa forma, argumentou a Acusação que, na medida em que o acordo com o GEM previu a emissão de novas ações em favor do fundo investidor, em contrapartida aos seus aportes de capital, haveria, segundo a Cláusula 15 da Política de Negociação da LAEP, vedação às alienações realizadas pelos Acusados, pois a emissão de ações pode ser interpretada como venda de ações da Companhia (fls. 1269).

98. Além disso, o Prazo Razoável de dois dias para o fim da vedação (Cláusula 4.ª acima), no que se refere ao fato relevante de 15.1.2010, se estenderia até 18.1, e que, dessa forma, as vendas de Armando Buchina em 15.1 e Othniel Lopes em 15 e 18.1 também estariam em desacordo com a Política de Negociação.

99. O termo de acusação também rebate outro argumento apresentado pelos Acusados, o de que as alienações respeitaram os Planos Individuais de Investimento, dos quais só foram disponibilizados os de Rodrigo Ferraz, Othniel Lopes, Armando Buchina e Fabio Floh.

100. Assim, apontou que Rodrigo Ferraz podia negociar até 800.000 BDRs e vendeu 1.800.000, Othniel Lopes era limitado a negociar 1.200.000 e alienou 3.450.000 e Armando Buchina podia negociar 300.000 e vendeu 450.000 em janeiro.

101. Apontou, também, a Acusação, que Armando Buchina e Othniel Rodrigues Lopes não se limitaram, em janeiro de 2010, a alienar os papéis destinados ao empréstimo à LAEP, tendo o primeiro vendido 450.000 BDRs, com 300.000 destinados ao empréstimo, e o segundo alienado 3.450.000, dos quais somente 2.300.000 foram para o empréstimo.

102. O único que respeitou a quantidade máxima a ser negociada prevista no Plano foi Fabio Floh, que podia alienar até 150.000 BDRs/mês. Não respeitou, porém a determinação de manter qualquer título adquirido pelo prazo de 90 dias antes de nova negociação, executando *day-trades* em 18 e 19.2.2010 com um total de 50.000 BDRs.

103. A Acusação também identificou várias inconsistências na documentação referente aos empréstimos feitos pelos Acusados para a LAEP/Parmalat.

104. Assim, apontou, por exemplo, conforme Tabela 11 retro, que o valor líquido do empréstimo, equivalente ao valor total emprestado menos o valor retido para impostos, deveria ser de R\$4.871.694,00 para Othniel Lopes (diferença de R\$820,35 em relação ao constante do contrato), e R\$640.683,64 para Armando Buchina (diferença de R\$4.266,31).

105. No contrato de Othniel Lopes também foi apontada outra inconsistência, pois o "valor original" constante do Termo de Quitação tinha uma diferença a menor de R\$125.136,00 com o "valor total do empréstimo" apresentado no quadro preambular do contrato.

106. Já em relação ao número de BDRs a serem pagos pela companhia, a SMI observou que, no caso de Armando Buchina, caso este tivesse optado por receber o pagamento em títulos (o que não ocorreu, segundo o respectivo Termo de Quitação), constava do contrato a quantidade de 800.000 BDRs, embora o valor emprestado, R\$756.000,00, correspondesse às 300.000 BDRs por ele alienadas em 15.1.2010.²⁴

107. No caso de Rodrigo Hoffmann, a Acusação destacou o fato de o Conselho de Administração da Companhia ter autorizado as alienações dos papéis para o empréstimo em 14.1.2010, sendo que ele já havia alienado, em 8.1.2010, os BDRs objeto dessa autorização.

108. Uma inconsistência que a SMI considerou grave foi o fato de os contratos de Othniel Lopes e de Armando Buchina estarem datados de 14.1.10 e as alienações de BDRs que coincidem com os valores consignados nos contratos terem sido realizadas somente em 15.1, ou seja, *"não seria possível prever o valor exato de venda dos BDRs com um dia de antecedência, diante da alta volatilidade apresentada pelo BDR MILK11 à época"*.

109. Outro ponto levantado pela SMI foi a assunção, pela Companhia, dos impostos incidentes sobre a operação de venda dos BDRs, efetivada na retenção, pelos mutuantes, dos percentuais mostrados na Tabela 10 supra, ligeiramente superior a 15%. Segundo a Acusação, *"esta seria a alíquota do imposto de renda sobre a venda, considerando o custo de aquisição dos BDRs igual a zero (foram recebidos através do plano de incentivo)"*. Assim, tendo a LAEP pago o valor total do empréstimo corrigido, e não o valor líquido, concluiu a SMI que *"os mutuantes, ao final, receberam o equivalente ao valor bruto das alienações, tendo ocorrido a transferência dos encargos de imposto de renda (além das despesas operacionais) para a Companhia"* (fl. 1264).

Da acusação contra Fabio Floh, Luis Álvaro, Nilton Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque.

110. Para esse grupo de acusados, o termo de acusação afirma, inicialmente, não haver, *"dentro das limitações da investigação conduzida, como obter evidência direta, cabal e definitiva a respeito do uso privilegiado da informação"*, mas que este tipo de ilícito poder ser provado por meio de uma *"avaliação global e unitária de diversos indícios graves e válidos"*, que levaria à assim denominada prova indiciária, de ampla aceitação na jurisprudência (fls. 1269).²⁵

111. Dessa forma, a Acusação elenca os seguintes indícios de uso de informação privilegiada pelos Acusados:

- a. Pela forma como foi estruturada, com emissão de novas ações em favor do investidor externo, cuja subscrição se daria a um preço inferior ao do mercado, a operação de capitalização implicaria uma diluição dos acionistas da LAEP, o que levaria a uma queda na cotação dos BDRs;
- b. O fato de dez diretores ligados à companhia (incluindo-se os que fizeram os empréstimos à LAEP) terem vendido quantidades significativas de BDRs entre os dias 08 e 14.1 *"sugere que a informação sobre a iminente diluição de capital se disseminou entre os administradores às vésperas da divulgação do fato relevante em 15/01, seguido, em 28/01, por outro Fato Relevante, que comunicou a conversão de dívidas em ações, implicando nova diluição de capital"* (fl. 1270);
- c. O *"patente"* oportunismo nas vendas dos BDRs, bastando se observar o comportamento da cotação do título, *"que interrompeu uma trajetória de forte alta depois da divulgação do fato de 15/01 e entrou em queda consistente com a divulgação do fato após o pregão de 28/01"*, não tendo mais sido igualada a cotação de fechamento de 14.1.2010;²⁶
- d. O fato de que, dos dez acusados, somente Luiz Álvaro, Othniel Lopes e Rodrigo Ferraz já haviam realizado algum negócio com MILK11 desde 26.3.2010 e que, ainda assim, foram vendas realizadas em poucos pregões isolados e envolvendo quantidades significativamente menores que as operadas durante o mês de janeiro, o que *"demonstra a atipicidade dos negócios realizados em janeiro/2010"*; e
- e. A coincidência quase perfeita entre os Acusados que operaram e os que foram convocados à sede da companhia às 11:00 de 14.1.2010 para serem comunicados do acordo com o GEM, quando apenas Rodrigo Hoffmann não compareceu. Todos os participantes da reunião negociaram BDRs nos dias que antecederam a divulgação do fato relevante, o que é *"um indício de que o assunto em pauta tenha circulado antes entre os participantes"*.

112. A Acusação também procurou refutar eventuais contra-argumentações aos pontos levantados acima. Assim, o fato de que vários dos Acusados eram diretores da Parmalat, e não da LAEP, não seria obstáculo ao trânsito de informações entre eles, já que *"há ao menos um elemento de ligação"*, que seria Othniel Lopes, à época dos fatos presidente da Parmalat e membro do Conselho de Administração da LAEP, e um dos primeiros a tomar conhecimento (junto com o presidente da LAEP, M. A. E.) da proposta de acordo com o GEM.

113. Além disso, quando se afirma que *"em 14 de janeiro, a Diretoria e pessoal relacionado à gestão da Companhia, por volta das 11:00, foram chamados, na própria sede da Companhia por Othniel Rodrigues Lopes e Rodrigo Ferraz P. da Cunha para a apresentação das linhas gerais da operação"* (fl.20), o termo de acusação afirma ser pouco provável que tal reunião tenha se dado na sede da LAEP em Bermudas, tendo em vista que todos os diretores constam na rede Serpro como residentes no Brasil. Também o fato de a sede da Parmalat, onde ocorreu a referida reunião do dia 14.1.2010, ser no mesmo endereço que constava, no IAN da LAEP, como sendo seu Departamento de Acionistas, *"demonstra não haver uma separação clara entre as administrações das duas pessoas jurídicas, favorecendo o argumento de que a informação relevante circulou previamente entre os envolvidos"* (fls. 1271).

114. Assim, aduziu a Acusação que ainda que o fato relevante realmente corresse em sigilo para a maior parte dos Acusados, a LAEP *"falhou em manter mecanismos que permitissem a essas pessoas vinculadas terem conhecimento de que se achavam em período vedado à negociação"*, tanto que ao menos dois acusados, Fabio Floh e Armando Buchina, asseveraram ter-se certificado da inexistência de fato relevante não divulgado antes de alienarem seus BDRs.

115. A Acusação considerou como agravante da conduta relatada até aqui o fato de que tanto a LAEP quanto a Parmalat não apresentavam há muito tempo o relatório de negociação de partes relacionadas na forma prevista no Artigo 11 da Instrução CVM nº 358/02²⁷.

116. Por fim, observou a SMI que os Acusados, embora inquiridos a respeito, limitaram-se a justificar suas operações em relação ao fato relevante de 15.1.2010, não fazendo nenhuma referência aos de 28.1 e 14.3. Assim, tendo em vista que o fato relevante de 28.1 também implicava uma diluição do capital, a Acusação considerou que as alienações realizadas entre os dois fatos relevantes, no período de 15.1 a 28.1.2010, também foram feitas de posse de informação privilegiada (fl. 1271).

IV. DA MANIFESTAÇÃO DA PFE.

117. Em 24.3.2011, a Procuradoria Geral Especializada – PFE, às fls. 1240-1242,²⁸ entendeu que a peça acusatória preenchia os requisitos constantes dos artigos 6º e 11 da Deliberação CVM nº 538/2008 (fls. 1240-1242).

118. Contudo, a PFE manifestou-se no sentido de que o §1º do art. 155 da Lei nº 6.404/1976 tem como destinatários os administradores de companhias abertas nacionais, e não de companhias estrangeiras emissoras de BDRs, e que, portanto, a Othniel Lopes e Rodrigo Ferraz também deveria ser imputada a infração ao §4º daquele dispositivo, que é direcionado a qualquer pessoa que tenha em seu poder uma informação privilegiada.

119. A PFE também apontou que, nos termos do art. 10 da Deliberação CVM nº 538/2008, deveria ser expedida uma comunicação ao Ministério Público Federal do Estado de São Paulo, por ter-se verificado indícios da ocorrência do crime previsto no art. 27-D da Lei nº 6.385/1976.

120. Dessa forma, em 31.3.2011, a SMI, às fls. 1244-1276, alterou o termo de acusação, pedindo a responsabilização de todos os relacionados (em conjunto, "Acusados"), por violação ao art. 13, *caput*, da Instrução CVM nº 358/2002, combinado com o artigo 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976, propondo, também, que fosse oficiado o Ministério Público Federal, o que foi feito por meio do Ofício/CVM/SGE/Nº 35/2011, enviado em 16.5.2011 (fl. 2495).

V. DAS DEFESAS

5.1. OTHNIEL LOPES, ARMANDO BUCHINA, RODRIGO FERRAZ E ARTHUR GILBERTO

121. Othniel Lopes e Armando Buchina apresentaram, conjuntamente, defesa tempestiva em 22.8.2011 (fls. 1405-1470), e, na mesma data, também tempestivamente, apresentaram defesa conjunta Rodrigo Ferraz e Arthur Gilberto (fls. 1957-2027).

122. Como as defesas trouxeram muitos argumentos em comum, elas vão ser relatadas nesta mesma seção, diferenciando-se quando necessário.

5.1.1. DA PRESCRIÇÃO

123. Tanto Rodrigo Ferraz e Arthur Gilberto, em petição protocolada em 25.11.2015, de fls. 2490-2494, quanto Othniel Lopes e Armando Buchina, em petição protocolada em 8.12.2015, alegaram ter ocorrido a prescrição intercorrente do processo, nos termos do § 1º do art. 1º da Lei nº 9.873/1999.²⁹

124. Segundo afirmaram, o último dos acusados a apresentar nova proposta de termo de compromisso o teria feito em 25.9.2012³⁰ e somente em 20.10.2015 o Colegiado teria rejeitado esse e os outros pedidos de reconsideração anteriormente apresentados (fls. 2477-2478).

125. Assim, o processo teria ficado por mais de três anos pendente de julgamento ou despacho e sem qualquer ato que pudesse ser caracterizado como impulso processual suficiente para interromper o prazo prescricional.

126. Acrescentaram Othniel Lopes e Armando Buchina que, no seu entendimento, atos internos da CVM, tais como redistribuição de relatoria, não interromperiam o prazo de prescrição, por não trazerem inovação aos autos processuais. Da mesma maneira, defenderam que a análise pelo Colegiado da conveniência e oportunidade da celebração de termos de compromisso não suspenderia o prazo prescricional.

5.1.2. DA CRISE FINANCEIRA DA LAEP

127. Os BDRs objeto das operações tratadas no presente processo foram recebidos, pelos defendentes, no âmbito do Programa de Incentivo de Compra de Ações ("SIP") da LAEP, às fls. 1472 a 1486. De acordo com este documento, Othniel Lopes recebeu, em 5.6.2009, 2.000.000 de BDRs, Rodrigo Ferraz, 1.000.000, Arthur Gilberto, 800.000, e Armando Buchina, 450.000 BDRs (fls. 1472 a 1486)³¹.

128. Os defendentes apresentaram extenso relato da crise financeira que, a partir de 2008, teria atingido a LAEP e a Parmalat e as levado, em janeiro de 2010, a um quadro pré-falimentar, quadro este que estaria por trás dos empréstimos dos recursos obtidos de alienações de BDRs.

129. Em maio de 2006, por meio de sua controlada Lácteos, a LAEP adquiriu o controle social da Parmalat, já então em recuperação judicial, tendo realizado, em novembro de 2007, oferta pública de distribuição de BDRs, pela qual foram captados cerca de R\$507 milhões (fls. 1965-1966, 2045).

130. Após receber este aporte de capital, a Companhia adotou uma estratégia de integração da cadeia produtiva do leite e de consolidação do setor lácteo brasileiro, tendo, para isso, adquirido ativos como, por exemplo, os que foram objeto dos fatos relevantes divulgados em 6.11.2007 e 18.1.2008 (fls. 2047-2048).

131. Porém, na mesma época, *"a Companhia passou a ser pressionada"*, segundo Rodrigo Ferraz e Arthur Gilberto, *"pelo substancial aumento dos preços pagos aos produtores de leite, pelo preços predatórios praticados por alguns competidores e pelas dificuldades enfrentadas no processo de recuperação judicial da Parmalat"* (fl. 1966).

132. Ademais, a concorrência desleal sofrida pela LAEP teria sido agravada, segundo Othniel Lopes e Armando Buchina, *"pela política implementada por bancos oficiais, que injetaram recursos em empresas do setor e que não contemplaram a Companhia em razão da situação em sua controlada Parmalat se encontrava"* (fl. 1415).

133. O quadro acima, segundo os defendentes, teria se agravado entre agosto e setembro de 2008, quando a eclosão da crise de crédito mundial drenou a capacidade de crédito da Companhia.

134. Dessa forma, relataram que, em setembro de 2008, a LAEP abandonou a política de consolidação e crescimento que havia adotado e passou a tentar se desfazer de ativos menos estratégicos e de maior custo de produção. No entanto, devido ao fato de a Parmalat encontrar-se em Recuperação Judicial, isto só pôde ser iniciado a partir de janeiro de 2009, com a venda da unidade de Guaranhuns – PE, e, posteriormente, com a venda de outras unidades em julho de 2009 (fls. 1490-1494, 1967-1968).

135. Acrescentaram Rodrigo Ferraz e Arthur Gilberto que, entre novembro de 2008 e julho de 2009, também tiveram que ser renegociados os pagamentos de debêntures emitidas pela Parmalat, cujo pagamento havia sido suspenso, e que foram equacionados em 1.7.2009, conforme fato relevante às fls. 2071-2072.

136. Porém, mesmo com essas medidas, alegaram Othniel Lopes e Armando Buchina que a LAEP teria chegado ao fim de 2009 sem conseguir crédito em instituições financeiras de primeira linha, *"deixando a Companhia em estado pré-falimentar"* e *"diante de tamanho dilema: ou continuava produzindo e operando para pagar seus credores ou entrava com pedido de falência"* (fl. 1416).

137. Para continuar produzindo, alegaram os defendentes, era necessário, portanto, pagar os fornecedores de matéria-prima, além dos fornecedores de embalagens e transportadores, o que a Companhia só estava conseguindo, no fim de 2009, segundo relataram, por meio de empréstimos junto a empresas de fomento mercantil e *factoring*, a juros de até 4,5% ao mês.

138. Para demonstrar o quadro de insolvência financeira vivenciado pela LAEP no fim de 2009, os defendentes anexaram relatório enviado a seus acionistas por seu Presidente Executivo, Marcus Alberto Elias, datado de 21.12.2009, no qual ele comunicou que a Companhia fora compelida a se utilizar de empresas de fomento mercantil e *factoring* para desconto de títulos e de financiamento de curto prazo, a taxas de 4.5% ao mês, e informou que a administração estava tentando alienar ativos para mudar a situação (fls. 1490-1494).

139. Também nesse sentido, anexaram o Parecer dos Auditores Independentes referente às demonstrações financeiras de 21.12.2019, que apontou como fatores que ameaçavam a continuidade das operações da Companhia, os seus sucessivos prejuízos operacionais e a sua deficiência de capital de giro, bem como o fato de sua controlada Parmalat encontrar-se em recuperação judicial (fls. 1496-1497).

140. Os defendentes anexaram, também, parecer contábil-financeiro, (fls. 1499-1537, 2074-2150), que, segundo Othniel Lopes e Armando Buchina, demonstraria as "*condições de extrema dificuldade financeira e patrimonial que a Laep vinha sofrendo no final de 2009*" (fl. 1419).

141. Em janeiro de 2010, a dívida aproximada da Parmalat junto a fornecedores de leite era de aproximadamente R\$33 milhões (fl. 1042) e foi justamente essa dívida em aberto que, segundo os defendentes, levaram a que a unidade da Companhia em Itaperuna/RJ fosse objeto de iminente intervenção do Governo do Estado e a que a unidade de Santa Helena/GO fosse objeto de ordem de bloqueio judicial que levou à paralisação de suas atividades, unidades estas que representavam, em conjunto, cerca de 60% da capacidade produtiva e de faturamento da Parmalat, conforme demonstrativo de fl. 2157, trazido por Rodrigo Ferraz e Arthur Gilberto.

142. Além de se remeterem a documentos já enviados à SMI pela LAEP, quando de sua manifestação de fls. 927-933, os defendentes anexaram outros para comprovar a situação financeira em que se encontravam a Companhia e a Parmalat em janeiro de 2010, ou, mais especificamente, em 14.1.2010, quando teriam sido inquiridos a vender suas BDRs e emprestar os recursos. Os documentos são:

- i Relação de títulos protestados por fornecedores entre nov/2009 e jan/2010 (fl. 1539);
- ii Documentos policiais e judiciais relativos a bloqueio de entrada e saída e arresto de bens e produtos da unidade de Santa Helena/GO, datados de dez/2009 e jan/2010 (fls. 1541-1562);
- iii Notícias sobre acampamento de produtores e bloqueio de entrada e saída de produtos, em 13 e 14.1.2010, na fábrica de Santa Helena/GO, publicadas entre os dias 8.12.2009 e 20.1.2010 (fls. 1082-1101, 1108-1109);
- iv Notícia de 15.1.2010, sobre notificação extrajudicial do Governo do Estado do Rio de Janeiro para pagamento de dívidas com produtores do estado, bem como a ameaça de interdição da fábrica de Itaperuna caso não seja feito o referido pagamento (fl. 1002);
- v Correspondência enviada a Rodrigo Ferraz pela Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado de Rio de Janeiro – FAERJ, datada de 26.7.11, atestando que a entidade, em dezembro de 2009, coordenou os esforços de produtores e cooperativas de leite junto ao Governo do Estado para a regularização dos pagamentos da Parmalat, e que em jan/2010 a entidade comunicou que poderia haver uma intervenção governamental na empresa, mas que na tarde de 15.1.2010 esta informou o pagamento dos fornecedores em atraso (fls. 1564-1565);
- vi E-mail enviado pelo Assessor Especial da Secretaria Estadual, em 20.6.2011, para Rodrigo Ferraz e Othniel Lopes, confirmando que as tratativas entre o Governo do Estado e a Parmalat para regularização dos pagamentos aos fornecedores de leite iniciaram-se em dez/2009, e que na manhã de 14.1.2010 a empresa foi comunicada de que seria formalmente notificada para que regularizasse os pagamentos, sob pena de intervenção (fls. 2161-2162).

143. Estes últimos documentos, segundo os defendentes, refutariam a afirmação da Acusação, nos itens 90 e 91 retro, de que não poderia ser de conhecimento da Companhia, em 14.1.2010, que ela seria notificada sobre a intervenção na unidade de Itaperuna, já que, como apontou a SMI, esta informação teria sido enviada à Parmalat/LAEP somente no dia 15.1, por meio da correspondência de fls. 935-936. Ademais, alegam os defendentes que a publicidade daquele fato poderia ser comprovada, também, pela citada notícia publicada na imprensa em 15.1.2010, noticiando a possível notificação extrajudicial (fl. 1102).

144. O exposto até aqui confirmaria, segundo Othniel Lopes e Armando Buchina, que, em 14.1.2010, *"a Companhia se encontrava absolutamente estrangulada, devendo a milhares de fornecedores, sem possuir qualquer caixa ou acesso a fonte de recursos."* Nem mesmo as empresas de *factoring* e fomento mercantil, acrescentaram, *"se disponibilizavam a emprestar recursos para a Companhia, diante da existência de dívidas em atraso não quitadas"* (fl. 1422).

145. Ademais, estando com uma fábrica bloqueada e outra na iminência de sofrer uma intervenção, aduziram Rodrigo Ferraz e Arthur Gilberto que se *"a Companhia não pudesse contar com [esta produção] e com a consequente continuidade nos descontos dos recebíveis por eles gerados, as suas operações se encerrariam imediatamente"* (fl. 1975).

146. A solicitação para que alguns executivos alienassem em bolsa os BDRs recebidos no SIP e emprestassem os recursos para a Companhia, teria sido assim, no dizer dos defendentes, a alternativa que restou à LAEP para angariar recursos, em face da sua situação pré-falimentar.

5.1.3. DA ALIENAÇÃO E EMPRÉSTIMO DE BDRS

147. Dessa forma, em 14.1.2010, *"a Diretoria da Companhia solicitou a alguns de seus mais importantes executivos, entre os quais os Defendentes"* (fl. 1423), que vendessem seus BDRs e emprestassem os recursos à Companhia, solicitação que foi formalizada no documento intitulado Officers Meeting, de fl. 1016. No mesmo ato, foi dada autorização para que alguns diretores vendessem BDRs, em exceção aos Programas Individuais de Investimento e à Política de Negociação da LAEP.

148. Alegando a urgência da medida, o documento também estipulava a necessidade de posterior ratificação da autorização pelo Conselho de Administração e a submissão desses atos à Assembleia Geral. A ratificação do conselho ocorreu no mesmo dia, anexando Othniel Lopes e Armando Buchina, para provar tal fato, mensagens eletrônicas trocadas entre o DRI da LAEP e assessores contratados em Bermudas para o registro da ata (fls. 1572-1586).

149. Othniel Lopes e Armando Buchina elencaram as seguintes deliberações aprovadas pelo Conselho de Administração da LAEP, na reunião do dia 14.1.2010:

- a. O presidente do conselho foi autorizado a permitir que certos executivos vendessem BDRS, em exceção aos Programas Individuais de Investimento e à Política de Negociação e qualquer membro do órgão conselho estaria autorizado a tomar qualquer medida necessária a esta deliberação;
- b. Todas as medidas tomadas e documentos assinados, relativos às deliberações acima, estariam confirmados e ratificados;

c. Que era no melhor interesse da Companhia autorizar a alienação dos BDRs e o empréstimo dos recursos à sociedade, que arcaria com todos os impostos e custos.

150. Os defendentes destacaram que, em 19.2.2010, AGE da LAEP ratificou e autorizou a venda de seus BDRs acima dos limites e fora dos prazos da Política de Negociação e dos Programas Individuais de Investimento, bem como o empréstimo dos recursos, com desconto prévio junto à BS Factoring (fls. 1.031-1040).

151. Assim, em 15.1.2010, *"tal como solicitado pela Companhia e em observância às normas aplicáveis e aos seus deveres fiduciários, (fl. 1426)"* Othniel Lopes alienou 2.300.000 BDRs, por R\$5.770.694,00, e Armando Buchina alienou 300.000 BDRs, por R\$756.000,00, tendo ambos, na mesma data e pelos mesmos montantes, celebrado os contratos de empréstimo com LAEP e Parmalat.

152. Da mesma forma, Rodrigo Ferraz alienou 1.800.000 BDRs, por R\$4.997.560,00, e Arthur Gilberto alienou 800.000 BDRs, por R\$2.185.884,00, valores estes também emprestados à LAEP/Parmalat.

153. Segundo Othniel Lopes e Armando Buchina, as condições de crédito que ofereceram para a Companhia (CDI + 0,5% ao mês) foram bem mais favoráveis que qualquer condição de mercado encontrada por companhias em melhores condições de solvência, e que o risco assumido por eles de os empréstimos não serem quitados, *"inversamente proporcional ao benefício fruído pela empresa (...) justifica o fato de a empresa ter arcado com os impostos e encargos incidentes sobre a operação"* (fl. 1427).

154. Do mesmo modo, Rodrigo Ferraz e Arthur Gilberto, acrescentaram que venderam os BDRs por solicitação da Companhia e, por isso, *"não fazia sentido que ainda fossem obrigados a arcar com os tributos e demais despesas decorrentes de tal alienação, especialmente considerando que (...) o imposto de renda (...) corresponderia a 15% do valor total"* (fls. 1978).

155. Os defendentes justificaram a necessidade do adiantamento dos recursos para a Parmalat pela BS Factoring pelo fato de que as alienações de BDRs somente seriam liquidadas três dias depois das operações, tendo sido, para isso, firmado os Termos Aditivos de fls. 1072-1076, pelos quais cederam os direitos de recebimento dos recursos, quando de sua liquidação financeira.

156. Relatam os defendentes que os empréstimos injetaram cerca de R\$14 milhões no caixa da Companhia, soma equivalente a 42% das dívidas de curto prazo com produtores e cooperativas em 14.1.2010, permitindo o pagamento aos pequenos produtores das regiões de Itaperuna/RJ e Santa Helena/GO, em 15 e 18.1, conforme extratos às fls. 2174-2189.

157. O parecer por eles anexado verificou os controles gerenciais que registram os fluxos de caixa consolidados da LAEP, atestando, às fls. 2133-2134, que nos dias 15 e 18.1.2010 (sexta e segunda feira), ocorreram pagamentos a produtores de leite, cooperativas, transportadores, no total de R\$9.553 mil, além de fornecedores de embalagem e outros serviços, no total de R\$2.511 mil. A esse montante de R\$12.064 mil, somou-se o pagamento à BS Factoring de uma parcela de R\$2.100 mil em 15.1 e outra de R\$188 mil, a título de juros retidos.

158. O total de pagamentos teria sido, portanto, de R\$14.352 mil, montante que, apontou o referido parecer, *"consome praticamente todos os recursos emprestados e*

comprovam a importância do ingresso desses valores naqueles momentos crítico de falta de liquidez financeira vivenciados pela Laep” (fl. 2134).

159. Já a rubrica de ajuste, constante do Termo Aditivo firmado entre a LAEP e a BS Factoring, contestada pela Acusação, referir-se-ia, segundo os defendentes, a amortizações efetuadas nas contas correntes que a Companhia mantinha com a empresa de fomento, que tinham saldo devedor de R\$55.085.894,25 e R\$24.212.364,35, conforme atestou o parecer contábil-financeiro anexado às defesas. Segundo este documento, às fls. 1522-1524, os controles financeiros da LAEP, que registravam esses saldos, consignaram amortizações de R\$2.100,00 na primeira conta e R\$1.000,00 na segunda, totalizando o valor de R\$3.100,00, integrante da rubrica Ajustes, no Termo Aditivo referente ao empréstimo feito por Othniel Lopes e Rodrigo Ferraz (fls. 1072-1076).

160. Em relação à inconsistência apontada pela Acusação entre as datas de alienação das BDRS, 15.1.2010, e de assinatura dos contratos onde já constavam os valores das vendas, 14.1.2010, os defendentes alegaram que se tratou de mero erro de inserção da data nos contratos, pois foi utilizado o modelo do que havia sido celebrado no dia anterior, não sendo, ademais, possível, como apontado pela SMI, que o contrato do dia 14 trouxesse os valores de papéis vendidos no dia 15.

161. Dessa forma, pelo exposto nos itens anteriores, alegaram os defendentes que as alienações de BDRS e os subsequentes empréstimos dos recursos para a LAEP foram medidas essenciais e indispensáveis para a sobrevivência da Companhia, permitindo-lhe continuar suas atividades até que outras medidas fossem implementadas, entre elas a negociação com o GEM, a conversão de dívidas em capital e a associação com a Monticiano (fl. 1430-1431, 1982).

5.1.4. DA OPERAÇÃO COM O FUNDO GEM

162. Afirmaram os defendentes que os aportes de recursos pelo GEM, na operação de capitalização objeto do fato relevante de 15.1.2010, além de serem realizados a médio prazo, sem suprir a necessidade urgente de recursos da Companhia, estavam sujeitos a uma série de condicionantes, como por exemplo o disposto na Cláusulas 7.1 (k) e 7.2, que vinculavam a transferência de recursos ao estado de solvência da Companhia (fls. 1431-1434, 19975-1976).

163. Daí que, segundo eles, tanto a Companhia não podia esperar que a primeira parcela dos recursos entrasse, para resolver suas pendências com os produtores de leite, como também esta mesma situação financeira trazia incerteza, em 14.1.2010, quanto à efetiva concretização da operação.

164. Os defendentes alegaram que a sua expectativa e a de todos os envolvidos na operação era de que, com o seu anúncio ao mercado, os BDRs da LAEP se valorizassem, como seria normal ocorrer, no seu entendimento, nas operações do tipo PIPE, em que um investidor aporta recursos vultosos em uma companhia, citando, para embasar esta opinião, estudos feitos para o mercado norte-americano (fls. 1459-1462, 1996-2001).

165. Assim embora reconhecendo a diluição dos antigos acionistas pela emissão de novas ações, o aporte de R\$120 milhões numa companhia naquelas condições financeiras deveria, para os defendentes, impactar positivamente as cotações dos BDRS, o que, se não ocorreu, teria sido, segundo a sua interpretação, pela alta que havia se verificado anteriormente.

166. Quanto a isso, aduziram também os defendentes que a evolução das cotações dos BDRs não poderia subsidiar as acusações formuladas pela SMI, pois estariam descoladas

dos fundamentos da Companhia, devido à série de boatos de que o controle acionário da Parmalat seria alienado, conforme a própria SMI teria reconhecido à fl. 499.

167. Ainda sobre a evolução das cotações, os defendentes discordaram da afirmação da Acusação de que os BDRs teriam tido forte desvalorização após a divulgação do fato relevante comunicando o acordo com o GEM, em 15.1.2010, anexando documento com as cotações posteriores a esta data, às fls. 2191, e alegando que elas oscilaram entre R\$2,40 e R\$2,60, chegando a ser negociada por valor superior ao de fechamento do dia 14.1, e tendo se desvalorizado com mais força somente a partir de 4.2.2010.

168. Em suma, alegaram os defendentes que não alienaram os BDRs por que tinham conhecimento da operação a ser firmada com o GEM, mas por que haviam assumido o compromisso de emprestar os recursos para a LAEP, que precisava de capital imediato e que estava impossibilitada de obter recursos de outras fontes, sendo "*evidente que as referidas alienações não tiveram qualquer relação com a posse, pelos Defendentes, da informação sobre a possibilidade de realização de operação de PIPE com o GEM*" (fl. 1988) (grifo no original).

5.1.5. DA NÃO CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO DE *INSIDER TRADING*

169. Para afastar a imputação de uso de informação privilegiada nas negociações de BDRs objeto de empréstimo para a LAEP, os defendentes elencaram os quatro requisitos que, segundo a jurisprudência da CVM e a doutrina, caracterizariam a conduta de *insider trading* contida no §4º do art. 155 da lei 6.404/76, a saber, (i) a informação deve ser relevante; (ii) sigilosa e obtida por acesso privilegiado; (iii) utilizada, efetivamente, na negociação; (iv) que deve ser efetuada com o intuito de auferir lucro ou evitar prejuízo.

170. Argumentaram então que, na regulamentação deste dispositivo legal, a Instrução CVM nº 358/02, ao dispensar dois dos requisitos relacionados acima, quais sejam, (i) o uso efetivo da informação e (ii) a finalidade de auferir vantagem, criou uma presunção de que quem negociou com valores mobiliários de posse de alguma informação relevante não divulgada ao mercado, se utilizou dessa informação e teve por objetivo auferir vantagem, para si ou para outrem.

171. Trata-se, porém, continuaram, de uma presunção relativa (*juris tantum*), que admite prova em contrário, já que não poderia a norma regulamentar restringir a lei que regulamenta, sob pena de ilegalidade.

172. Segundo os defendentes, a interpretação exposta acima seria pacífica na doutrina nacional, e também na estrangeira, conforme excertos que colacionaram, bem como refletida na jurisprudência da CVM, como, por exemplo, no voto exarado pelo Diretor Relator Marcelo Fernandez Trindade em 28.6.2006, no julgamento do PAS CVM nº 04/2004, em que foi consignado:

"Há, portanto, na Instrução 358/02, uma presunção de que o *insider*, e o terceiro a ele equiparado pelo conhecimento da informação, atuam com a finalidade de obter lucro com a utilização da informação. Tal presunção legitima-se, e somente se legitima, diante da presença de indícios, e pode ser afastada por prova no sentido de que a obtenção de lucro não foi a finalidade da operação. Essa possibilidade de prova em contrário, a meu ver, decorre não só do necessário respeito, pela norma regulamentar, à norma regulamentada, como das regras dos §§ 6º e 7º do próprio art. 13 da Instrução 358/02, que admitem que a negociação ocorra na pendência de fato relevante não divulgado, em certas condições."

173. Rodrigo Ferraz e Arthur Gilberto trouxeram, quanto a isso, outro precedente da CVM, PAS CVM nº 17/2002, julgado em 25.10.2005, em que o Diretor, julgando suposto uso de informação privilegiada, admitiu que a presunção se desfaz quando o agente provar que a negociou por outros motivos relevantes, por uma necessidade premente frente a qual não seria possível exigir conduta diversa (fls. 1991-1992).

174. Assim, concluíram os defendentes que se o agente provar que não usou a informação ou que a negociação não teve a finalidade de obter vantagem econômica, não estaria configurado o ilícito de *insider trading* (fls. 1445).

175. Dessa forma, alegaram que, conforme exposto anteriormente, alienaram seus BDRs para emprestar os recursos à LAEP, e não em função do conhecimento que possuíam do acordo de investimento com a GEM, e também sem a finalidade de auferirem qualquer vantagem, o que afastaria a responsabilização pela prática de *insider trading*.

176. Os defendentes acrescentaram que, caso não tivessem alienado os BDRs e emprestado os recursos para a LAEP, esta seria levada à falência, pela impossibilidade de continuar suas atividades. Logo, incidiu sobre essas operações o princípio da inexigibilidade de conduta diversa, que, no ordenamento jurídico vigente, exclui a culpabilidade do agente (fls. 1446-1447, 1992-1993).

177. Ademais, alegaram os defendentes que caso não houvessem ajudado a LAEP com o empréstimo de recursos, teriam faltado a seu dever de lealdade para com a Companhia, preconizado pelo *caput* e inciso II do art. 155 da Lei 6.404/76. Teriam agido, assim, no precípua interesse da Companhia, nos termos do disposto do art. 154 da Lei Societária (fls. 1465-1466, 2001-2003) ³².

178. A esse respeito, invocaram o precedente do Inquérito Administrativo CVM nº 07/91, julgado em 6.6.1994, em que foi absolvido acionista controlador que, na pendência da divulgação de fato relevante vendeu ações da companhia e repassou os recursos para ela, visando evitar sua possível concordata ou falência. A CVM, ao absolvê-lo, teria privilegiado assim, neste caso, a ótica da preservação da companhia sobre a prática do *insider trading* (fls. 1466-1468, 2004-2005).

179. Os defendentes reiteraram, desse modo, que agiram no interesse da Companhia e em cumprimento a seus deveres de diligência e lealdade, ao venderem BDRs e emprestarem os recursos, beneficiando, ademais, os investidores e o mercado como um todo, não havendo, portanto, nenhum sentido em responsabilizá-los por sua conduta.

5.1.6. DA POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DOS BDRS EM PERÍODO VEDADO

180. Não obstante a justificativa de que as alienações de BDRS não foram motivadas pelo fato relevante de 15.1.2010, mas sim para auxiliar a Companhia em uma situação emergencial, os defendentes também alegaram que haveria exceções à regra geral de vedação à negociação de posse de informação privilegiada, que alcançariam as alienações de BDRs realizadas por eles quando já tinham conhecimento do acordo de investimentos a ser firmado entre LAEP e GEM (fls. 1447-1456, 2010-2025).

181. Estas exceções estão previstas no §7º do art. 13 da Instrução CVM nº358/02:

Art.13, §7º - As vedações previstas no *caput* e nos §§ 1º a 3º não se aplicam às negociações realizadas pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com

funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, de acordo com política de negociação aprovada nos termos do art. 15.

182. Acrescentaram os defendentes que o disposto no dispositivo acima teria sido referendado pelo Ofício Circular/CVM/SEP/nº 04/2011, que dispôs que *"tanto no caso de programa de recompra de ações, como nas demais vedações acima citadas, a proibição de negociação não se estenderá às negociações que sejam realizadas em conformidade com a política de negociação aprovada pela companhia, nos termos do artigo 15 da Instrução CVM nº 358/02."*³³

183. Nesse sentido, relataram os defendentes que, após a Oferta Pública de Ações realizada em 31.10.2007, a LAEP elaborou e arquivou na CVM, em 6.11.2007, a sua Política de Negociação (fls. 940-958), em consonância com o artigo 15 da Instrução CVM nº 358/02, que permaneceu em pleno vigor até agosto de 2011, sem sofrer qualquer alteração nesse período ou manifestação da CVM no sentido de que fosse ajustada ou alterada.

184. O art. 11 da Política de Negociação veda a negociação com valores mobiliários anteriormente à divulgação ao público de fato relevante, por parte das pessoas vinculadas com conhecimento de tal fato relevante e/ou da data de sua divulgação:

11. Anteriormente à divulgação ao público de Fato Relevante, nos termos da Política de Divulgação, é vedada a negociação, prestação de Aconselhamento ou assistência de investimento em Valores Mobiliários por parte das Pessoas Vinculadas que tenham conhecimento de tal Fato Relevante e/ou da data de sua divulgação.

185. Alegaram, porém, os defendentes, que a mesma Política de Negociação previa, nos seus itens 23, 30 e 35, hipóteses nas quais seria permitido às pessoas vinculadas negociarem valores mobiliários de emissão da Companhia mesmo na pendência de divulgação de fato relevante:

23. As Pessoas Vinculadas que tiverem seus Planos Individuais de Investimento aprovados pela Companhia, em conformidade com as especificações abaixo, poderão negociar Valores Mobiliários na pendência de divulgação de Fato Relevante, não obstante terem de observar todas as obrigações constantes da presente Política de Negociação.

30. A Política de Negociação não poderá ser aprovada ou alterada na pendência de Fato Relevante ainda não divulgado. Situações excepcionais envolvendo negociações de Valores Mobiliários previamente apresentadas à consideração do *Compliance Officer* poderão ser autorizadas, observados os limites legais regulamentares.

35. A negociação com Valores Mobiliários por Pessoas Vinculadas durante os períodos de não negociação, conforme previstos nesta Política de Negociação, poderá ser excepcionalmente autorizada pela Diretoria da Companhia, mediante solicitação apresentada por escrito contendo a justificativa da necessidade da negociação.

186. Os defendentes anexaram às defesas parecer jurídico datado de 13.1.2010 (fls. 1648-1645) que, em vista da regularidade da Política de Negociação da LAEP e face à situação excepcional vivida pela Companhia naquele momento, que justificaria a autorização dada pela Diretoria para a alienação das BDRs, concluiu que seria poderia ser evocado o §7º do art. 13 da IN 358 para afastar a vedação do *caput* do mesmo artigo.

187. O mesmo parecer jurídico defendeu que as exceções previstas na Política de Negociação da LAEP seguiram o mesmo padrão adotado por outras companhias, entre as quais, a título de exemplo, citaram Petrobrás, Ambev, B2W e Gafisa (fls. 1452-1454).

188. Assim, segundo os defendentes, as alienações de BDRs que fizeram nos dias 14 e 15.1.2010 estariam enquadradas no item 35 da Política de Negociação da LAEP, pois foram justificadamente autorizadas pela Diretoria da Companhia em caráter excepcional, e também autorizadas pelo Conselho e ratificadas pela AGE.

189. Essas operações teriam sido a venda de 1.800.000 BDRs por Rodrigo Ferraz e de 800.000 por Arthur Gilberto, em 14.1.2010, e de 2.300.000 BDRs por Othniel Lopes e de 300.000 por Armando Buchina, em 14.1.2010.

190. Ademais, em relação à afirmação da Acusação de que as autorizações dadas para a alienação das BDRs teriam configurado uma alteração da Política de Negociação da LAEP, em infração ao § 1º do art. 15 da Instrução CVM nº 358/02³⁴, os defendentes alegaram que, na verdade, não teria havido alteração, pelo contrário, apenas teriam se executado dispositivos previstos na política, que autorizavam a Diretoria da Companhia a aprovar negociações em caráter excepcional.

191. Assim, reiteraram os defendentes que, não obstante estarem de posse de informação privilegiada por ocasião de negociação de BDRs da LAEP, não caberia a sua punição, pois agiram em observância à Política de Negociação da Companhia e em benefício desta, e não de seus interesses particulares, dada a situação excepcional do momento.

5.1.7. DAS NEGOCIAÇÕES FEITAS NO ÂMBITO DOS PLANOS INDIVIDUAIS DE INVESTIMENTO

192. Othniel Lopes também foi acusado de operar de posse de informação privilegiada nas alienações de 400.000 BDRs em 13.1.2010, 400.000 em 18.1.2010 e 350.000 em 20.1.2010, totalizando 1.150.000 BDRs. Da mesma forma, Armando Buchina também foi acusado pela alienação de 150.000 BDRs em 13.1.2010.

193. Conforme já relatado, eles receberam os BDRs no âmbito do Programa de Incentivo de Compra de Ações ("SIP") da LAEP, às fls. 1472 a 1486. Ambos protocolizaram e arquivaram, na Companhia, Planos Individuais de Investimento, Othniel Lopes em 25.9.2009 (fls. 622-625), com a autorização para alienar e/ou adquirir até 1.200.000 BDRs por mês, e Armando Buchina em 6.11.2009 (fls. 553-555), com a autorização para alienar e/ou adquirir 300.000 BDRs por mês.

194. Othniel Lopes e Armando Buchina também aduziram que a Política de Negociação da LAEP permitia, no seu item 23, reproduzido acima, a negociação na pendência de fato relevante, desde que dentro dos limites do Plano Individual de Investimento, exceção também constante destes planos, em seu item 3.1 (fls. 986, 1013):

3.1. As restrições à negociação, conforme estabelecido na seção Proibições à Negociação, item 14, da Política, bem como nos Fatos Relevantes, em geral não são aplicáveis ao Diretor nomeado, sempre que as operações tiverem sido realizadas dentro do âmbito deste IIP.

195. Assim, os defendentes alegaram que as alienações feitas por Othniel Lopes em 13.1.2010, 400.000 BDRs, 18.1.2010, 400.000 BDRs, e 20.1.2010, 350.000 BDRs, e por Armando Buchina em 13.1.2010, 150.000 BDRs, foram feitas dentro dos limites permitidos pelos Planos Individuais de Investimento, havendo ademais, exceções às restrições à negociação, para operações realizadas no âmbito desses planos.

196. Alegaram, em acréscimo, que como tinham uma expectativa de que a operação com o fundo GEM levasse a uma valorização das cotações dos BDRs da LAEP, as vendas que fizeram no dia 13.1.2010 não teriam, portanto, sido feitas com o uso desta informação e nem tido o objetivo de auferir vantagem, o que descaracterizaria o *insider trading*.

5.2. DA DEFESA DE RODRIGO HOFFMANN

197. Rodrigo Hoffmann apresentou a defesa tempestiva em 22.8.2011 (fls. 1683 a 1753).

198. Em petição protocolada em 8.12.2015, alegou ter ocorrido a prescrição intercorrente do processo, nos termos do §1º do art. 1º da Lei nº 9.873/1999, tendo apresentado as mesmas razões já relatadas para os defendentes anteriores.

199. Declarou que, à época dos fatos, era Gerente Executivo Financeiro da Parmalat e que, em vista dos serviços prestados, recebeu, em 5.6.2009, 200.000 BDRs de emissão da LAEP, dentro do SIP da Companhia (fls. 1759-1772).

200. Apresentou narrativa da evolução financeira da LAEP, da OPA realizada em 2007 até a situação emergencial vivenciada pela Companhia em janeiro de 2010, similar à apresentada por Othniel Lopes, Armando Buchina, Rodrigo Ferraz e Arthur Gilberto (fls. 1692-1702).

201. Como os demais defendentes, Rodrigo Hoffmann declarou que, em vista de seu estado pré-falimentar, a LAEP, em 14.1.2010, solicitou a alguns de seus executivos que vendessem seus BDRs recebidos em plano de remuneração e emprestassem os recursos à Companhia.

202. Esta solicitação, porém, não o contemplou, não tendo participado das reuniões da Diretoria e do Conselho de Administração da LAEP realizadas em 14.1.2010.

203. No dia seguinte, porém, segundo alegou, a Diretoria da Companhia solicitou a ele que também alienasse seus BDRs e auxiliasse a sociedade a sair de sua situação de insolvência, ocasião em que comunicou que já havia vendido seus papéis, em 8.1.2010, e comprado ações de outra companhia, em 12.1.2010, conforme notas de corretagem às fls. 1774-1775.

204. Comprometeu-se, porém, a se desfazer desta posição e emprestar os recursos, tendo, em 18.1.2010, vendido os papéis que havia comprado seis dias antes, conforme nota de corretagem à fl. 1776, destacando que teve prejuízo nesta operação feita por solicitação da Companhia.

205. O mútuo com a LAEP e a Parmalat foi realizado no mesmo dia 15.1.2010, no valor de R\$528.565,60 (fls. 1061-1064), equivalente à negociação de BDRs realizada em 08.1.2010, *"assumindo as mutuárias os encargos e impostos incidentes sobre a operação e obrigando-se a quitar os valores do empréstimo corrigidos à taxa CDI, acrescidos de 0.5% ao mês"*.

206. Rodrigo Hoffmann ressaltou que tais condições de empréstimo *"foram bem mais favoráveis que qualquer condição de mercado encontrada por companhias de mais reputada solvência"* e que *"o risco de não reaver esses valores era inversamente proporcional ao benefício fruído pela empresa"*, o que justificaria ter ela arcado com os encargos da operação.

207. Acrescentou que, como o valor oriundo da alienação não estaria disponível imediatamente em sua conta bancária, firmou em 15.1.2010, na qualidade de garantidor, um Termo Aditivo ao Contrato de Fomento Mercantil celebrado entre a Parmalat e a BS Factoring, às fls. 1075-1078, pelo qual esta adiantaria os valores à Companhia, recebendo em troca os recebíveis do defendente, garantido por um cheque de sua conta bancária pessoal (fl. 1704).

208. Rodrigo Hoffmann destacou que a alienação de BDRs que fez em 8.1.2010 e o empréstimo de recursos à Companhia foram ratificados pela AGE de 19.2.2010, tendo a sua operação de venda sido enquadrada como exceção autorizada na Política de negociação, mesmo sem ter tido, alegou, acesso à informação sobre o acordo com o GEM.

209. Como os outros defendentes, Rodrigo Hoffmann afirmou que os recursos oriundos das operações de empréstimo, cerca de R\$ 14 milhões, possibilitaram a quitação de dívidas junto aos fornecedores de leite, evitando que a Companhia paralisasse as atividades em duas de suas principais plantas e dando a ela o fôlego necessário à estruturação de seu passivo.

210. Alegou, ainda, que a própria Acusação reconheceu que não há evidências manifestas de que o defendente teria tomado conhecimento do fato relevante referente ao acordo com a GEM, antes de sua divulgação (fls. 1266), e que "a data em que o Defendente foi comunicado não teria sido sequer mencionada".

211. Rodrigo Hoffmann afirmou, assim, que a Acusação "*fundou-se em mero indício, incapaz de provar que o Defendente teve acesso a informações privilegiadas antes de sua divulgação*". Citando a doutrina e a jurisprudência da CVM, como por exemplo, os PAS CVM nºs 06/95, julgado em 5.5.2005, 2002/2405, julgado em 11.10.2003, e 2003/5669, julgado em 11.7.2006, o defendente alegou que para se caracterizar a prática de *insider trading* por meio de indícios, é necessário que estes sejam convergentes e unívocos e que não haja contra indícios que afastem ou tirem a certeza desta caracterização, não podendo condenar-se por mera presunção, ou, como argumentou, "*com base nas meras suposições apresentadas pela SMI no Termo de Acusação*"(fls. 1725-1732). (grifou)

212. Nesse sentido, alegou, então, Rodrigo Hoffmann, que a Acusação não apresentou provas de que ele estivesse de posse de informações privilegiadas, baseando-se, para acusá-lo, em somente dois indícios, quais sejam: "(i) o Defendente **realizou uma única negociação** de BDRs, em 8 de janeiro, anterior a todas as demais negociações de outros acusados"; e (ii) "*sua ligação com o grupo foi comprovada em um anexo ao acordo firmado com a Monticiano, contendo a lista dos empregados de várias empresas do grupo. Seu nome figura na folha intitulada 'Lácteos'.*" (fl. 1729) (grifou)

213. Contra esses indícios, ele elencou os seguintes contra indícios, como fatos incontroversos e suficientes para afastar a caracterização de sua negociação como *insider trading*: (i) não ter sido ele citado como participante das tratativas sobre o acordo com o GEM, (ii) o fato de que era gerente da Parmalat e não participava do processo decisório da LAEP, (iii) o fato de que "*estava afastado do centro de decisões da Companhia, trabalhando em área totalmente diversa daquela em que se localizavam os executivos da LAEP*" (iv) vendeu BDRs uma única vez, em sua primeira oportunidade, logo após o período de *blackout*; e (v) o fato de, ao receber a solicitação para vender seus BDRs e emprestar os recursos, ter comunicado que já havia alienado suas posições e ter revertido o produto em favor da Companhia (fl. 1730).

214. Além de asseverar que não tinha prévio conhecimento do acordo no momento da venda de seus BDRs, Rodrigo Hoffmann também se utilizou dos mesmos argumentos de

Othniel Lopes, Armando Buchina, Rodrigo Ferraz e Arthur Gilberto, no sentido de que para se afastar a caracterização do *insider trading*, nos termos do §4º do art. 155 da lei 6.404/76, bastaria que se provasse que não utilizou a informação privilegiada na negociação, ou que esta não foi efetuada com o intuito de auferir lucro ou evitar prejuízo.

215. Assim, o objetivo e a motivação da alienação de seus BDRs foram emprestar os recursos para a LAEP, que sem eles poderia interromper suas atividades. Esta atitude, ademais, segundo alegou, em paralelo aos outros defendentes, foi tomada em uma situação de inexigibilidade de conduta diversa, em face da situação financeira da Companhia, e, como tal, excludente de sua culpabilidade fls. 1724-1725).

216. Sustentou, também, que a expectativa era que a operação com o GEM repercutisse de forma positiva na cotação do papel, de tal forma que a opção de subscrição de BDRs atribuída ao GEM se dava no valor de R\$ 3,00, para uma cotação no fechamento do dia 14.1.2010 de R\$ 2,65. Outro fator que geraria tal expectativa era o fato de a Companhia se encontrar na situação financeira relatada, esperando-se que um compromisso firmado com o GEM de aportar R\$ 120 milhões fosse bem recebido pelo mercado.

217. Acrescentou, ademais, que a sua conduta visou a proteger os interesses da Companhia, em atendimento ao seu dever de lealdade, nos termos do *caput* e inciso II do art. 155 da Lei 6.404/76, invocando, também, o precedente do Inquérito Administrativo CVM nº 07/91, julgado em 6.6.1994, citado pelos outros defendentes.

218. Por fim, Rodrigo Hoffmann também arguiu, em sua defesa, que a Política de Negociação da LAEP contemplava a possibilidade de, em casos extremos, a negociação de valores mobiliários em períodos vedados ser autorizada pela Diretoria.

5.3. DA DEFESA DE LUIZ ÁLVARO, NILTON MUNIZ, SILVANA DINO E TARCÍSIO DUQUE

219. Luiz Álvaro, Nilton Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque apresentaram, conjuntamente, defesa tempestiva em 22.8.2011 (fls. 2255 a 2291).

220. Declararam, inicialmente, que eram diretores não estatutários da Parmalat, conforme atas do conselho de administração de fls. 2295 a 2302, ocupando os seguintes cargos na época dos fatos: Luiz Álvaro, diretor de unidade de negócios – Jundiaí, Nilton Muniz, diretor comercial, Silvana Dino, diretora de recursos humanos, e, Tarcísio Duque, diretor industrial.

221. Preliminarmente, os defendentes alegaram que, embora a GMA-1 tenha lhes solicitado esclarecimentos sobre suas operações com BDRs da LAEP no período investigado, os ofícios a eles enviados, às fls. 527-534 e 543-550 **"induz[em] qualquer destinatário dessa intimação a entender que o pedido de esclarecimentos limitava-se ao evento de 15.01.2010"** e, dessa forma, teriam fornecido considerações prévias somente a respeito dos negócios que antecederam tal fato. (grifaram)

222. Entretanto, a Acusação **"incluiu também o fato relevante de 28.01.2010 (capitalização de dívidas da Laep) entre os eventos que teriam motivado suposta negociação com informação privilegiada pelos defendentes"**, evento este que, segundo afirmaram, não teve qualquer destaque no pedido de informações específico que lhes foi dirigido e que, por isso, não mereceu esclarecimentos de suas partes. (grifaram)

223. Dessa forma, teria havido, de acordo com os defendentes, uma violação às disposições do art. 11 da Deliberação CVM nº 538/08, que estabelece como condição prévia à formulação de uma acusação que o acusado seja instado a se manifestar previamente sobre os fatos investigados.

224. Por consequência, alegaram os defendentes que teria sido violado o seu direito de defesa prévia em relação a quaisquer das imputações relacionadas ao fato relevante divulgado pela LAEP em 28.1.2010, pelo que requereram "o *arquivamento do feito em relação a esse elemento da acusação*", ou, caso assim não entendido, "a *devolução dos autos à SMI para saneamento dessa irregularidade*" (fls. 2265-2267).

225. Para os defendentes, para que uma negociação no mercado de valores mobiliários seja caracterizada como *insider trading*, a informação privilegiada detida pelo *insider* deve ter sido efetivamente utilizada por ele na negociação. "Em outras palavras, o *exame dos motivos determinantes da conduta do insider quando da tomada de decisão*" de negociação deve ser perquirido pela CVM, para se concluir por sua responsabilização, no teor do art. 155, §4º, da Lei 6.404/76.

226. A Instrução 358/02, no entanto, segundo sustentaram os defendentes, não reproduziu, na redação do seu art. 13, "**a menção ao elemento essencial à caracterização da vedação contida na lei, qual seja, que a proibição em tela se dirige ao uso indevido da informação para auferir vantagem no mercado**". (grifaram)

227. Assim, continuaram, coube à doutrina e à jurisprudência diferenciar os *insiders* entre primários e secundários, havendo sobre os primeiros, em razão do cargo que ocupam na companhia, uma presunção relativa de conhecimento da informação privilegiada e de uso dessa informação para auferir vantagem, com a consequente inversão do ônus da prova quanto às negociações efetuadas por eles na pendência de algum fato relevante não divulgado.

228. Já quanto aos segundos, cujo acesso à informação se dá de forma derivada, o ônus da prova caberia a quem alega, não somente quanto ao conhecimento da informação como quanto ao conhecimento de que seria uma informação privilegiada e não divulgada, ou que ele deveria saber disso em função da posição que ocupa.

229. Seguindo essa linha, citaram entendimento do Colegiado da CVM, no PAS CVM nº 22/06, julgado em 2.10.2009, em que "os acusados que ocupavam cargos gerenciais na emissora, foram absolvidos por ausência de elementos que demonstrassem que tinham prévio conhecimento das informações privilegiadas", ou seja, teria entendido a Autarquia que não cabe "*presunção relativa de conhecimento sobre a existência de informações não divulgadas ao mercado em se tratando do exame de negociações efetuadas por funcionários da companhia emissora*."

230. Argumentaram os defendentes que, do mesmo modo que no processo supracitado, eles não eram, à época, administradores ou trabalhavam em áreas envolvidas com o respectivo fato relevante divulgado em 15.1.2010, tendo a Companhia afirmado que eles não estavam entre os conhecedores da informação, conhecimento também negado por todos eles.

231. Deveria então a Acusação ter demonstrado, de forma ao menos indiciária, o conhecimento dos fatos relevantes pelos defendentes no momento em que realizaram seus negócios com BDR da LAEP, tarefa de que, afirmaram, ela não se desincumbiu, não se podendo "*impor aos defendentes o ônus de provar a inexistência do conhecimento*".

232. Sustentaram, ademais, que no presente processo "*nem mesmo se pode afirmar que existam indícios consistentes para subsidiar a acusação formulada*", indícios que, conforme entendimento consolidado da CVM, para que ensejem uma condenação devem ser "graves, precisos e concordes que levem a uma conclusão robusta e fundamentada acerca do fato que se quer provar"³⁵.

233. Sustentaram os defendentes que *"na verdade, fartas evidências se encontram nos autos justamente apontando o oposto da tese acusatória"*, como a citada declaração da LAEP de que eles não estavam *"no rol de pessoas que detinham conhecimento das operações antes da data de 14.01.2010."*

234. Também o fato de que dez diretores venderam BDRs no período não serviria como indício, de acordo com os defendentes, pois *"se mais empregados tivessem alienado os papéis nesse período, levaria à idêntica conclusão, de que todos saberiam da informação privilegiada."* Da mesma forma, nada provaria a "coincidência" entre quem esteve na reunião de 14.1.2010 e as pessoas que alienaram BDRs no período, e o suposto "oportunismo" da conduta por eles apresentada (fl. 2274).

235. Os defendentes relataram que a origem de seus BDRs advém de planos de remuneração, anexados às fls. 2304-2308, e que não negociavam habitualmente com os papéis. Afirmaram que *"somente optaram por liquidar suas carteiras em virtude da forte alta experimentada por esses papéis a partir de dezembro de 2009"*.

236. Já no que tange à afirmação da Acusação, à fl. 1271, de que a Companhia falhara em *"manter mecanismos que permitissem a essas pessoas vinculadas terem conhecimento de que se achavam em período vedado à negociação"*, afirmaram que *"essa circunstância não pode ser invocada em prejuízo dos Defendentes, que não são responsáveis pela implementação da Política, devendo apenas cumpri-la"*.

237. Os defendentes rebateram a tese esposada pela Acusação de que o receio de queda das cotações dos BRDs da LAEP, causada por um possível impacto negativo das operações anunciadas em 15.1.2010 e 28.1.2010, os teria motivado a vender seus papéis.

238. Segundo eles, não soa *"minimamente convincente"*, em vista da situação econômico-financeira do grupo, que, reiteraram, foi devidamente informada à área técnica da CVM às fls. 927-1.175, que um investidor interpretasse os dois eventos como negativos para a Companhia, *"por representarem imediata injeção de recursos na Laep e redução de seus índices de endividamento"* (fl. 2280).

239. Acrescentaram, nesse sentido, que o desconhecimento da operação de capitalização contratada com o GEM é que justificaria terem operado como vendedores de BDRs no período.

240. Ademais, por uma razão de racionalidade financeira ou econômica, o salvamento da Companhia teria um peso maior no comportamento dos investidores, que não pautariam suas decisões preocupados com uma eventual diluição de sua participação nos lucros ou no acervo, em caso de falência ou liquidação.

241. Aduziram, também, os defendentes que na hipótese sustentada pela Acusação e tendo em vista suposta ameaça de diluição, teriam *"buscado liquidar integralmente suas posições em Laep imediatamente antes da divulgação da operação com a GEM"*, mas se comportaram de maneira diversa, tendo alienado gradualmente suas posições, inclusive posteriormente à divulgação do fato relevante.

242. Anexaram à defesa, às fls. 2310-2340, parecer técnico que, diferentemente da análise empreendida pela SMI, que atribuiu um viés negativo à oscilação da cotação de MILK11 devido aos fatos relevantes de 15.1.2010 e 28.1.2010, chegou à conclusão, com base em estudos estatísticos, que o fato relevante do dia 15.1 *"não exerceu impacto claro e imediato nos preços, o que sugere que as informações nele contidas teriam "ex post" também caráter ambíguo, pois, ao mesmo tempo em que consistia em aporte de capital*

de novo investidor (sinal positivo), implicaria na diluição da participação acionária dos atuais acionistas (sinal negativo)”, chegando à mesma conclusão em relação ao fato do dia 28.1 (fl. 2283).

5.4. DA DEFESA DE FABIO FLOH

243. Fabio Floh apresentou defesa tempestiva em 22.8.2011 (fls. 1329-1377).

244. Apresentou, posteriormente, preliminar referente ao pedido de reconsideração por ele formulado em 8.8.2012 (fls. 2471-2476), e que não teria sido considerado na decisão de rejeição tomada pelo Colegiado em 20.10.2015, de fls. 2477-2478.

245. Também alegou a prescrição intercorrente do processo, nos mesmos termos alegados por Othniel Lopes, Rodrigo Ferraz, Arthur Gilberto e Rodrigo Hoffmann (fls. 2496-2501).

246. Afirmou que, à época dos fatos, era Gerente Jurídico da Parmalat e que os BDRs de emissão da LAEP que negociou em janeiro de 2010, objeto do presente processo, foram recebidos como prêmio de remuneração em 16.7.2009, após aprovação da AGE da Companhia em 5.1.2009.

247. Alegou que após o recebimento dos BDRs, a sua negociação teria sido impedida por vários eventos que não estavam sob o seu controle, incluindo períodos de vedação devido a fatos relevantes não divulgados, dos quais destaca a negociação de unidade fabril pela Parmalat à Nestlé, divulgada em 18.11.2009, e o sistemático atraso na apresentação dos 1º, 2º e 3º ITRs de 2009³⁶, fatos esses que impossibilitaram a negociação dos títulos no período de 16.10 e 22.12.2009.

248. Em vista da profusão de boatos sobre a Companhia que estavam circulando entre o segundo semestre de 2009 e o começo de 2010, narrada pela própria Acusação e dos quais alega não ter sabido as razões, declarou o defendente que, para garantir o efetivo recebimento do prêmio recebido, protocolou na LAEP, em 5.11.2009, um Plano Individual de Investimento, na forma prevista na Instrução CVM nº 358/02 (fls. 580-593).

249. Fabio Floh reiterou, conforme já informado por ele próprio às fls. 577 e pela LAEP às fls. 20, que somente teve conhecimento da operação entre a Companhia e o fundo GEM no dia 14.1.2010, posteriormente, portanto, às datas de suas vendas, que se deram nos dias 11, 12 e 13.1.2010, e que logo após saber da referida operação *“suspendeu imediatamente qualquer operação com MILK11 e somente voltou a negociar no dia 4 de fevereiro de 2010, bem após a divulgação do fato relevante de 15 de janeiro de 2010”* (fls. 1336).

250. Alegou que a SMI formulou sua Acusação mesmo admitindo que, em relação a ele e a outros defendentes, não haveria *“dentro das limitações da investigação conduzida, como obter evidência direta, cabal e definitiva a respeito do uso privilegiado da informação”*³⁷.

251. Acrescentou que a Acusação desconsiderou toda a situação fática supradescrita, baseando-se apenas *“em mero indício de que o Defendente já tinha conhecimento da operação”* e sustentando *“como verdade objetiva (...) mera opinião pessoal”* (fls. 1336-1337).

252. Segundo o defendente, a jurisprudência em matéria criminal e administrativa recomenda cautela ao se formular acusação baseada em indícios, que devem, para isso, ser concordes e concludentes, e não serem contrarrestados por contraindícios que permitam uma explicação diferente aos fatos.

253. Assim, tendo a Acusação apresentado como indícios apenas o fato de que um conjunto de executivos da LAEP negociou BDRs na mesma data e a verificação de que o papel não era negociado por eles num longo período que antecedeu ao fato relevante, relacionou o defendente outros fatos que justificariam, quanto a ele, *"a certeza de uma postura irrepreensível"* ou, ao menos, lhe dariam o *"benefício da dúvida razoável, perante o levantamento de indícios tão frágeis"* (fl. 1338).

254. Primeiramente, alegou ser gerente jurídico, não estatutário, trabalhando em andar e local afastado dos diretores. Seu cargo não seria, segundo afirmou, o maior cargo jurídico da Companhia, *"nem sequer estava próximo ao poder decisório quanto à realização da operação com o GEM ou sobre os aspectos jurídicos atinentes a sua negociação"*.

255. Em continuação, afirmou que vendeu os papéis nas referidas datas porque, antes delas, estaria em período vedado, ou seja, *"vendeu os BDRs no primeiro momento em que pode fazê-lo, por se tratar de remuneração-prêmio"*, reiterando que suspendeu as vendas após tomar ciência do fato relevante. Destacou que, em vista da péssima situação financeira da Companhia, lhe angustiava não poder vender os papéis que representavam parcela significativa de sua remuneração, sem os quais esta seria incompatível com os valores de mercado (fls. 1338-1339).

256. Anexou o mesmo parecer técnico dos outros defendentes, que demonstraria que a cotação dos BDRs da LAEP não se alterou de forma significativa após a divulgação do fato relevante em 15.1.2010 e que a informação já estaria absorvida pelo mercado anteriormente, colacionando precedente da CVM, PAS CVM n.º 06/2003, que considerou que a informação disseminada, mesmo que de forma irregular, não poderia ser considerada privilegiada.

257. Argumentou, também, quanto à existência de Plano de Negociação e de Plano de Investimento Individual, como fatores de prevenção e de garantia de cumprimento da legislação, tendo asseverado que seguiu estritamente seus dispositivos.

258. Assim, Fabio Floh alegou que todas as negociações pelas quais é acusado foram realizadas de acordo com o permitido pela Política de Negociação de Valores Mobiliários da Parmalat e da LAEP, e dentro dos limites autorizados por seu Plano Individual de Investimento, *"o que, por si só, bastaria para a declaração da improcedência da acusação"* (fls. 1335).

259. Nesse sentido, defendeu que suas negociações se deram até o limite de 150.000 BDRs permitido por seu Plano Individual de Investimento e que o item 23 da Política de Negociação excepcionaria a regra geral de vedação à negociação na pendência de fato relevante, para quem tivesse tal plano aprovado, exceções também previstas no §7º do art. 13 da Instrução CVM nº358/02 e que foram referendadas pelo Ofício Circular/CVM/SEP/nº 04/2001³⁸.

260. O Plano Individual de Investimento, cuja carência, no caso do defendente, terminou no dia 6.12.2010, vedava a negociação nos 15 dias anteriores à divulgação de ITRs, IANs e DFPs, e o 3º ITR de 2009 somente foi divulgado em 23.12.2009. Daí que, nesse sentido, ele refuta a tese da Acusação, de que suas vendas teriam sido oportunistas, pois ele teria, na verdade, se aproveitado de janela de negociação e da alta de preços do papel.

261. Não teria havido, ademais, segundo ele, na mesma linha que outros defendentes, o atendimento a dois requisitos necessários para a caracterização do *insider trading*, nos

termos do §4º do art. 155 da Lei 6.404/76, c/c o art. 13 da Instrução CVM nº358/02: (i) o uso efetivo da informação e (ii) a finalidade de auferir vantagem.

262. Para Fabio Floh, a Acusação teria se influenciado pelo comportamento atípico das cotações dos BDRs da LAEP entre dezembro de 2009 e janeiro de 2010, que teria sido causado, na verdade, afirmou, pelas notícias e boatos que envolveram a Companhia à época, e não por um suposto vazamento de informação relevante.

263. Por fim, alegou Fabio Floh que na Acusação não houve "*sequer comprovação de quaisquer dos três elementos necessários da responsabilidade subjetiva: (i) culpa; (ii) dano; e (iii) nexo de causalidade*", que, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial que colacionou, às fls. 1365-1372, seriam necessários para a aplicação de penalidades pela CVM, sem que se incorresse na aplicação de responsabilidade objetiva, vedada em nosso ordenamento na seara administrativa, mas que, defendeu, teria sido aplicada no presente caso.

VI. DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

264. Em reunião de Colegiado realizada em 22.2.2013, o Diretor Otavio Yazbek foi sorteado como relator deste processo. Em razão do término do seu mandato, o processo foi redistribuído, em 7.1.2014, ao Diretor Roberto Tadeu. Em 27.1.2015, o processo foi redistribuído para mim, nos termos do art. 10 da Deliberação CVM nº 558/2008.

VII. DAS PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO

265. No curso do processo, foram apresentadas propostas de termo de compromisso pelos acusados Armando Tadeu Buchina, Arthur Gilberto Voorsluys, Fabio Floh, Luis Álvaro Moreira Ferreira Filho, Nilton Batista Muniz, Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha, Silvana Dino, Tarcísio Antônio de Rezende Duque e Rodrigo Andrés Pimenta Hoffmann.

266. Após negociação com os proponentes e manifestação da PFE, no tocante aos requisitos legais das propostas, o Comitê de Termo de Compromisso emitiu, em 16.5.2012, parecer favorável à aceitação das propostas. Porém, em entendimento diverso, o Colegiado decidiu, em 19.6.2012, que não seria oportuno e conveniente aceitá-las e que deveria o processo ser levado a julgamento em relação a todos os acusados.

267. Posteriormente, em 27.7.2012, Othniel Lopes também apresentou proposta de termo de compromisso (fls. 2413-2487) e os acusados Rodrigo Ferraz e Arthur Voorsluys, em 02.08.2012 (fls. 2443-2447), Rodrigo Hoffmann e Armando Buchina, em 28.08.2012 (fls. 2433-2442), e Luis Álvaro, Nilton Batista Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque, em 25.09.2012 (fls. 2448-2451) e em 13.03.2013 (fls. 2484-2489), apresentaram pedidos de reconsideração da decisão proferida em 19.06.2012.

268. Em 20.10.2015 (fls. 2477-2478), o Colegiado decidiu rejeitar a proposta formulada por Othniel Lopes, bem como não acolher os pedidos de reconsideração de Armando Tadeu Buchina, Arthur Gilberto Voorsluys, Luis Álvaro Moreira Ferreira Filho, Nilton Batista Muniz, Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha, Silvana Dino, Tarcísio Antônio de Rezende Duque e Rodrigo Andrés Pimenta Hoffmann.

269. Também Fabio Floh formulou, em 8.8.2012 (fls. 2471-2476), pedido de reconsideração da decisão do Colegiado da CVM proferida na reunião de 19.6.2012, que rejeitara a proposta de celebração de termo de compromisso, conforme relatado no item 247 retro.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2015.

Pablo Waldemar Renteria
DIRETOR-RELATOR

¹ “Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante.”

² “Art. 155. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular.

(...)

§4º. É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários.”

³ Os fatos relevantes divulgados, em conjunto, por LAEP e Parmalat, anteriormente aos comunicados de 16 e 17.12.2009, datavam de 18 e 23.11.2009 e comunicavam as tratativas e detalhes da alienação, para a Nestlé Brasil Ltda., de uma unidade produtiva pertencente à Parmalat (fls. 3-4).

⁴ Ofício/CVM/GMA-1/nº 10/10.

⁵ Conforme apurado pela SMI, às fls. 500-501, Central Veredas vendeu em bolsa estas 54.870.000 BDRs, entre os dias 10.2.2010 e 12.3.2010.

⁶ A SMI não encontrou qualquer divulgação de informação sobre negociação de pessoas ligadas à LAEP e à Parmalat no sistema IPE da CVM, desde fev/2009, no caso da LAEP, e desde dez/2003 para a Parmalat, tendo informado a SEP deste fato.

⁷ Apesar de não constar das listagens, seu nome aparece na ata da AGE da LAEP de 19.2.2010, como um dos autorizados, retroativamente, a vender BDRs e emprestar os recursos para a Companhia (fls. 565-569).

⁸ Ofícios/CVM/GMA-1/nºs 120 a 128/10 e 134/10

⁹ A DFP da LAEP de 31.12.2008 foi apresentada em 27.8.2009, e os ITRS de 2009 em 16.10.2009, 4.11.2009 e 23.12.2009.

¹⁰ Na realidade, conforme apurado pela SMI no RA 20/10, às fls. 485-505, nesse dia o papel abriu e fechou em R\$2,50, embora tenha apresentado alta no *intra day*.

¹¹ Na ata, por erro de grafia, constou Othniel Lopes de Oliveira ao invés de Othniel Rodrigues Lopes (fls. 629 e 927).

¹² Da ata da reunião do Conselho de Administração da LAEP não consta autorização para Armando Buchina e Rodrigo Hoffmann alienarem seus BDRs e emprestarem os recursos para a Companhia, apesar de a AGE ter ratificado a autorização também para os dois.

¹³ Anexada pela LAEP às fls. 940-958

¹⁴ O fato relevante foi divulgado às 11h:08min e Armando Buchina começou a vender suas BDRs às 16h:03min, conforme relação de negócios no CD-ROM de fl. 27.

¹⁵ Vide Nota 12.

¹⁶ Ofício/CVM/GMA-1/nº 135/10.

¹⁷ Na verdade é a Cláusula 35 da Política de negociação que permite essa exceção. Vide fl. 952 ou Item 51 retro.

¹⁸ Da mesma forma que a reunião do Conselho de Administração, a reunião da Diretoria também não relacionou Armando Buchina e Rodrigo Hoffmann entre os que iriam vender BDRs e emprestar recursos para a Companhia, apesar de a AGE ter posteriormente ratificado a autorização também para os dois. Vide Nota 12.

¹⁹ A SMI analisou os esclarecimentos prestados, os contratos de empréstimo e os Termos Aditivos, no Relatório de Análise GMA-1 28/10, às fls. 1185 a 1204, que antecedeu a apresentação do Termo de Acusação.

²⁰ Relatório de Análise GMA-1 28/10, fl. 1195.

²¹ Conforme relatado nos Itens 40 e 41 deste Relatório, as autorizações para Armando Buchina e Rodrigo Hoffmann alienarem seus BDRs e emprestar os recursos para a Companhia foi ratificada pela AGE de 19.2.2010, embora tais autorizações não constassem da ata da reunião do Conselho de Administração da LAEP de 14.1.2010.

²² Embora não citado pela Acusação, essas condições são impostas pelo § 3º do art. 15 da Instrução CVM nº 358/02.

²³ Vide Item 82 deste Relatório.

²⁴ Vide Tabelas 8, 11 e 12.

²⁵ Para exemplificar, a Acusação traz decisão do TRF/2ª Região no Agravo de Instrumento n.º 154675: “(...) impende salientar uma particularidade que envolve as demandas ligadas à ocorrência do insider trading: a prova por meios indiretos. Como já assente na doutrina e jurisprudência, a comprovação de que determinada atuação no mercado foi desleal porquanto motivada pela ciência de informações privilegiadas será sempre indireta, resultando da análise dedutiva dos indícios, que presumirão a ocorrência desse agir odioso”.

²⁶ Nesse sentido, a Acusação afirma que houve apenas picos *intra-day* em 15.1, 29.01, 1.2 e 2.2, não procedendo a alegação de Nilton Muniz de que o papel teria operado em alta após a divulgação do fato de 15.12.2010.

²⁷ Nas suas manifestações de fls. 551-918, alguns dos Acusados afirmaram que a legislação de Bermudas, onde a Companhia tem sede, os dispensaria dessa obrigação.

²⁸ MEMO PFE-CVM/GJU-4/Nº 022/2011

²⁹ Trata-se do pedido de reconsideração apresentado por Luis Álvaro, Nilton Batista Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque, às fls. 2448-2451.

³⁰ §1º - Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

³¹ De acordo com o documento de fls. 1478, Othniel Lopes e Rodrigo Ferraz teriam recebido um lote adicional.

³² Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.

Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado:

II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção de vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da companhia;

³³ Disponível em <http://www.cvm.gov.br/legislacao/circ/sep/oc-sep-0411.html>.

³⁴ §1º A política de negociação referida no caput não poderá ser aprovada ou alterada na pendência de ato ou fato relevante ainda não divulgado (...).

³⁵ Conforme voto da Diretora Norma Parente proferido no PAS CVM nº 24/00, julgado em 18.8.2005.

³⁶ A DFP da LAEP de 31.12.2008 foi apresentada em 27.8.2009, e os ITRS de 2009 em 16.10.2009, 4.11.2009 e 23.12.2009.

³⁷ Item 127 do Termo de Acusação (fls. 1269).

³⁸ Vide itens 203 e seguintes das defesas de Othniel Lopes, Armando Buchina, Rodrigo Ferraz e Arthur Gilberto.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2011/3823

Acusados: Othniely Rodrigues Lopes
Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha
Fábio Floh
Armando Tadeu Buchina
Arthur Gilberto Voorsluys
Luis Álvaro Moreira Ferreira Filho
Nilton Batista Muniz
Silvana Dino
Tarcísio Antonio de Rezende Duque
Rodrigo Andres Pimenta Hoffmann

Assunto: Negociação com uso de informação privilegiada ainda não divulgada ao mercado (infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76, c/c o art. 13, *caput*, da Instrução CVM nº 358/02).

Relator: Diretor Pablo Renteria

VOTO

1. Cuida-se de processo administrativo sancionador instaurado em face de administradores da Laep Investments Ltd. ("LAEP" ou "Companhia"), companhia estrangeira patrocinadora do programa de BDRs, e executivos de sua controlada indireta Parmalat Brasil S.A. Indústria de Alimentos ("Parmalat"), companhia aberta em recuperação judicial, à época dos fatos, por conta de suposta utilização de informações relevantes ainda não divulgadas ao mercado, na negociação de BDRs patrocinados pela primeira.

2. Conforme relatado, ao acompanhar oscilações atípicas de volume e preço dos BDRs, ocorridas entre dezembro de 2009 e janeiro de 2010, a SMI identificou operações de venda do papel em bolsa por parte de dez pessoas vinculadas à patrocinadora, que foram realizadas previamente à divulgação de fatos relevantes que teriam efeito negativo sobre a cotação.

3. Todas essas pessoas foram acusadas de violação ao disposto no art. 13, *caput*, da Instrução CVM nº 358/2002, combinado com o artigo 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976, em virtude de terem negociado BDRs patrocinados pela LAEP na posse de informações relevantes ainda não divulgadas ao mercado, relacionadas à capitalização da Companhia por um fundo estrangeiro, em 15.1.2010, e à conversão de sua dívida em capital, em 28.1.2010.

4. Neste voto, abordarei, primeiramente, a preliminar referente aos pedidos de extinção do processo por prescrição intercorrente, formulados pelos acusados Othniel Lopes, Armando Buchina, Rodrigo Ferraz, Arthur Gilberto, Rodrigo Hofmman e Fabio Floh, enfrentando na sequência a preliminar relativa ao pedido de reconsideração formulado, em 8.8.2012, pelo acusado Fabio Floh, acerca da decisão do Colegiado da CVM proferida na reunião de 19.6.2012, que rejeitara a proposta de celebração de termo de compromisso.

5. Em seguida, examinarei a acusação de utilização de informação privilegiada em relação ao fato relevante divulgado em 15.1.2010. Neste ponto, dividirei os acusados em dois grupos: de um lado, os que alegaram, principalmente, o desconhecimento do referido fato, e, de outro, aqueles que apresentaram como justificava para as operações os empréstimos à LAEP dos recursos obtidos. Por fim, abordarei a acusação de utilização de informação privilegiada em relação ao fato relevante divulgado em 28.1.2010.

I. DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

6. Othniel Lopes, Armando Buchina, Rodrigo Ferraz, Arthur Gilberto, Rodrigo Hofmman e Fabio Floh alegaram ter ocorrido a prescrição intercorrente do processo, nos termos do §1º do art. 1º da Lei nº 9.873/1999, pois o processo teria ficado por mais de três anos pendente de julgamento, despacho ou qualquer outro ato que interrompesse o prazo prescricional.

7. Argumentaram, nessa direção, que o processo teria permanecido paralisado entre o pedido de reconsideração apresentado em 25.9.2012 em relação à rejeição de celebração de termos de compromisso, e a decisão do Colegiado de 20.10.2015, que indeferiu esse pedido.

8. No entanto, essa narrativa dos fatos não condiz com os autos. Em 13.3.2013, os acusados Luis Álvaro, Nilton Batista Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque apresentaram novo pedido de reconsideração da decisão do Colegiado proferida em 19.06.2012 (fls. 2484-2489), de sorte que o processo não ficou paralisado pelo período mencionado pelos defendentes.

9. Ressalto, ademais, que, no referido período, o processo foi redistribuído em duas oportunidades: (i) em 7.1.2014, para o Diretor Roberto Tadeu, em razão do término do mandato do Diretor Otavio Yazbek, e (ii) em 27.1.2015, para mim, nos termos do art. 10 da Deliberação CVM nº 558/2008. De acordo com precedentes desta autarquia¹ e do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN², a designação de novo relator configura ato de impulsão do processo, apto a interromper a prescrição intercorrente.

10. Nessa mesma direção, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região já manifestou o entendimento de que *“quando a Administração pratica atos que impulsionam o processo, ainda que seja despacho de mero expediente, não estará caracterizada a inércia da mesma, não havendo, portanto, que se falar em prescrição intercorrente a que se refere o artigo 1º, §1º, da Lei nº 9.873/99”*³.

11. Em suma, considerando os atos praticados neste processo em 13.3.2013, 7.1.2014 e 27.1.2015, afasto a preliminar de extinção do processo em virtude da suposta ocorrência da prescrição intercorrente, de que trata o §1º do art. 1º da Lei nº 9.873/1999.

II. DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DO COLEGIADO QUE REJEITOU PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

12. Em seu pedido de reconsideração, Fabio Floh alegou, notadamente, a existência de fato novo, apto a justificar a reconsideração da decisão do Colegiado de 19.6.2012, que rejeitou a sua proposta de termo de compromisso. Tal fato novo consistiria na apresentação de proposta pelo único acusado que não a tinha feito ainda. Desse modo, segundo o acusado, não subsistiria mais o argumento, utilizado pelo Colegiado na aludida decisão, de que a aceitação da proposta não proporcionaria economia processual.

13. Em que pese ter razão – haja vista todos os acusados terem, afinal, apresentado proposta de termo de compromisso –, entendo que a celebração de acordo, no presente caso, não se mostra conveniente nem oportuna. Voto, portanto, pela rejeição do pedido de reconsideração, assim como seu deu em relação aos pedidos de reconsideração apresentados por Armando Buchina, Arthur Gilberto, Luis Álvaro, Nilton Muniz, Rodrigo Ferraz, Silvana Dino, Tarcísio Duque e Rodrigo Hoffmann, que foram indeferidos em reunião de Colegiado, em 20.10.2015.

III. DO SUPOSTO USO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA EM RELAÇÃO AO FATO RELEVANTE DIVULGADO EM 15.1.2010

14. Sendo assim, passo a examinar as condutas de Fabio Floh, Luis Álvaro, Nilton Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque, que alegaram não possuir qualquer conhecimento prévio do acordo de investimento com o fundo GEM, objeto do fato relevante divulgado em 15.1.2010, quando de suas operações de venda de BDRs da LAEP.

15. Em seguida, examinarei os negócios feitos por Othniel Lopes, Rodrigo Ferraz, Armando Buchina, Arthur Gilberto e Rodrigo Hoffmann, que teriam sido motivados, segundo eles, pela necessidade de recursos emergenciais da LAEP, para a qual foram emprestados os valores obtidos com as operações.

III.1. DA ACUSAÇÃO CONTRA FABIO FLOH, LUIS ÁLVARO, NILTON MUNIZ, SILVANA DINO E TARCÍSIO DUQUE

16. Fabio Floh, Luis Álvaro, Nilton Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque, executivos da Parmalat, à época uma companhia aberta em recuperação judicial, foram acusados pela SMI de violação ao art. 13, *caput*, da Instrução CVM nº 358/2002, combinado com o artigo

155, §4º, da Lei nº 6.404/1976, por terem alienado BDRs patrocinados por sua controladora indireta LAEP, companhia estrangeira, nas quantidades e valores relacionados abaixo, na posse de informação relevante ainda não divulgada ao mercado, a respeito de operação de capitalização da controladora por investidor externo.

Tabela 1: Negócios de Fabio Floh, Luis Álvaro, Nilton Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque.

Nome	Data	Vendas	Valor (R\$)
Fabio Floh	11.1.2010	90.000	270.600,00
	12.1.2010	50.000	119.400,00
	13.1.2010	10.000	22.000,00
	Total	150.000	412.000,00
Luis Álvaro	8.1.2010	91.500	320.250,00
	13.1.2010	50.000	127.500,00
	Total	141.500	447.750,00
Nilton Muniz	13.1.2010	650.000	1.450.000,00
Silvana Dino	13.1.2010	250.000	540.500,00
Tarcísio Duque	11.1.2010	150.000	450.000,00
	13.1.2010	300.000	657.000,00
	Total	450.000	1.107.000,00

17. O fato relevante em questão, anunciado em 15.1.2010, dizia respeito a um aporte de até R\$120 milhões a ser feito na LAEP pelo fundo estrangeiro GEM, por meio de uma operação de subscrição privada conhecida como PIPE – *Private Investment in Public Equity*.

18. De acordo com os acusados, eles não tinham, na data das operações (relacionadas na Tabela 1), conhecimento da operação com o fundo GEM, sendo que foram informados a respeito dela apenas em 14.1.2010, em reunião ocorrida na sede da LAEP. Essa versão dos fatos foi confirmada pela Companhia, segundo a qual os acusados somente teriam tomado ciência da operação na aludida reunião. A Companhia relatou ainda que de todos os acusados apenas Othniel Lopes, diretor-presidente da Parmalat e membro do conselho de administração da LAEP, e Rodrigo Ferraz, membro do conselho de administração e diretor de relações com investidores da LAEP e diretor jurídico e de relações com investidores da Parmalat, tiveram conhecimento das tratativas contratuais antes do dia 14.1.2010. (fls. 18-23).

19. De outra parte, os acusados ressaltaram que, à época dos fatos, ocupavam cargos e desempenhavam funções na Parmalat que não guardavam relação com a operação de capitalização da LAEP. Fabio Floh era gerente jurídico, Luiz Álvaro, diretor de unidade de negócios – Jundiaí, Nilton Muniz, diretor comercial, Silvana Dino, diretora de recursos humanos, e Tarcísio Duque, diretor industrial.

20. Vale ressaltar, a propósito, em linha com precedentes da CVM⁴, que o art. 13 da Instrução CVM nº 358/02 estabelece regras atinentes à valoração das provas que instruem os processos sancionadores nos quais são formuladas acusações de infração ao disposto nos §§ 1º e 4º do art. 155 da Lei nº 6.404/1976. Nessa direção, o que o mencionado art. 13 faz é esclarecer que a relação mais ou menos estreita mantida pelo acusado com a companhia à época dos fatos autoriza a presunção de determinados fatos que integram a configuração da prática de insider trading.

21. Assim, em relação à própria companhia e seus acionistas controladores, diretos ou indiretos, os diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, que negociaram na pendência de fato relevante, a norma reconhece ser legítimo inferir que tiveram acesso à informação privilegiada e, ainda, que negociaram com o intuito de obter vantagem⁵.

22. De outra parte, em relação às pessoas que, em virtude de seu cargo ou função na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tiveram conhecimento da informação, mostra-se pertinente presumir que, ao negociarem na pendência de fato relevante, agiram motivados pelo intuito de obter vantagem⁶.

23. Como se depreende da leitura do dispositivo, em relação a essas pessoas, admite-se a presunção do elemento subjetivo da infração, mas não da ciência da informação relativa ao fato relevante. Compete, portanto, à acusação demonstrar este elemento da infração por meio de provas (diretas ou indiretas) adicionais, como, por exemplo, a evidência de que o departamento ou setor no qual o investigado atuava na companhia ou em outra sociedade do grupo estava diretamente envolvido na operação, que seria objeto de fato relevante⁷.

24. Note-se, a propósito, que o art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002 não estabelece, a rigor, hipóteses de inversão do ônus da prova, o que, a meu ver, sequer seria aceitável em sede de processo administrativo sancionador. Antes disso, reconhece a admissão, nas situações ali descritas, da prova indireta mediante presunção simples, também denominada presunção judicial ou prova indiciária, a qual não se confunde com a presunção legal⁸.

25. A prova indiciária ou a presunção simples é amplamente admitida no direito penal pátrio, como se vê do seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

“1. O princípio processual penal do favor do rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções *hominis ou facti*, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do *ius puniendi*, máxime porque o Código de processo penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como “a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra, ou outras circunstâncias.” Doutrina (LEONE, Gionanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. V.II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. P.161-162) Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 06.10.2009, Dje-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 12-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 2. O julgador pode, através de um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, mediante raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta.”⁹

26. Com efeito, nos casos contemplados no art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002, a CVM considera determinado fato provado (e.g., o fato de o investigado ser administrador da companhia aberta) como indício hábil a autorizar, por indução, a conclusão quanto à

ocorrência de fatos que configuram a prática do *insider trading* (o conhecimento da informação relativa ao fato relevante pendente de divulgação e o intuito de obter de vantagem). Ou seja, esses elementos da infração são reputados provados pela CVM, até que o investigado ou acusado demonstre o contrário.

27. Significa dizer que, nas situações abrangidas pelo aludido art. 13, a CVM se desincumbe do ônus de provar a ocorrência do *insider trading*, mas o faz mediante prova indireta, com base em indício que, de acordo a experiência comum, é suficiente para estabelecer a prática da infração. Diante disso, compete ao investigado, ou acusado, indicar provas que contestem o indício (e.g., que ele não era administrador da companhia à época dos fatos) ou a própria presunção levada a cabo pela CVM (e.g, não obstante ser administrador, ele não teve acesso à informação privilegiada, ou então negociou premido por necessidades pessoais e urgentes, sem o intuito de obter vantagem).

28. Voltando ao caso concreto, constata-se que Fabio Floh, Luis Álvaro, Nilton Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque não se enquadravam no primeiro grupo relacionado no *caput* do art. 13 da Instrução CVM nº 358/02, já que não ocupavam cargos estatutários na LAEP, nem eram controladores dessa emissora. Por conseguinte, não se pode presumir *tout court* que estavam de posse de informação privilegiada ao negociarem na pendência do fato relevante, que seria divulgado no dia 15.1.2010.

29. Em linha com o disposto na segunda parte do art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002, o fato de ocuparem cargos na Parmalat, companhia controlada da LAEP, constitui indício importante, mas não suficiente, para estabelecer a conclusão de que conheciam a informação privilegiada.

30. Ciente disso, a SMI buscou, durante a instrução do processo, provas adicionais de que tais acusados, na data de suas operações, sabiam da operação com o fundo GEM. No entanto, a SMI não logrou obter uma prova direta nessa direção, tendo consignado no termo de acusação que não haveria, "*dentro das limitações da investigação conduzida, como obter evidência direta, cabal e definitiva a respeito do uso privilegiado da informação*".

31. Nada obstante, a área técnica considerou os fatos seguintes como indícios que, valorados em conjunto, fariam prova indiciária de que eles possuíam conhecimento prévio da operação com o GEM e teriam, assim, praticado *insider trading* nas alienações de BDRs que fizeram entre os dias 8.1 e 13.1.2010, antecipando-se à esperada queda das cotações do papel:

- a. Pela forma como foi estruturada, com emissão de novas ações em favor do investidor externo, cuja subscrição se daria a um preço inferior ao do mercado, a operação de capitalização implicaria uma diluição dos acionistas da LAEP, o que levaria a uma queda na cotação dos BDRs;
- b. Dez pessoas ligadas à LAEP, entre eles Fabio Floh, Luis Álvaro, Nilton Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque, venderam lotes significativos de BDRs entre os dias 08 e 14.1.2010, o que sugeriria que a informação sobre a iminente diluição de capital havia se disseminado entre os administradores às vésperas da divulgação do fato relevante;
- c. A coincidência quase perfeita entre os que negociaram e os que teriam sido comunicados da operação em 14.1.2010, na sede da Companhia;
- d. Como a sede da LAEP é em Bermudas, o local desta reunião, provavelmente, foi a sede da Parmalat, que é o mesmo que consta no Formulário Anual de

Informações – IAN da LAEP como do Departamento de Acionistas, o que demonstraria não haver separação clara entre as administrações das duas pessoas jurídicas e reforçaria o argumento de que a informação relevante circulou previamente entre os envolvidos;

- e. Sendo administrador tanto da LAEP como da Parmalat, Othniel Lopes poderia, portanto, ter informado aos acusados que trabalhavam para a Parmalat sobre a operação entre LAEP e GEM;
- f. A trajetória de alta em que estava a cotação dos BDRs da LAEP teria sido interrompida pela divulgação do fato relevante em 15.1.2010, demonstrando o oportunismo das vendas dos acusados; e
- g. As vendas teriam sido atípicas, pois com exceção de negócios esporádicos de Luis Álvaro, os acusados não haviam negociado BDRs nos meses anteriores a janeiro de 2010.

32. No entanto, consolidou-se, no âmbito desta Autarquia, o entendimento de que *“não é qualquer indício que enseja a condenação, mas a prova indiciária, quando representada por indícios graves, precisos e concordes que levem a uma conclusão robusta e fundamentada acerca do fato que se quer provar”*¹⁰.

33. Logo, em casos como o presente, cabe ao julgador aquilatar se os indícios arrolados pela acusação, tomados individualmente e em seu conjunto, têm força e credibilidade para comprovar a ocorrência da infração, em face dos contraindícios apresentados pela defesa¹¹.

34. No caso ora em apreço, ao analisar, um a um e em seu conjunto, os indícios apresentados pela Acusação e os argumentos e contraindícios colocados, em sentido contrário, pelas defesas, não me convenci de que os acusados tinham, de fato, ciência da operação com o GEM, por ocasião das negociações com BDRs realizadas antes da divulgação do fato relevante de 15.1.2010.

35. Quanto ao primeiro indício trazido pela Acusação, segundo o qual o acordo de investimento entre LAEP e GEM teria gerado a expectativa de queda na cotação dos BDRs, os defendentes contra-argumentaram que deveria ser levado em consideração o viés positivo do fato relevante, que anunciou o aporte de capital por um novo investidor. Nessa direção, alegaram que não era possível antever que a divulgação do fato relevante teria impacto negativo na cotação do papel.

36. Acredito assistir razão aos acusados. Considerando a situação econômico-financeira enfrentada, à época, por LAEP e Parmalat, esta última em recuperação judicial, parece-me, ao menos, plausível que o anúncio de injeção de recursos vultosos pelo fundo GEM, da ordem de R\$120 milhões, gerasse expectativa positiva junto aos investidores. Se não é suficiente para afastar a previsibilidade do viés negativo do fato relevante, tal argumento, ao menos, enfraquece o indício utilizado pela Acusação para estabelecer a conclusão quanto à ocorrência do insider trading.

37. Outro indício trazido pela Acusação foi a coincidência de dez pessoas ligadas à LAEP venderem lotes grandes de BDRs na semana que antecedeu a sua divulgação, coincidência esta que seria explicada, segundo a SMI, pela disseminação, entre os Acusados, da informação sobre a operação com o fundo GEM.

38. Além disso, sendo a sede da Parmalat no mesmo endereço do Departamento de Acionistas da LAEP, e sendo Othniel Lopes diretor tanto da LAEP quanto da Parmalat,

haveria tanto um ambiente quanto um canal para que a informação fluísse para os acusados que eram executivos da Parmalat.

39. Em relação à forma como eram organizadas as estruturas administrativas da LAEP e da Parmalat, em termos de localização física e organizacional, em que pese a coincidência de endereços, não há nos autos, além deste fato, outros elementos que permitam concluir que os acusados, vinculados administrativamente à controlada, teriam acesso às decisões e questões afeitas à controladora, não tendo a Acusação se desincumbido de demonstrar como se daria ou poderia se dar este acesso.

40. Quanto à coincidência das negociações em período simultâneo, reconheço que há plausibilidade na hipótese da Acusação, já que, conforme informado pela LAEP, a operação foi desenhada exatamente no período em que os acusados venderam seus papéis, tendo as primeiras minutas circulado em 8.1.2010, seguidas de negociações e revisões, até a assinatura dos documentos definitivos, entre a noite de 14.1 e a manhã de 15.1.2010¹².

41. No entanto, como não foi obtida prova direta de que esses cinco acusados, na data de suas operações, sabiam da operação com o fundo GEM, seriam necessários, a meu ver, outros elementos concretos, além dessa coincidência, para que se formasse um conjunto convergente de indícios que permitisse presumir, com razoável grau de certeza, que eles tinham conhecimento da informação.

42. E os indícios restantes coletados pela Acusação, a meu ver, também não contribuem para isto. Refiro-me, primeiramente, a afirmação de que as vendas dos acusados teriam sido atípicas, já que eles não negociaram BDRs nos meses anteriores a janeiro de 2010, com exceção de negócios esporádicos de Luis Álvaro.

43. De fato, a atipicidade dos negócios é indício comumente associado a práticas de insider trading, porém, em casos como o presente, entendo que a sua relevância deve ser mitigada, pois os valores mobiliários alienados pelos acusados, previamente ao fato relevante divulgado em 15.1.2010, tinham sido adquiridos no âmbito do plano de remuneração da LAEP e de acordo com as condições definidas nesse plano. Além disso, como eram, à época dos fatos, executivos da Parmalat, os acusados estavam submetidos a períodos de vedação a negociação, de modo que a habitualidade ou a sua ausência nas negociações deve ser examinada tendo em conta as restrições estabelecidas não apenas no plano de remuneração como também na política de negociação.

44. Por fim, refiro-me ao suposto oportunismo das vendas dos acusados, que venderam após trajetória de alta que teria sido interrompida pela divulgação do fato relevante em 15.1.2010. Creio que, neste ponto, em vista do até aqui relatado, talvez se possa falar em oportunidade, e não em oportunismo.

45. De fato, os acusados detinham significativos lotes de BDRs, recebidos no âmbito de plano de remuneração, cujo valor havia subido significativamente em 30 dias, alta esta em relação a qual a SMI, após exaustiva análise, não encontrou sinais de ter sido causada por manipulação¹³. No entanto, conforme alegou Fabio Floh, não era permitido negociar os papéis até 22.12.2009, em função do atraso na apresentação dos 1º, 2º e 3º ITRs de 2009 da LAEP¹⁴. Somente em 23.12.2009 abriu-se a janela para a venda.

46. Além disso, havia um sério risco de falência das empresas, sinalizando o risco de perda drástica do valor do investimento. Os documentos trazidos aos autos comprovam, a meu ver, que na semana de 8.1.2010 a 14.1.2010, a LAEP e a Parmalat viviam uma aguda crise financeira, da qual discorrerei adiante, estando, naquele período, com uma fábrica bloqueada e a outra em vias de interdição, e tendo que se socorrer a empresas de *factoring* para suprir suas necessidades de caixa.

47. Esta crise, além de ser de conhecimento público, certamente era sentida no dia a dia por seus executivos operacionais e, dentro desse quadro, e em face da alta sofrida pelo papel, entendo que seria racional que eles quisessem liquidar suas posições.

48. Evidentemente, estivessem eles de posse da informação sobre o fato relevante divulgado em 15.1.2010, teriam agido ilicitamente ao alienarem seus BDRs. No entanto, os indícios nesse sentido identificados pela Acusação, supra-analisados, não me convenceram de que teria havido a ciência prévia.

49. Além da ausência de conjunto sólido de indícios, os argumentos, documentos e informações trazidos aos autos pelas defesas me fazem concluir que havia outras explicações possíveis para a alienação de BDRs pelos acusados, entre os dias 8.1.2010 e 14.1.2010, que retiram o caráter unívoco da hipótese acusatória levantada pela SMI.

50. Com efeito, Fabio Floh alegou que, em vista da péssima situação financeira da Companhia, ansiava por poder vender os papéis, e que, conforme já relatado, não era permitido negociar os papéis até 22.12.2009, em função do atraso na apresentação dos 1º, 2º e 3º ITRs de 2009 da LAEP.

51. Luis Álvaro, Nilton Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque afirmaram, por sua vez, que venderam seus papeis em virtude da forte alta experimentada por eles a partir de dezembro de 2009. De fato, conforme consta do relatório, os BDRs da LAEP foram de R\$0,63 em 15.12.2009 para R\$3,55 em 08.01.2010, oscilação que a SMI creditou a notícias que circulavam na imprensa, não tendo conseguido vinculá-la à operação futura com o GEM.

52. A meu ver, esses argumentos, portanto, enfraquecem a alegação de que a alienação dos papeis pelos acusados teria sido motivada pela suposta ciência da operação de capitalização. Havia outras explicações plausíveis para isso, o que, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, deve conduzir à absolvição dos acusados.

53. Voto, portanto, pela absolvição de Fabio Floh, Luis Álvaro, Nilton Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque da acusação de infração ao disposto no *caput* do art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002, c/c o art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976, por ocasião das negociações realizadas no período antecedente à divulgação do fato relevante em 15.1.2010.

III.2. DA ACUSAÇÃO CONTRA OTHNIEL LOPES, RODRIGO FERRAZ, ARMANDO BUCHINA, ARTHUR GILBERTO E RODRIGO HOFFMANN.

54. Passo então a examinar a acusação formulada em face de Othniel Lopes, Rodrigo Ferraz, Armando Buchina, Arthur Gilberto e Rodrigo Hoffmann, de acordo com a qual teriam violado o disposto no art. 13, *caput*, da Instrução CVM nº 358/2002, combinado com o artigo 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976, por terem alienado BDRs patrocinados pela LAEP, de posse de informação relevante ainda não divulgada ao mercado, a respeito do acordo de investimento entre a Companhia e o fundo GEM.

Tabela 2: Negócios de Othniel Lopes, Rodrigo Ferraz, Armando Buchina, Arthur Gilberto e Rodrigo Hoffmann.

Nome	Data	Vendas	Valor (R\$)
Othniel Lopes	13.1.201	400.000	897.800,00
	15.1.201	2.300.00	5.770.694,00(*)

	Total	2.700.00 ^(*)	6.668.494,00
Rodrigo Ferraz	14.1.201	1.800.00 ^(*)	4.977.560,00 ^(*)
Armando Buchina	13.1.201	150.000	330.000,00
	15.1.201	300.000 ^(*)	756.000,00 ^(*)
	Total	450.000	1.086.000,00
Arthur Gilberto	14.1.201	800.000 ^(*)	2.185.884,00 ^(*)
Rodrigo Hoffmann	8.1.2010	200.000 ^(*)	531.600,00 ^(*)

(*) BDRs alienadas para empréstimo dos recursos para a LAEP

55. À época dos fatos, Othniel Lopes era diretor-presidente da Parmalat e membro do conselho de administração da LAEP, Rodrigo Ferraz, membro do conselho de administração e diretor de relações com investidores da LAEP e diretor-jurídico e de relações com investidores da Parmalat, Armando Buchina, diretor de tecnologia da informação da Parmalat, Arthur Gilberto, diretor de operações da Parmalat e Rodrigo Hoffmann, gerente executivo financeiro da Parmalat. Todos adquiriram os BDRs negociados no âmbito do plano de remuneração da LAEP¹⁵.

56. Primeiramente, vou analisar as operações realizadas por Othniel Lopes, Rodrigo Ferraz, Armando Buchina, Arthur Gilberto e Rodrigo Hoffmann. Para cada uma dessas operações, há, nos autos, um contrato de mútuo entre o alienante dos BDRs, como mutuante, e LAEP/Parmalat, como mutuárias, sendo o valor mutuado bruto o montante financeiro arrecadado nas alienações dos papéis.

57. Estes negócios foram realizados assumidamente com conhecimento da operação com o GEM, à exceção da venda feita por Rodrigo Hoffmann, o qual foi acusado de *insider trading* por que haveria prova indiciária de que ele sabia do acordo com o GEM quando negociou em 8.1.2010. Quanto aos demais, apurou-se que Othniel Lopes participou das tratativas da operação com o GEM desde 9.12.2009. Rodrigo Ferraz tomou conhecimento em 7.1.2010. Armando Buchina e Arthur Gilberto tiveram ciência na reunião de 14.1.2010.

58. Em apertada síntese, esses quatro acusados alegaram, em sua defesa, que o §7º do art. 13 da Instrução CVM nº 358/02¹⁶ abre exceções à regra geral de vedação à negociação de posse de informação privilegiada em relação aos negócios realizados em conformidade com Política de Negociação aprovada nos termos do artigo 15 da mesma Instrução¹⁷, entendendo esse que teria sido referendado pelo Ofício Circular/CVM/SEP/nº 04/2011.

59. Essas exceções, alegam, alcançariam as alienações de BDRs relacionadas acima, realizadas por eles quando já tinham conhecimento do acordo de investimentos a ser firmado entre LAEP e GEM.

60. A permissão para a negociação de valores mobiliários patrocinados pela LAEP na pendência de divulgação de fato relevante estaria prevista no item 35 da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão Própria da LAEP, arquivada na CVM, em 6.11.2007, permissão essa que, segundo os acusados, seguiu o mesmo padrão adotado por outras companhias:

35. A negociação com Valores Mobiliários por Pessoas Vinculadas durante os períodos de não negociação, conforme previstos nesta Política de Negociação, poderá ser excepcionalmente autorizada pela Diretoria da Companhia, mediante solicitação apresentada por escrito contendo a justificativa da necessidade da negociação.

61. Assim, na medida em que as suas alienações de BDRs dos dias 14 e 15.1.2010 foram justificadamente autorizadas pela Diretoria da LAEP em 14.1.2010, em função da necessidade de recursos emergenciais, e também autorizadas, na mesma data pelo Conselho de Administração, estariam elas, segundo os defendentes, enquadradas no item 35 da Política de Negociação da LAEP.

62. Discordo dos acusados. Primeiramente, observo que a exceção em tela refere-se ao “período de não negociação”, título da Seção V da Política de Negociação da LAEP, que assim o define em seu art. 18:

18. As Pessoas Vinculadas deverão abster-se de realizar quaisquer negociações com Valores Mobiliários no período de 15 (quinze) dias que anteceder a divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP e IAN) exigidas pela CVM.

63. Ou seja, trata-se de exceção à proibição de negociar antes da divulgação de demonstrações financeiras, imposta pelo §4º do art. 13 da Instrução CVM nº358/02¹⁸ e também excepcionadas pelo §3º de seu art. 15¹⁹.

64. Entendo, ademais, que a Política de Negociação não poderia sobrepor-se à lei e autorizar alguém a negociar valores mobiliários valendo-se de informação privilegiada. Noto, aliás, que essa é a orientação expressamente acolhida no item 3 da Política de Negociação da LAEP:

3. A adoção da presente Política de Negociação objetiva fixar parâmetros e limites específicos para a negociação com Valores Mobiliários por parte de seus destinatários, mantendo-se, contudo, a vedação absoluta de utilização de informação em relação a Fato Relevante, ainda não divulgado, para obter, para si ou para outrem, vantagem no mercado de valores mobiliários.

65. O que a Política de Negociação pode e deve fazer é estabelecer regras destinadas a evitar que as negociações realizadas por pessoas usualmente expostas a informações privilegiadas, como são os administradores, configurem *insider trading*. No entanto, e me parece importante frisar esse ponto, o Conselho de Administração não tem autonomia, sob pena de ferir a lei, de estipular Política de Negociação que admita que pessoa a ela vinculada possa decidir negociar valores mobiliários referentes à companhia, valendo-se de informação relevante ainda não divulgada ao público.

66. Dito diversamente, é a Política de Negociação que deve ser amoldar às prescrições legais, e não o contrário. Não é dado ao conselho de administração, nem mesmo à assembleia geral de acionistas, autorizar quem quer que seja a infringir as vedações estabelecidas nos §§ 1º e 4º da Lei nº 6.404/1976. O que se mostra lícito é prever, na Política de Negociação, regras que evitem a ocorrência da conduta típica estabelecida nos referidos dispositivos legais.

67. Feito esse esclarecimento, passo a examinar o argumento apresentado por Othniel Lopes, Rodrigo Ferraz, Armando Buchina e Arthur Gilberto, de que as alienações de BDRs por eles realizadas em 14 e 15.1.2010, foram feitas para suprir a LAEP e a Parmalat com

recursos emergenciais, e, por isso, não teriam sido feitas com a finalidade de obter vantagem.

68. Nesse tocante, a análise dos documentos acostados aos autos me convenceu de que as operações foram realizadas de modo a permitir o empréstimo de recursos à LAEP e à Parmalat, que atravessavam, naquele momento, uma crise de liquidez aguda.

69. Em particular, conforme documentos trazidos aos autos, as dívidas com produtores e fornecedores dessas duas unidades totalizavam cerca de R\$ 33 milhões, e para fazer frente a necessidades de caixa, as sociedades recorriam a empresa de *factoring*, que cobrava juros de 4.5% ao mês para o desconto de títulos e a concessão de financiamento de curto prazo. Em 14.1.2015, a Companhia mantinha duas linhas de crédito com a empresa de fomento, com saldos devedores de R\$55.085.894,25 e R\$24.212.364,35. Este quadro foi atestado por parecer econômico-contábil anexado pelos defendentes, que me parece ter sido elaborado com a técnica e o rigor necessários.

70. Além disso, no período em apreço, a Parmalat estava com a sua planta industrial de Santa Helena/GO bloqueada judicialmente, com ordem de arresto de bens e produtos (fls. 1541-1562). Além disso, devido ao atraso no pagamento a produtores e cooperativas, a planta de Itaperuna estava em vias de sofrer intervenção por parte do Governo do Estado do Rio de Janeiro, conforme documento enviado à Companhia em 15.1.2010 (fls. 935-936) e notícia publicada na imprensa em 15.1.2010 (fl. 1102). Toda esta situação estava amplamente divulgada, à época, conforme notícias então veiculadas na imprensa e juntadas aos autos (fls. 1080-1109 e 1161-1175).

71. Em suma, os elementos de prova dos autos permitem firmar a convicção de que, entre os dias 14 e 15.1.2010, havia a necessidade urgente de conseguir recursos financeiros para conseguir o desbloqueio da unidade de Santa Helena e evitar a intervenção na planta de Itaperuna, evitando a interrupção definitiva da produção e do fluxo de caixa dessas duas plantas, que representavam, em conjunto, cerca de 60% da capacidade produtiva e de faturamento da Parmalat, conforme documento acostado à fl. 2157.

72. E esses recursos foram conseguidos por meio dos empréstimos efetuados por Othniel Lopes, Rodrigo Ferraz, Armando Buchina, Arthur Gilberto e Rodrigo Hoffmann, que injetaram cerca de R\$14 milhões no caixa da Companhia, o equivalente a 42% do montante total de dívidas de curto prazo com produtores e cooperativas em 14.1.2010. Segundo os documentos apresentados, e conforme atestado pelo parecer econômico-contábil anexado, após o desconto de taxas e abatimentos de conta corrente junto à empresa de fomento, os recursos foram direcionados ao pagamento aos pequenos produtores das regiões de Itaperuna/RJ e Santa Helena/GO, entre os dias 15 e 18.1.2010.

73. A meu ver, portanto, as negociações realizadas pelos acusados Othniel Lopes, Rodrigo Ferraz, Armando Buchina e Arthur Gilberto nos dias 14 e 15.1.2010 não foram motivadas pela expectativa de tirar vantagem da informação privilegiada referente ao acordo a ser firmado com o GEM, mas, sim, pelo intuito de socorrer financeiramente a LAEP e a Parmalat, que se encontravam premidas pela urgente necessidade de caixa.

74. Note-se, a propósito, que este Colegiado já examinou situação semelhante à do presente caso, tendo concluído que o acionista controlador que, na pendência de divulgação de fato relevante, negocia ações de companhia aberta com o fim de levantar recursos financeiros emergenciais em favor daquela, não incorre na conduta típica do *insider trading*, vez que ausente o desígnio de usar a informação privilegiada para obter vantagem²⁰.

75. Em relação às condições dos empréstimos, creio que a taxa de juros negociada (CDI + 0,5% ao mês) foi favorável à Companhia, tendo em vista a taxa de 4.5% ao mês que ela estava pagando a empresas de *factoring*. Já o fato de a Companhia ter arcado com os tributos incidentes sobre as vendas, aspecto que foi contestado pela Acusação, entendo como razoável que essa condição tenha sido exigida pelos mutuantes em contrapartida ao risco que incorreram ao emprestar recursos a sociedades em situação pré-falimentar.

76. Da mesma forma, parece-me razoável que a empresa de *factoring* exigisse o abatimento de parte da dívida consolidada para que adiantasse à Companhia os recursos que seriam emprestados pelos acusados. Ao contrário do que alega a Acusação, essa circunstância, a meu ver, não enfraquece a versão dos fatos apresentada pelos acusados, de que teriam alienado os BDRs de modo a conseguir emprestar recursos à Companhia.

77. Por fim, entendo que as inconsistências levantadas pela Acusação nos contratos de mútuo, algumas na casa dos centavos, podem ser creditadas a erros formais, sem influência sobre o que aqui foi discutido.

78. Voto, portanto, em virtude do acima exposto, pela absolvição de Othniel Lopes, Rodrigo Ferraz, Armando Buchina e Arthur Gilberto da acusação de infração ao disposto no *caput* do art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002, c/c o art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976, no que diz respeito às negociações com BDRs realizadas nos dias 14 e 15 de janeiro de 2010.

79. Quanto a Rodrigo Hoffmann, gerente executivo financeiro da Parmalat, apesar de ter firmado contrato de empréstimo com a LAEP/Parmalat em 15.1.2010, alienou BDRs em 8.1.2010.

80. Na sua defesa, alegou que a Companhia, em 15.1.2010, solicitou-lhe que vendesse os BDRs recebidos em plano de remuneração e lhe emprestasse os recursos. No entanto, como já havia vendido os papéis em 8.1.2010, após o período de *blackout*, e comprado ações de outra companhia, em 12.1.2010, assinou mútuo com a LAEP e a Parmalat no mesmo dia 15.1.2010, tendo os recursos sido adiantados pela empresa de *factoring*. Em 18.1.2010, vendeu os papéis adquiridos em 12.1 para honrar sua obrigação.

81. Disse ter agido assim para que a LAEP pudesse quitar suas dívidas junto aos fornecedores de leite e não interrompesse as suas atividades, e que, com essa conduta, visou a proteger os interesses da Companhia.

82. A Acusação não conseguiu apurar se ele saberia da operação com o GEM já em 8.1.2010, data de sua negociação, tendo sido acusado com base nos mesmos indícios já apontados para Fabio Floh, Luis Álvaro, Nilton Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque.

83. Assim como se verificou em relação a esses últimos, tais indícios não me convenceram de que Rodrigo Hoffmann tenha negociado, em 8.1.2010, de posse de informação privilegiada. Destaco, nessa direção, que o cargo ocupado pelo acusado – a gerência financeira da Parmalat – não autoriza a presunção de que ele tinha acesso a informações sobre o acordo a ser firmado com o GEM. Ademais, ele não foi citado pela Companhia como um dos participantes das tratativas sobre o acordo.

84. Note-se também que o seu empréstimo foi feito com recursos obtidos com a venda de outro papel, e não com BDRs da LAEP, o que, a meu ver, reforça a versão segundo a qual os acusados teriam negociado com o intuito de prover recursos emergenciais à Companhia.

85. Voto, portanto, pela absolvição de Rodrigo Hoffmann da acusação de infração ao disposto no *caput* do art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002, c/c o art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976, em relação à alienação de 150.000 BDRs efetuada em 8.1.2010.

86. Por fim, resta analisar as vendas feitas por Othniel Lopes e Armando Buchina, relacionadas na Tabela 2 supra, antes da divulgação, em 15.1.2010, do acordo de investimento entre LAEP e GEM.

87. Primeiramente, trato da operação de venda feita por Armando Buchina, por guardar similaridade com as operações realizadas por Fabio Floh, Luis Álvaro, Nilton Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque, que apreciei anteriormente.

88. De fato, Armando Buchina, executivo operacional da Parmalat, diretor de tecnologia da informação, também teria sido comunicado da operação com o GEM em 14.1.2010, conforme informação da LAEP e dele próprio, tendo sido acusado, quanto à alienação que fez em 13.1.2020, com base nos mesmos indícios usados contra os outros.

89. Em sua defesa, ele alegou que não se utilizou de informação relevante nesta alienação, que teria sido feita dentro do limite autorizado por seu Plano Individual de Investimento, e que como a operação com o fundo GEM levaria a uma valorização das cotações dos BDRs da LAEP, não poderia se dizer que a venda de BDRs teria sido feita com o intuito de evitar uma perda financeira esperada.

90. Independentemente destas justificativas, pelas razões já expostas em relação a Fabio Floh, Luis Álvaro, Nilton Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque, entendo que não ficou comprovado que Armando Buchina tenha negociado, no dia 13.1.2010, de posse de informação privilegiada.

91. Voto, portanto, pela absolvição de Armando Buchina da acusação de infração ao disposto no *caput* do art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002, c/c o art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976, em relação à alienação de 150.000 BDRs efetuada em 13.1.2010.

92. No caso de Othniel Lopes, este tomou ciência das tratativas com o GEM desde 9.12.2009, ou seja, ele já sabia do fato relevante quando fez as vendas em 13.1.2010.

93. Alegou, todavia, que não se utilizou desta informação na operação, pois esta teria sido feita dentro do limite autorizado por seu Plano Individual de Investimento, bem como não teria almejado a obtenção de vantagem econômica, pois tinha a expectativa de que a operação com o fundo GEM levaria a uma valorização das cotações dos BDRs da LAEP, e não uma queda.

94. Não concordo com os argumentos apresentados pelo acusado. É fato incontroverso, amplamente documentado nos autos, que Othniel Lopes era administrador (estatutário) da LAEP e, ao negociar BDRs no dia 13.1.2010, tinha pleno conhecimento dos termos do acordo a ser firmado com o fundo GEM, que seria objeto do fato relevante divulgado em 15.1.2010.

95. Além disso, ao contrário do que se observou na negociação realizada no dia 15.1.2010, a alienação de 400.000 BDRs no dia 13.1.2010 não foi efetuada em virtude da necessidade de prover recursos à Companhia. Verifica-se, ao contrário, que ela foi realizada pelo acusado por razões pessoais, de acordo com a sua avaliação de que o momento era oportuno para vender os papéis. Sendo assim, deve prevalecer, em relação ao negócio do dia 13.1.2010, o entendimento de que foi motivado pela expectativa de tirar vantagem da informação relevante ainda não divulgada ao público.

96. Note-se, por oportuno, que, por ser administrador da LAEP, Othniel Lopes se enquadrava no preceito estabelecido na primeira parte do art. 13 da Instrução CVM 358/2002, presumindo-se, em consequência, que tenha negociado com o intuito de obter vantagem. E, nesse tocante, o acusado não apresentou, em sua defesa, qualquer argumento apto a afastar essa presunção.

97. De outra parte, não se mostra pertinente, para fins de apuração da prática de *insider*, o argumento de que teria negociado dentro dos limites do seu Plano Individual de Investimento, que autorizava a alienação ou a aquisição de até 1.200.000 BDRs por mês. Se é verdade que a Instrução CVM nº 358/2002, em seu art. 13, §7º²¹, considera regulares as negociações amparadas na política de negociação da companhia, ainda que efetuadas na pendência da divulgação de fato relevante, também é verdade que esse preceito alcança apenas as negociações efetuadas com base no "*compromisso irrevogável e irretratável de seus participantes de investir valores previamente estabelecidos, nas datas nele previstas*", como prescreve textualmente o art. 15, §3º, II, a, da Instrução CVM nº 358/2002²².

98. Significa dizer, como já observado na doutrina²³ e nas decisões da CVM²⁴, que o administrador que compre ou venda valores mobiliários na pendência de fato relevante, amparado em plano de investimento aprovado pela companhia, não incorre na prática de *insider trading* na medida (e apenas na medida) em que o momento de realização do negócio e o seu montante tenham sido previamente determinados no aludido plano. A razão da norma é clara: como a decisão de negociar foi previamente definida, o fato de o administrador vir a ter, posteriormente, conhecimento de alguma informação privilegiada não terá qualquer influência na realização da transação. Desta feita, o administrador fica impedido de tirar proveito da informação na hora de negociar.

99. No entanto, no caso do Plano Individual de Investimento arquivado por Othniel Lopes na LAEP, como bem apontado no item 122 do termo de acusação, o signatário tinha liberdade para negociar até o limite mensal de 1.200.000 BDRs, conforme as cláusulas 2-c e 2-d (fl. 624).

100. Não havia datas e quantidades estipuladas, ou seja, não estavam predeterminados os negócios que seriam feitos dentro de seu âmbito. As cláusulas do Plano conferiam a Othniel Lopes plena discricionariedade para escolher o momento que considerasse mais oportuno para realizar os negócios e, portanto, não o impediam de tirar proveito de eventual informação privilegiada para decidir se iria ou não negociar BDRs patrocinados pela LAEP.

101. Sendo assim, é de concluir-se que o fato de a venda em 13.1.2010 de 400.000 BDRs ter sido efetuada no âmbito do Plano Individual de Investimento aprovado pela LAEP não afasta a ocorrência de infração por Othniel Lopes à vedação estabelecida no art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002, c/c o art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976. Ao reverso, verifica-se que, naquela oportunidade, Othniel Lopes poderia ter-se absterido de negociar e, nada obstante, decidiu alienar os BDRs, muito embora estivesse de posse de informação relevante, que somente seria divulgada ao mercado dias depois.

102. Voto, portanto, pela condenação de Othniel Lopes por infração ao disposto no *caput* do art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002, c/c o art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976, em relação à alienação de 400.000 BDRs efetuada em 13.1.2010.

IV. DO SUPOSTO USO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA EM RELAÇÃO AO FATO RELEVANTE DIVULGADO EM 28.1.2010.

103. Passo então a examinar as acusações de uso de informação privilegiada relativa ao fato relevante divulgado em 28.1.2010, após o encerramento do pregão. Por meio do referido fato relevante, a LAEP informou a conversão de parte de sua dívida com *"importantes credores estratégicos"* em ações classe A. Esta operação foi deliberada na reunião do conselho de administração da LAEP realizada em 14.1.2010, conforme ata às fls. 627 a 633.

104. Na medida em que nenhum dos acusados fez qualquer referência a esta operação, quando inquiridos pela SMI, e que no entendimento da área técnica ela também implicava numa diluição do capital da LAEP, a Acusação considerou que as alienações realizadas entre os dois fatos relevantes, no período de 15.1 a 28.1.2010, também foram feitas de posse de informação privilegiada.

105. Assim, passo a apreciar a acusação contra Othniel Lopes e Luís Álvaro, de violação ao art. 13, *caput*, da Instrução CVM nº 358/2002, combinado com o artigo 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976, por terem alienado BDRS patrocinados pela LAEP, de posse de informação relevante ainda não divulgada ao mercado, a respeito de conversão de parte da dívida da Companhia em capital.

Tabela 3: Negócios de Othniel Lopes e Luís Álvaro.

Nome	Data	Vendas	Valor (R\$)
Othniel Lopes	18.1.201	400.000	1.020.468,
	20.1.201	350.000	927.500,00
	Total	750.000	1.947.968,
Luís Álvaro	28.1.201	150.000	382.000,00

106. Preliminarmente, aprecio a alegação de Luis Álvaro de que teria sido violado o seu direito de defesa prévia em relação ao fato relevante divulgado pela LAEP em 28.1.2010, pois o ofício recebido da CVM, nos termos do art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008, apenas teria solicitado esclarecimentos acerca dos negócios efetuados na pendência do fato relevante divulgado em 15.1.2010.

107. Não entendo desta forma. A operação de capitalização datada de 28.1.2010 encontra-se expressamente mencionada no item 6 do aludido ofício (fls. 527-529) e a questão contida no item 13 referia-se tanto aos negócios realizados antes do fato relevante divulgado no dia 15.1.2010 quanto àqueles efetuados na pendência do fato relevante do dia 28.1.2010.

108. Noto, ademais, que, ainda durante a vigência do art. 6º-B da Deliberação CVM nº 457/2002, que precedeu o art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008, o Colegiado teve a oportunidade de esclarecer que a prévia manifestação do investigado *"não confere um direito subjetivo aos indiciados nem se consubstancia em uma defesa prévia, sendo medida única e exclusiva de eficiência administrativa, com o objetivo de evitar acusações descabidas e melhorar o nível probatório dos processos administrativos, buscando, ao final, a instauração apenas de processos sancionadores justificados e que sejam instruídos com qualidade (...)"*²⁵.

109. Já sob a vigência da nova Deliberação, o Colegiado decidiu, seguindo a mesma orientação, que a finalidade de seu art. 11 consiste em *"proteger e viabilizar o exercício do poder de polícia pela CVM. Com efeito, a oitiva preliminar tem por objetivo tão somente*

dar suporte à formação da convicção da área técnica quanto à materialidade e a autoria das infrações e auxiliar na boa instrução do processo, durante a etapa investigativa de que trata o art. 9º, §2º, da Lei nº 6.385, de 7.12.1976. O dispositivo não confere, portanto, um direito subjetivo aos investigados, nem deve ser confundido com defesa prévia”²⁶.

110. Não tem, portanto, o art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008, relação com o contraditório e o exercício da ampla defesa. Desse modo, eventual equívoco no seu cumprimento, ainda que existente, não resultaria na nulidade do processo administrativo sancionador. Observo, também, que, no presente processo, Luis Álvaro exerceu seu direito de defesa, às fls. 2255 a 2291, contestando integralmente a peça acusatória, de modo que não teria sofrido qualquer prejuízo, ainda que se verificasse o descumprimento ao art. 11.

111. Quanto ao mérito, no entanto, dou razão a Luis Álvaro. Não há nos autos qualquer prova que demonstre a sua participação na realização da operação de conversão de dívida anunciada no dia 28.1.2010, ou que, ao menos, faça presumir que dela tinha conhecimento.

112. Voto, assim, pela absolvição de Luís Álvaro da acusação de infração ao disposto no *caput* do art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002, c/c o art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976, em relação à alienação de 150.000 BDRs efetuada em 28.1.2010.

113. Quanto a Othniel Lopes, este alegou que as alienações de 400.000 BDRs, em 18.1.2010, e 350.000 BDRs, em 20.1.2010, foram feitas dentro dos limites permitidos por seu Plano Individual de Investimento, pelo qual poderia alienar até 1.200.000 BDRs por mês.

114. Constatado que, na qualidade de conselheiro de administração da LAEP, Othniel participou da reunião que autorizou o Presidente da Companhia a *"emitir 137 milhões de Ações Classe A para pagar credores (conversão da dívida em investimento) com o objetivo de reduzir drasticamente a dívida atual da Sociedade"*, exatamente o que foi publicado como fato relevante em 28.1.2010 (fl. 11).

115. Em vista disso, resta incontroverso que, não obstante ter conhecimento desde o dia 14.1 da operação de conversão de dívida que seria divulgada ao mercado no dia 28.1, Othniel Lopes negociou BDRs nos dias 18 e 20.1.2010. Aqui, novamente, o acusado não logrou comprovar que a negociação tenha sido motivada por outra razão senão pelo intuito de obter vantagem. Nesse tocante, limitou-se a alegar que as transações foram realizadas dentro dos limites previstos no seu Plano Individual de Investimento.

116. No entanto, o argumento não procede e, por consequência, não afasta a ocorrência da infração ao disposto no *caput* do art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002, c/c o art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976. A esse respeito, remeto as razões já expostas acima por ocasião do exame da acusação relativa ao negócio realizado em 13.1.2010.

117. Em síntese, como já mencionei, o referido Plano Individual não definia, em termos irrevogáveis e irretratáveis, as datas nem os valores das operações que seriam efetuadas por Othniel. Ao reverso, Othniel tinha plena liberdade para escolher o momento que considerasse mais oportuno para realizar os negócios. Consequentemente, nos dias 18 e 20.1, Othniel Lopes decidiu vender BDRs patrocinados pela LAEP, levando em conta a informação privilegiada que tinha a respeito da operação que seria anunciada ao mercado no próximo dia 28.

118. Voto, portanto, pela condenação de Othniel Lopes por infração ao disposto no *caput* do art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002, c/c o art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976, em relação à alienação de 400.000 BDRs em 18.1.2010 e de 350.000 BDRs em 20.1.2010.

V. CONCLUSÃO

119. Por todo o exposto, voto pela absolvição de Fabio Floh, Luiz Álvaro Moreira Ferreira Filho, Nilton Batista Muniz, Silvana Dino, Tarcísio Antônio de Rezende Duque, Rodrigo Andrés Pimenta Hoffmann e Armando Tadeu Buchina da imputação de infração ao disposto no caput do art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002, c/c o art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976, no que diz respeito às alienações de BDRs patrocinadas pela LAEP realizadas entre os dias 8.1.2010 e 13.1.2010.

120. Voto também pela absolvição de Othniel Rodrigues Lopes, Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha, Armando Tadeu Buchina e Arthur Gilberto Voorsluys da imputação de infração ao disposto no *caput* do art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002, c/c o art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976, no que concerne às alienações de BDRs patrocinadas pela LAEP realizadas entre os dias 14.1.2010 e 15.1.2010.

121. Voto pela absolvição de Luiz Álvaro Moreira Ferreira Filho da imputação de infração ao disposto no caput do art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002, c/c o art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976, com relação à alienação de 150.000 BDRs patrocinados pela LAEP, realizada no dia 28.1.2010.

122. Por fim, quanto à penalidade a ser aplicada a Othniel Rodrigues Lopes, convém observar que o acusado infringiu o disposto no *caput* do art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002, c/c o art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976 em oportunidades distintas: (i) na alienação de 400.000 BDRs patrocinados pela LAEP em 13.1.2010, (ii) na alienação de 400.000 BDRs em 18.1.2010, e (iii) na alienação de 350.000 BDRs em 20.1.2010.

123. De acordo com as informações resumidas na tabela abaixo e no documento anexo a este voto, Othniel Lopes obteve, de fato, vantagem financeira apenas no negócio realizado em 20.1.2010. Comparando a cotação pela qual alienou os 350.000 BDRs no dia 20.1.2010 com a cotação média do pregão de 28.1.2010, data da divulgação do fato relevante, chega-se à conclusão que Othniel Lopes evitou perda financeira no montante de R\$ 24.500,00.

Tabela 4: Resultado das operações de Othniel Lopes com BDRs da LAEP

Fato relevante de 15.1.2010 – BDR - Preço médio do dia 2,59					
Othniel Lopes					
13.1.2010	400.000	2,24	897.800,00	1.036.000,00	(138.200,00)
Fato relevante de 28.1.2010 – BDR - Preço médio do dia 2,58					
				Valor a 2,58	
18.1.2010	400.000	2,55	1.020.468,00	1.032.000,00	(11.532,00)
20.1.2010	350.000	2,65	927.500,00	903.000,00	24.500,00
Total					(125.232,00)

124. De outra parte, ressalto a gravidade das infrações praticadas por Othniel Lopes. Ninguém ignora que o *insider trading* é uma prática insidiosa e deletéria, cujos efeitos são devastadores para a credibilidade e o bom funcionamento do mercado brasileiro de valores

mobiliários. Por essa razão, entendo que as penalidades devem ser exemplares e proporcionais à gravidade das infrações²⁷.

125. Diante disso, voto da seguinte maneira:

(i) com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/1976, e §1º, inciso I, do mesmo dispositivo legal, pela condenação de Othniel Rodrigues Lopes à penalidade pecuniária no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por ter infringido o disposto no art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976, combinado com o *caput* do art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002, ao ter alienado, no dia 13.1.2010, 400.000 BDRs patrocinados pela LAEP, de posse de informações privilegiadas sobre a celebração de acordo, que seria divulgado ao mercado em 15.1.2010, por meio de aviso de fato relevante;

(ii) com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/1976, e §1º, inciso I, do mesmo dispositivo legal, pela condenação de Othniel Rodrigues Lopes à penalidade pecuniária no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por ter infringido o disposto no art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976, combinado com o *caput* do art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002, ao ter alienado, no dia 18.1.2010, 400.000 BDRs patrocinados pela LAEP, de posse de informações privilegiadas sobre a operação de conversão de dívidas da sociedade, que seria divulgada ao mercado em 28.1.2010, por meio de aviso de fato relevante;

(iii) com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/1976, e §1º, inciso I, do mesmo dispositivo legal, pela condenação de Othniel Rodrigues Lopes à penalidade pecuniária no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por ter infringido o disposto no art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976, combinado com o *caput* do art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002, ao ter alienado, no dia 20.1.2010, 350.000 BDRs patrocinados pela LAEP, de posse de informações privilegiadas sobre a operação de conversão de dívidas da sociedade, que seria divulgada ao mercado em 28.1.2010, por meio de aviso de fato relevante.

126. Por fim, proponho comunicar o resultado deste julgamento à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício/CVM/SGE/Nº 35/2011, enviado em 16.5.2011 (fl. 2495).

É como voto.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2015.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR

¹ Recurso nº 11.411, relativo ao PAS CVM nº 16/2002, iniciado na 371ª Sessão e finalizado na 375ª Sessão, e Recurso nº 11.408, relativo ao PAS CVM n. 16/2003, iniciado na 375ª Sessão e finalizado na 376ª Sessão.

² Vale transcrever o acórdão na íntegra: “Processo Administrativo. ANP. Prescrição Intercorrente. Art. 1º, §1º, Lei 9.873/99. inócrrrente. I - Inicialmente, cumpre trazer à colação o teor do art. 1º, § 1º, da Lei n.º 9.873/99, o qual dispõe que “incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho”. II - Em sendo assim, instaurado o procedimento administrativo, caso a Administração deixe o mesmo pendente de julgamento ou despacho por mais de três anos, forçoso será reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. III - In casu, pela análise dos documentos acostados aos autos, não se depreende que o procedimento administrativo ora em análise ficou paralisado desde a autuação, pendendo de julgamento ou despacho por mais de três anos. IV - Destarte, cumpre destacar que, quando a Administração pratica atos que impulsionam o processo, ainda que seja despacho de mero expediente, não estará caracterizada a inércia da mesma, não havendo, portanto, que se falar em prescrição intercorrente a que se refere o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/99 V - Remessa Necessária e Apelação da ANP providas” (TRF da 2ª Região, Sétima Turma Especializada, Processo n. 2004.5101.0140181, Rel. Des. Reis Friede, julg. 2.3.2011).

³ Em direção semelhante, v. entre outros o voto do Diretor Relator Marcelo Fernandez Trindade no julgamento do PAS CVM nº 04/2004, em 28.6.2006, e o voto da Diretora Relatora Luciana Dias, no julgamento do PAS CVM nº RJ2012/1666, em 3.4.2012.

⁴ Como estabelece a primeira parte do disposto no art. 13, *caput*, da Instrução CVM nº 358/2002: “*Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária (...)*”.

⁵ Como se infere da leitura conjunta da parte inicial e final do disposto no art. 13, *caput*, da Instrução CVM nº 358/2002: “*Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados (...) por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante*” (grifou-se).

⁶ Mencione-se, a título ilustrativo, o PAS RJ2013/9904, julgado em 28.4.2015, sob a relatoria do Diretor Roberto Tadeu, no qual se considerou, entre outros indícios da ocorrência de **insider trading**, o fato de o acusado trabalhar no departamento jurídico da companhia aberta, subordinado a pessoas que, comprovadamente, tiveram acesso à informação relativa ao fato relevante.

⁷ Veja-se a propósito a lição de José Carlos Barbosa Moreira, em tudo aplicável ao julgamento pela CVM dos processos administrativos sancionadores: “*O órgão judicial, para formar sua convicção e julgar a causa, precisa esclarecer-se acerca dos fatos relevantes, e essa, como ninguém ignora, é a função das provas. Pode acontecer, no entanto, – e o caso não é raro –, que, com referência a determinado fato, decisivo para a solução do litígio, a atividade instrutória se revele incapaz de ministrar, diretamente, elementos bastantes de convicção, e, por outro lado, venha aos autos material probatório suficiente para que o juiz se convença de ter ocorrido fato diverso, mas relacionado com aquele que constituía o thema probandum. A relação entre os dois fatos – o conhecido e o desconhecido – é tal, suponhamos, que da existência do primeiro se possa logicamente inferir, senão com absoluta certeza, ao menos com forte dose de probabilidade, a existência (ou a inexistência) do segundo. Nessas circunstâncias, nada mais razoável que valer-se o juiz do conhecimento adquirido sobre o fato x para tirar conclusões a respeito do fato y. O resultado desse raciocínio é que configura, propriamente, a presunção judicial: o juiz presume que ocorreu o fato y porque sabe que ocorreu o fato x, e sabe também que a ocorrência de um implica, necessária ou normalmente, a ocorrência do outro*” (*As Presunções e a Prova*, in *Temas de Direito Processual*, São Paulo: Saraiva, 1977, p. 57).

⁸ STF, 1ª Turma, HC 103.118/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 16.04.2012.

⁹ Voto proferido pela Diretora Norma Parente, no PAS CVM nº 24/00, julg. 18.8.2005.

¹⁰ Nessa direção, é ver-se: “As perplexidades e dificuldades que envolvem a aceitação de indícios como elementos suficientes a amparar uma condenação estão centradas no juízo de certeza que se exige para condenar e no princípio *in dubio pro reo*. Portanto, todo o esforço da doutrina e da jurisprudência que aceitam a condenação com base em indícios dirigiu-se para cercar a utilização de indícios da necessária segurança, como forma de conciliá-lo com o juízo de certeza e a presunção de inocência; e de se acautelar contra certos voluntarismos e evitar desvios de raciocínio.” (Voto do Diretor Luiz Antônio Sampaio Campos no PAS CVM nº RJ2002/2405, julg. 9.10.2003). Na mesma direção: “Os indícios possuem valor probatório suficiente para ensejar condenação. Exige-se, todavia, que tais indícios sejam convergentes e unívocos. A existência de contraindícios suficientes para inspirar dúvida nos julgadores deve conduzir à absolvição, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.” (Voto da Diretora Relatora Norma Parente no PAS CVM nº RJ 06/95, julg. 5.5.2005). V. ainda PAS CVM nº 24/05, Dir. Rel. Sérgio Weguelin, julg. em 2.7.2008).

¹¹ Vide documento de fls. 18-23 e Item 8 do Relatório.

¹² Relatório de Análise GMA-1 20/10, às fls. 485 a 505.

¹³ A DFP da LAEP de 31.12.2008 foi apresentada em 27.8.2009, e os ITRS de 2009 em 16.10.2009, 4.11.2009 e 23.12.2009.

¹⁴ Segundo a relação de fls. fls. 1474-1475, Othniel Lopes recebeu 2.000.000 BDRs, Rodrigo Ferraz 1.000.000 BDRs, Armando Buchina, 450.000 BDRs, Arthur Gilberto, 800.000 BDRs, e Tarcísio Duque 450.000 BDRs, tendo Othniel Lopes e Rodrigo Ferraz recebido um lote extra, segundo documento de fls. 1477-1478.

¹⁵ Art.13, §7º As vedações previstas no *caput* e nos §§ 1º a 3º não se aplicam às negociações realizadas pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, de acordo com política de negociação aprovada nos termos do art. 15.

¹⁶ Art. 15. A companhia aberta poderá, por deliberação do conselho de administração, aprovar política de negociação das ações de sua emissão por ela própria, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores,

membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária.

§1º A política de negociação referida no *caput* não poderá ser aprovada ou alterada na pendência de ato ou fato relevante ainda não divulgado, e deverá necessariamente:

I - contar com a adesão expressa das pessoas mencionadas no *caput* que queiram dela se beneficiar, as quais deverão observá-la estritamente; e

II – incluir a vedação de negociações, no mínimo, no período de 15 (quinze) dias anterior à divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da companhia; e

III - adotar procedimentos que assegurem que em nenhuma hipótese a companhia negociará com as próprias ações nos períodos de vedação estabelecidos nesta Instrução e na própria política de negociação.

§2º A critério da companhia, a adesão de que trata o inciso I do parágrafo anterior poderá contemplar a indicação detalhada de política de negociação própria do interessado, a qual deverá observar os mesmos elementos mínimos referidos no parágrafo anterior.

§ 3º É permitida a aquisição de ações de emissão da companhia no período a que se refere o inciso II do § 1º por administradores, membros do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas da companhia, bem como de suas controladas e coligadas, criados por disposição estatutária, realizada em conformidade com plano de investimento aprovado pela companhia, desde que:

I – a companhia tenha aprovado cronograma definindo datas específicas para divulgação dos formulários ITR e DFP; e

II – o plano de investimento estabeleça:

a) o compromisso irrevogável e irretratável de seus participantes de investir valores previamente estabelecidos, nas datas nele previstas;

b) a impossibilidade de adesão ao plano na pendência de fato relevante não divulgado ao mercado, e durante os 15 (quinze) dias que antecederem a divulgação dos formulários ITR e DFP;

c) a obrigação de prorrogação do compromisso de compra, mesmo após o encerramento do período originalmente previsto de vinculação do participante ao plano, na pendência de fato relevante não divulgado ao mercado, e durante os 15 (quinze) dias que antecederem a divulgação dos formulários ITR e DFP; e

d) obrigação de seus participantes reverterem à companhia quaisquer perdas evitadas ou ganhos auferidos em negociações com ações de emissão da companhia, decorrentes de eventual alteração nas datas de divulgação dos formulários ITR e DFP, apurados através de critérios razoáveis definidos no próprio plano.

¹⁷ Art.13, § 4º Também é vedada a negociação pelas pessoas mencionadas no *caput* no período de 15 (quinze) dias que anteceder a divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da companhia, ressalvado o disposto no § 3º do art. 15.

¹⁸ Art.13, § 4º Também é vedada a negociação pelas pessoas mencionadas no *caput* no período de 15 (quinze) dias que anteceder a divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da companhia, ressalvado o disposto no § 3º do art. 15.

¹⁹ V., nesse sentido, o PAS CVM nº 07/1991, julg. 6.6.1994, Dir. Rel. José Estevam de Almeida Prado. V. também o PAS nº 17/2002, julg. 25.10.2005, Dir. Rel. Wladimir Castelo Branco, em cujo voto se destaca que seria razoável admitir a negociação, ainda que na pendência de divulgação de fato relevante, caso fique comprovado que foi realizada por uma “necessidade premente”, frente à qual não se poderia exigir da pessoa conduta diversa.

²⁰ Art. 13, §7º. As vedações previstas no *caput* e nos §§ 1º a 3º não se aplicam às negociações realizadas pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, de acordo com política de negociação aprovada nos termos do art. 15.

²¹ Art. 15, §3º. É permitida a aquisição de ações de emissão da companhia no período a que se refere o inciso II do § 1º por administradores, membros do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas da companhia, bem como de suas controladas e coligadas, criados por disposição estatutária, realizada em conformidade com plano de investimento aprovado pela companhia, desde que: (...) II – o plano de investimento estabeleça: a) o compromisso irrevogável e irretratável de seus participantes de investir valores previamente estabelecidos, nas datas nele previstas; (...)

²² Marcelo Fernandez Trindade, *Vedações à negociação de valores mobiliários por norma regulamentar: interpretação e legalidade*, in Marcelo Vieira Von Adamek, *Temas de Direito Societário e Empresarial Contemporâneos*, São Paulo: Malheiros, 2011, pp. 467-468.

²³ V., por todos, PAS CVM n.º RJ2013/5793, Dir. Rel. Luciana Dias, no julg. 27.1.2015.

²⁴ PAS CVM RJ-2006-4665, Relator Diretor Pedro Marcilio, julg. 9.1.2007.

²⁵ PAS CVM RJ-2006-8572, Relator Diretor Otavio Yazbek, julg. 16.3.2010.

²⁶ Em linha com o julgamento do Processo Administrativo Sancionador RJ2013-2714, Dir. Rel. Luciana Dias, julg. 7.10.2014, no qual o Colegiado aplicou a pena pecuniária no valor de R\$ 200.00,00 (duzentos mil reais) ao *insider* que havia obtido lucro de R\$ 1.022,12 (um mil e vinte e dois reais e doze centavos) com a operação irregular. Com efeito, em casos como o presente, em que o lucro é relativamente pequeno, mostra-se desprovida de efetividade e desproporcional à gravidade da infração a fixação da penalidade com base no critério estabelecido no art. 11, § 1º, inciso III, da Lei nº 6.385/1976. Nesses casos, portanto, mostra-se acertada a definição da penalidade com base no inciso I do citado dispositivo legal, em montante suficiente para desestimular condutas semelhantes, com base no inciso I do citado dispositivo legal.

Anexo ao Voto do Diretor Relator Pablo Renteria no julgamento do PAS RJ2011-3823

Cotações dos BDRs patrocinados pela LAEP (MILK11) em janeiro de 2010



Empresa: LAEP INVESTMENTS LTD.

Resumo Diário - Mercado à Vista

Ref: Jan/2010

Nome da Ação: DR3 (MILK11)							Preço por ação (em R\$)					
Dia	Especif.	Nº. Negócios	Part. (%)	Quantidade	Volume (R\$)	Part. (%)	Aber.	Mín.	Máx.	Méd.	Fech.	
0	4	DR3	4.757	1,630	38.217.100	53.601.626,00	1,057	1,44	1,34	1,48	1,40	1,36
1	5	DR3	3.595	1,076	22.377.100	29.562.945,00	0,441	1,36	1,26	1,38	1,32	1,30
2	6	DR3	8.857	2,564	62.927.000	94.893.916,00	1,421	1,55	1,42	1,59	1,51	1,55
3	7	DR3	25.530	7,180	147.848.200	278.218.078,00	4,780	1,50	1,50	2,15	1,88	2,04
4	8	DR3	39.327	11,543	211.917.600	611.359.342,00	9,920	2,20	2,16	3,55	2,88	2,68
5	11	DR3	20.870	5,746	88.882.800	271.147.832,00	4,601	3,25	2,77	3,45	3,05	2,86
5	12	DR3	13.385	3,761	50.670.000	123.493.373,00	2,076	2,72	2,11	2,78	2,44	2,37
7	13	DR3	15.043	4,225	69.308.500	167.030.446,00	2,635	2,28	2,12	2,76	2,41	2,75
8	14	DR3	11.425	3,231	55.542.600	153.287.794,00	2,508	2,90	2,62	2,93	2,76	2,65
9	15	DR3	6.065	1,841	26.514.100	68.565.045,00	1,156	2,50	2,39	2,82	2,59	2,50
0	18	DR3	3.726	1,890	14.353.000	36.670.711,00	0,914	2,59	2,47	2,65	2,55	2,52
1	19	DR3	5.762	1,850	16.854.300	42.564.221,00	0,812	2,50	2,42	2,62	2,53	2,50
2	20	DR3	11.483	3,039	48.906.100	127.983.406,00	1,832	2,50	2,46	2,71	2,62	2,53
3	21	DR3	2.831	0,706	10.783.200	27.118.431,00	0,380	2,60	2,41	2,63	2,51	2,43
4	22	DR3	2.547	0,728	8.986.800	22.322.403,00	0,335	2,42	2,41	2,57	2,48	2,42
5	26	DR3	5.892	1,663	22.980.900	59.720.637,00	0,972	2,52	2,46	2,70	2,60	2,62
5	27	DR3	3.499	1,025	9.668.200	24.471.702,00	0,426	2,61	2,46	2,64	2,53	2,47
7	28	DR3	3.276	1,220	11.642.700	30.073.744,00	0,551	2,55	2,47	2,69	2,58	2,59
8	29	DR3	15.065	5,009	48.243.100	131.310.787,00	2,202	2,62	2,55	2,85	2,72	2,55
9	Total		202.935	3,207	966.623.300	2.353.396.439,00	2,064					

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2011/3823 realizada no dia 9 de dezembro de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM nº RJ2011/3823 realizada no dia 9 de dezembro de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2011/3823 realizada no dia 9 de dezembro de 2015.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu por absolvições e pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias individuais, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE